

**Autorité de Régulation des Marchés publics
(ARMP)**

**Recueil des Décisions et Avis
rendus par le
Comité de Règlement des Différends
(CRD)
Années 2018 à 2019**

1^è Partie

**Commentaires des décisions
choisies**

Edition 2020

Sigles et Abréviations

AC	Autorité contractante
AO	Appel d'Offres
AOO :	Appel d'Offres Ouvert
AOR :	Appel d'Offres Restreint
AP :	Attribution Provisoire
ARD :	Agence Régional de Développement
ARMP :	Autorité de Régulation des Marchés publics
BID :	Banque Islamique de Développement
CCAG :	Cahier des Clauses Administratives Générales
CCAP :	Cahier des Clauses Administratives Particulières
CHNU :	Centre Hospitalier National Universitaire
CMP14 :	Code des Marchés publics. Décret n° 2014-1212 du 22 septembre 2014
COA :	Code des Obligations de l'Administration
CRD :	Comité de Règlement des Différends
CROUS :	Centre Régional des Œuvres Universitaires
DAO :	Dossier d'Appel d'Offres
DCMP :	Direction Centrale des Marchés Publics
DPAO :	Données particulières de l'Appel d'Offres
DRPCO :	Demande de Renseignements et de Prix à Compétition ouverte
DSP :	Délégation de Service Publics
EPIC :	Etablissement Public à caractère Industriel et Commercial
MESRI :	Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l'Innovation
MRVHCV :	Ministère du Renouveau Urbain et du Cadre de vie
OFOR :	Office des Forages Ruraux
PPM :	Plan de Passation des marchés
PROMISE :	Programme de Promotion de la Microfinance Islamique
SRM PPSL :	Service Régional des Marchés Publics Pôle de Saint Louis
SRMPPT :	Service Régional des Marchés Publics Pôle de Thiès
UAMM :	Université Amadou Mahtar Mbow

Recueil des Décisions et Avis du CRD 2018-2019

Préface du Directeur général de l'ARMIP

L'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) a pour missions, entre autres, de veiller au respect de la réglementation dans le domaine des marchés publics et de contribuer à l'information et la formation des acteurs de la commande publique.



Le Comité de Règlement des Différends (CRD) est l'un des organes de l'ARMP qui lui permettent de réaliser ses missions. En effet, le CRD est chargé de :

- Recevoir les dénonciations des irrégularités constatées par les parties intéressées ou celles connues de toute autre personne, avant, pendant et après la passation ou l'exécution des marchés publics et délégations de service public. Si ces faits caractérisent des violations de la réglementation relative à la passation des marchés publics, le Président du Comité saisit, soit la Commission Litiges, soit le Comité en formation disciplinaire, selon le cas. Si ces faits caractérisent des violations de la réglementation relative à l'exécution des marchés publics, il saisit le Comité en formation disciplinaire ; s'ils constituent une infraction pénale, il saisit les juridictions compétentes ;
- Recevoir et enregistrer les recours exercés par les candidats et soumissionnaires aux marchés publics et délégations de service public relatifs à la procédure de passation des marchés publics et délégations de service public, ainsi qu'à leur exécution ;
- Les décisions du CRD sont exécutoires et ont force contraignante sur les parties. Elles sont définitives, sauf en cas de recours devant le juge, ce recours n'ayant pas d'effet suspensif ;
- Le Président du Conseil de Régulation peut également saisir le CRD à l'effet de statuer sur toute irrégularité de procédure dont l'ARMP aurait été saisie.

Les décisions du CRD sont publiées dans leur intégralité sur le site internet de l'ARMP (www.armp.sn). Elles représentent une documentation volumineuse. Elles interprètent et font application des nombreuses dispositions de la réglementation de la commande publique. Au fil des années, elles ont fini par constituer une jurisprudence que l'on ne peut plus ignorer et dont on ne peut plus se passer en matière du droit et de la pratique de la commande publique.

Pour ces raisons, l'ARMP procède, depuis 2015, à l'analyse de la production du CRD afin d'en faciliter la diffusion auprès des acteurs de la commande publique. La réalisation de ce travail est confiée régulièrement à un expert indépendant. Jusqu'à présent, cette activité s'est traduite par la publication de trois éditions du Bulletin des Décisions et Avis du CRD. Le présent ouvrage couvre la période de 2018 à 2019. Il présente quelques innovations par rapport aux précédentes éditions.

Ainsi, le travail du Consultant est réparti en deux parties :

- D'abord, un choix de décisions commentées ; il s'agit des décisions de principe rendues en 2018 et 2019. Elles portent sur les questions pour lesquelles le plus grand nombre de décisions ont été rendues. Leur commentaire diffère du simple abstract, résumé des décisions. Il s'agit d'une analyse systémique qui les replace dans leur contexte et dans leurs antécédents jurisprudentiels ;
- Ensuite, un recueil des décisions et avis rendus en 2018 et 2019, en versions abrégées. Celles-ci reproduisent l'intitulé de la décision, l'objet du litige et le dispositif. Elles permettent ainsi de prendre connaissance des faits, de la motivation du CRD, ainsi que du sens de sa décision. Ce contexte justifie l'intitulé de l'ouvrage, à savoir " Recueil des Décisions et Avis du CRD".

L'ouvrage est doté d'une table des matières détaillée qui permet d'identifier et d'atteindre la décision souhaitée.

Nous espérons que les acteurs de la commande publique, les universitaires et les praticiens trouveront un intérêt dans l'utilisation de cette publication.

C'est le lieu, pour nous, d'adresser nos sincères remerciements au Professeur Jacques Mariel NZOUANKEU pour son accompagnement dans la réalisation de ce projet.

Saêr NIANG
Directeur général de l'ARMP

Commentaires des décisions choisies

Table des matières

1.	Compétence matérielle et territoriale du CRD	6-16
2.	Compétence consultative du CRD...	17-27
3.	Procédure. Conditions de recevabilité des recours.....	28-35
4.	Organisation de la commande publique Constitution des Commissions des marchés	36-45
5.	Organisation de la commande publique, Composition des Commissions des marchés	46-60
6.	Appels d'offres, Examen préliminaire et recevabilité des offres.....	61-67
7.	Appels d'offres Conformité des offres.....	68-82
8.	Délégation de service public (DSP) Affermage Conformité des offres Non-conformités Substantielles.....	83-97
9.	Délégation de service public (DSP) Référé administratif de suspension Ordonnance n° 05 du 10 octobre 2019.....	98-105
10.	Sanctions disciplinaires.....	106-110

Compétence matérielle et territoriale du Comité de Règlement des Différends de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP/CRD)

Domaines de compétence

Cas d'incompétence

1^{ère} Espèce

L'Administrateur de fourniture et d'impression SAU

DÉCISION N° 01/18/ARMP/CRD/SUS/ DU 03 JANVIER 2018

Sur la suspension de l'attribution provisoire du marché

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 91 du Code des Marchés publics que, dès réception du recours contentieux, le Comité de Règlement des Différends examine si celui-ci est recevable et, dans l'affirmative, ordonne à l'autorité contractante de suspendre la procédure de passation du marché ;

Considérant que l'article 89 dudit Code dispose que, préalablement à tout recours contentieux, tout candidat à un marché public doit saisir l'autorité contractante d'un recours gracieux dans un délai de cinq (5) jours francs et ouvrés à compter de la publication de l'avis d'attribution provisoire du marché, de l'avis d'appel à la concurrence ou de la communication du dossier d'appel à la concurrence ;

Que l'article 90 dudit Code ajoute qu'en l'absence de suite favorable à son recours, le requérant dispose de trois (3) jours ouvrables à compter de la réception de la réponse de l'autorité contractante ou de l'expiration du délai de trois (3) jours ouvrables imparti à l'autorité contractante pour répondre, pour présenter par notification écrite, au Comité de Règlement des Différends, un recours qui doit invoquer une violation caractérisée de la réglementation des marchés publics et est accompagné d'une pièce attestant du paiement de la consignation ;

Considérant que faisant suite au rejet de son offre à travers la parution du 21 décembre 2017 du quotidien d'informations « le soleil », le requérant a adressé à la SONES un recours reçu le 21 décembre 2017 ;

Que par lettre du 22 décembre 2017, le Directeur Général de ladite structure a répondu au recours gracieux ;

Que n'étant pas satisfait des réponses apportées par l'autorité contractante, le requérant a introduit un recours contentieux devant le CRD, le 26 décembre 2017 ;

Considérant que les journées des 24 et 25 décembre 2017 étant tombées respectivement dimanche et jour férié, elles ne peuvent compter dans la computation du délai imparti pour saisir le CRD ;

Considérant sous ce rapport, le requérant a formé son recours deux jours après la réponse de l'autorité contractante ;

Qu'ainsi, les délais requis sont largement observés ;

Considérant que la consignation a été payée suivant la quittance n° 100012017003617 du 26 décembre 2017 ;

Qu'il y a lieu de déclarer le recours recevable et d'ordonner la suspension de la procédure de passation du marché litigieux et la transmission par l'autorité contractante des documents nécessaires à l'instruction du recours ;

PAR CES MOTIFS :

- 1) Déclare le recours recevable ;*
- 2) Ordonne la suspension de la procédure de passation du marché litigieux et la communication par l'autorité contractante des documents nécessaires à l'instruction du recours ;*

2^e Espèce

Centre Régional des Œuvres Universitaires Sociales
DÉCISION N° 005/18/ARMP/CRD/DEF DU 17 JANVIER 2018

Sur la recevabilité de la saisine du CRD

Considérant que le décret n°2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'ARMP, en son article 22, donne compétence à la Commission des Litiges du Comité de Règlement des Différends pour statuer sur les saisines relatives aux litiges opposant les organes de l'Administration intervenant dans le cadre de la procédure de passation ou d'exécution des marchés publics et délégations de service public ;

Considérant que la saisine du Directeur du CROUS, autorité contractante, vise l'avis négatif rendu par la Direction centrale des Marchés publics (DCMP), organe de contrôle a priori, suivant lettre N°00080/MEFP/DCMP/ du 19 décembre 2017 ;

Que la saisine est fondée sur les dispositions de l'article 142.3 du décret n°20141212 du 22 septembre 2014 portant Code des marchés publics qui, dans ce cas de figure, ne fixent pas de délai de saisine du CRD ;
Qu'il convient de déclarer recevable le présent recours ;

CHINA Gezhouba GROUP CO LTD

c/

**Organisation pour la Mise en Valeur
du Fleuve Sénégal (OMVS)**

Décision n°70 du 24 mai 2018

SUR LA COMPÉTENCE

Considérant qu'il ressort de l'instruction du dossier que le marché lancé par OMVS a pour objet la sélection d'un constructeur pour la conception, la fourniture, la construction et la mise en service du projet d'aménagement hydro-électrique de Koukoutamba en République de Guinée ; Considérant que l'OMVS est une organisation internationale, créée le 11 mars 1972, par une convention signée par les chefs d'État de la République de Guinée, de la République du Mali, de la République Islamique de Mauritanie et de la République du Sénégal ;

Considérant qu'en vertu de son statut d'organisation internationale, l'OMVS est dotée de ses propres règles de passation et d'exécution de marchés publics communément appelées « Législation des Marchés de l'OMVS » ;

Que cette législation est approuvée conformément aux règles de fonctionnement de l'organisation par l'instance délibérante qu'est le conseil des ministres suivant résolution n° 56 du 04/05/1976 et 84 du 05/01/1978 ;

Considérant que le Comité de Règlement des Différends est compétent pour statuer sur les différends nés avant, pendant et après la passation ou l'exécution des marchés publics et délégations de service public, passés sous l'égide du Code des Marchés publics du Sénégal, ou en application d'accords de financement ou de traités sauf si des dispositions contraires résultent des procédures prévues par lesdits accords ou traités internationaux.

Qu'il y a lieu, en conséquence, de se déclarer incompétent, de rapporter la décision de suspension de la procédure et d'ordonner la restitution de la consignation ;

PAR CES MOTIFS :

- 1) Constate que le marché pour la sélection d'un constructeur pour la conception, la fourniture, la construction et la mise en service du projet d'aménagement hydro-électrique de Koutoutamba en République de Guinée, est lancé par OMVS, une organisation internationale créée par convention signée par les chefs d'État ;*
- 2) Constate que le marché litigieux est soumis aux règles de passation et d'exécution des marchés de l'OMVS appelées : « législation des marchés publics de l'OMVS »*
- 3) Dit que le Comité de Règlement des Différends est compétent pour arbitrer les différends nés lors de la passation ou l'exécution des marchés passés selon la législation des marchés publics du Sénégal ;*
- 4) En conséquence, se déclare incompétent, rapporte la décision de suspension et ordonne la restitution de la consignation.*

Commentaires

Les trois décisions ci-dessus ont donné au CRD l'occasion de préciser les champs et l'étendue de sa compétence contentieuse. Dans la 1^{re} espèce, n° 01 du 03 janvier 2018 **Société GTS, saisi sur le fondement de l'article 91 du CMP14, le CRD, faisant application des articles 89 et 90 du CMP14, a déclaré le requérant dont l'offre a été rejetée, recevable à introduire un recours contre l'attribution provisoire d'un marché public.** Dans la 2^e espèce, décision n° 005/18/du 17 janvier 2018, **le Directeur du Centre Régional des œuvres universitaires sociales de Thiès (CROUS), contestait une décision du démembrement régional de la Direction centrale des Marchés publics (DCMP). Le CRD se déclare compétent sur le fondement de l'article 142.3 du CMP14.** En se déclarant **incompétent dans l'affaire OMVS**, décision n° 70 du 24 mai 2018, le CRD délimite le fondement de sa compétence contentieuse aux groupes d'articles 89, 90 ; 91 et 142.3 du CMP.

Une vue d'ensemble sur le cadre légal de cette compétence permet d'en apprécier la portée.

I. Vue d'ensemble sur la compétence contentieuse du CRD

1. Sur le plan stratégique, les missions de l'organe de régulation des marchés publics sont encadrées par l'article 5 de la directive n° 5 du 9 décembre 2005 de l'UEMOA, portant contrôle et régulation des marchés publics et de délégations de service public dans l'UEMOA. Ces missions sont les suivantes :

- *la définition des politiques en matière de marchés publics ;*
- *la formation dans le domaine des marchés publics ;*
- *le maintien du système d'information des marchés publics ;*
- *la conduite des audits.*

L'article 30 nouveau du Code des obligations de l'Administration (COA) précise ce cadrage. Cet article prescrit en effet que l'organe de régulation s'intitule **Autorité de Régulation des marchés publics ; que celle-ci est dotée du statut d'autorité administrative indépendante ; qu'elle bénéficie de l'autonomie financière.** En son sein,

« une structure administrative spécialement mise en place à cet effet assure le contrôle a priori des procédures de passation des marchés publics, délégations de service public et contrats de partenariats, les missions de collecte et diffusion d'informations sur l'attribution et les conditions d'exécution de ces marchés et contrats ainsi que le conseil aux Autorités contractantes et à leurs agents ».

L'article 31 nouveau du COA crée, en ses termes, un organe chargé du recours non juridictionnel :

Article 31 nouveau

Recours relatif à la procédure de passation

En cas de non-respect des règles relatives à la passation des marchés et sans préjudice des recours gracieux et contentieux, une procédure spéciale de recours non juridictionnel devant un organe placé au sein de l'Agence de Régulation des Marchés publics, est ouvert à toute personne qui a participé

à une procédure de passation et n'a pas été désignée attributaire dans les conditions définies par le Code des Marchés publics.

2. Sur le plan opérationnel, les missions sont reformulées en objectifs spécifiques, d'actes juridiques ou de toute autre nature que l'ARMP est habilitée à prendre, lesquels délimitent sa compétence, Cette reformulation est effectuée par le **Code des marchés publics**, porté par le décret 2014-1212 du 22 septembre 2014, ainsi que par le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007, portant organisation et fonctionnement de l'ARMP.

Le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 précité confère à l'organe chargé du recours non juridictionnel le titre de **Comité de Règlement des Différends (CRD)** et, dans ses articles 18 à 23, lui attribue une partie de la compétence de l'ARMP. Le CRD est ainsi chargé au sein de l'ARMP de la compétence contentieuse, de la compétence consultative et de la compétence en matière disciplinaire.

Les trois décisions ci-dessus délimitent le champ de la compétence contentieuse du CRD.

II. Compétence contentieuse fondée sur des articles 89 al 2 ; 90 et 91 du CMP14

3. Dans la 1^{er} Espèce ci-dessus (*ARMP/CRD 01 du 03 Janvier 2018 Société GTS*), le requérant a saisi le CRD pour demander l'annulation de l'attribution provisoire du marché dont il était l'un des soumissionnaires. Il soutient que c'est à tort que son offre a été écartée.

Le CRD s'assure que la procédure engagée est recevable au regard de l'article 89 du CMP14 ; en particulier, que le requérant a introduit un recours gracieux auprès de l'autorité contractante ; que ce recours a été rejeté ; qu'ensuite il a saisi le CRD dans les délais prescrits et qu'enfin la consignation a été payée (voir nos commentaires dans le Recueil des Décisions et Avis du CRD, 2018 à 2019 sous : 3 Procédure, *ARMP/CRD/SUS 022 du 28 Février 2019 Delgas assainissement*). Toutes les conditions de recevabilité prescrites par les articles 89 et 90 du CMP14 étant remplies, le CRD déclare sa requête recevable et : « **Ordonne la suspension de la procédure de passation du marché litigieux et la communication par l'autorité contractante des documents nécessaires à l'instruction du recours** ».

4. Pour statuer comme il l'a fait, le CRD s'est fondé sur **l'article 89, al 2 CMP14** ainsi conçu :

Ce recours peut porter sur la décision d'attribuer ou de ne pas attribuer le marché, les conditions de publication des avis, les règles relatives à la participation des candidats et aux capacités et garanties exigées, le mode de passation et la procédure de sélection retenus, la conformité des documents d'Appels d'Offres à la réglementation, les spécifications techniques retenues, les critères d'évaluation. Il doit invoquer une violation caractérisée de la réglementation des marchés publics.

Ces dispositions sont complétées par différents articles du CMP14, portant notamment sur les critères de qualification des candidats (art. 43 et 44 CMP14), les critères d'évaluation des offres (art 59 CMP14), l'examen préliminaire des offres (art 68 du CMP), l'évaluation des offres (art 70 du CMP14).

Elles sont également complétées par le décret 2007-546 du 25 avril 2007, portant organisation et fonctionnement de l'ARMP, en son article 21 ainsi conçu :

Article 21 : *La Commission Litiges est saisie des recours relatifs à la procédure de passation, mentionnés au deuxième alinéa de l'article 20 du présent décret, dans le délai prévu par les dispositions de la section 4 du Chapitre 7 du Titre III du Code des Marchés publics et ayant pour objet de contester :*

- *les décisions d'attribuer ou de ne pas attribuer le marché ou la convention de délégation ;*
- *les conditions de publication des avis ;*
les règles relatives à la participation des candidats et aux capacités et garanties exigées ;
le mode de passation et la procédure de sélection retenus ;
la conformité des documents d'Appels d'Offres à la réglementation ;
les spécifications techniques retenues ; les critères d'évaluation.

La compétence du CRD fondée sur les articles 89, al 2 et 90 du CMP14 concerne la phase de passation du marché ; c'est le contentieux de la décision d'attribuer ou de ne pas attribuer le marché. Les critères de qualification des candidats, les critères de conformité des offres, les critères d'évaluation des offres et leur mise en œuvre lors du dépouillement et d'analyse des offres, de la notation et du classement des candidats visent à préparer la décision d'attribuer ou de ne pas attribuer le marché. Cette procédure se déroule donc jusqu'à l'attribution définitive et l'approbation du marché.

5. La suspension est un acte de procédure présentant le caractère d'une mesure conservatoire. Elle vise à éviter qu'un marché soit attribué, ou qu'un candidat soit écarté, alors que la procédure de sa passation est entachée d'illégalités. Elle se déroule selon les étapes suivantes

- a) Un candidat est éliminé ou écarté au cours de la procédure de passation de marché. Il peut l'être au cours de l'examen préliminaire de la recevabilité des candidatures, ou lors de la vérification de la qualification, ou encore lors de l'évaluation des offres et du classement des candidats. Dans tous les cas de figure, c'est au moment **de l'attribution provisoire** que le candidat est informé de son élimination ou du rejet de son offre.
- b) Le candidat ainsi éliminé saisit le CRD pour contester l'attribution provisoire du marché en indiquant sommairement le motif du rejet de son offre.
- c) À ce stade, le CRD ne dispose que des informations contenues dans le recours du requérant. Il vérifie que les délais de saisine sont respectés et que la consignation est payée. Si tel est le cas, il ordonne la suspension de la procédure de passation de marché et demande à l'autorité contractante de lui transmettre les documents y afférents.

Cette procédure ressemble au référé administratif de suspension de la Cour suprême, mais en diffère sur un point essentiel. Dans le référé administratif de suspension qui a remplacé l'ancienne procédure de sursis à exécution, le juge de

référé n'ordonne pas automatiquement la suspension, il vérifie si les moyens présentés au soutien de la demande de suspension sont sérieux, c'est-à-dire pourraient justifier l'annulation de la décision dont la suspension est sollicitée. Il vérifie aussi s'il y a urgence.

Le Régulateur des marchés publics procède autrement. Dès lors que les conditions de recevabilité de sa saisine sont remplies, il ordonne la suspension de la procédure. En fait, il **a compétence liée** pour le faire, dès lors que la procédure de saisine est régulière.

Il en est ainsi, parce que, à ce stade de la procédure, il ne dispose que de la version des faits ainsi que des moyens présentés par le candidat. Pour les apprécier, il devrait accéder aux documents du marché. Ce sont ces documents qui **donnent un contenu** aux critères définis dans le CMP14. Par exemple, les capacités financières figurent parmi les qualifications définies à l'article 44 du CMP14. Toutefois, le contenu de ces capacités varie selon le marché ; c'est donc au cas par cas qu'elles se déterminent. Dans ces conditions, le Régulateur des marchés publics pour évaluer la suite qui sera réservée au recours dont il est saisi doit d'abord suspendre la procédure de passation du marché et demander que lui soit transmis les documents du marché.

6. Après la décision de suspension, l'Autorité contractante transmet les documents du marché au CRD ; après instruction, il siège pour trancher **le litige au principal**. Les suites sont alors les suivantes.

6.1. Annulation de l'attribution provisoire et reprise de l'évaluation

Le CRD constate des irrégularités dans la procédure de passation des marchés, constate que le recours du requérant est fondé, annule l'attribution provisoire, et ordonne la reprise de l'évaluation selon les indications ou directives qu'il donne. C'est le cas le plus fréquent. On peut citer quelques exemples : *ARMP/C'RD 123 du 07 Août 2019 Maire de la Commune de Fanaye ; ARMP/CRD 192 du 18 Décembre 2019 Entreprise Feuze Services ; ARMP/CRD 132 du 21 Août 2019 Société 2XINE Media ; ARMP/CRD 155 du 02 Octobre 2019 Groupement CI Emali Somiha T ; ARMP/CRD 181 du 04 Décembre 2019 OUMOU Leader Distribution Equipement ; ARMP/CRD 011 du 16 Janvier 2019 Société JLS Sénégal ; ARMP/CRD 050 du 20 Mars 2019 Librairie Papeterie Daradji (LDP) ; ARMP/CRD 061 du 03 Avril 2019 Société Ecorel.*

6.2. Annulation de l'attribution provisoire et reprise de la procédure

Dans certains cas de figure, il est vrai peu nombreux, le CRD décide qu'« **une reprise de l'évaluation ne saurait permettre de corriger les manquements** » ; **dans ces cas, le CRD ordonne la reprise de toute la procédure de passation du marché** *ARMP/CRD 096 du 12 Juin 2019 Société Almadinatou Almounawara ; ARMP/CRD 121 du 31 Juillet 2019 Groupement Dioubo SARL/IRRI Afrique.*

6.3. Rejet du recours contre l'attribution provisoire et poursuite de la procédure de passation du marché

Dans cette hypothèse, le CRD juge que le recours dont il est saisi n'est pas fondé. Il le rejette, et ordonne la poursuite de la procédure. Les cas de rejet sont aussi nombreux que ceux de l'annulation. On peut citer *ARMP/CRD 004 du 09 Janvier 2019*

Société Diama Technologie ; ARMP/CRD 033 du 27 Février 2019 Laliane Entreprises ; ARMP/CRD 054 du 02 Avril 2019 Elecnor ; ARMP/CRD 093 du 29 Mai 2019 Sénégalaise des eaux (SDE) ; ARMP/CRD 102 du 03 Juillet 2019 Entreprise Flowserve ARMP/CRD 148 du 18 Septembre 2019 Entreprise Dieye Diazel Sénégal ; ARMP/CRD 176 du 13 Novembre 2019 Groupement Socomi/Touba Négoce International ; ARMP/CRD 141 du 17 Octobre 2018 Société Toure Computer Systems.

6.4. Annulations et rejets dans la même décision

Dans certains marchés allotis, il est arrivé que dans la même décision, le CRD annule l'attribution provisoire de certains lots et rejette les recours visant d'autres lots. Dans ces cas, la reprise de l'évaluation ne portera que sur les lots dont l'attribution provisoire aura été annulée (*ARMP/CRD 098 du 26 Juin 2019 Entreprise Baol Construction*).

III Compétence contentieuse fondée sur l'article 142.3 du CMP14

7. Dans l'affaire du Centre Régional des œuvres universitaires sociales de Thiès (CROUS), 2^e espèce ci-dessus, le Directeur du CROUS souhaitait passer par entente directe un marché relatif à la restaurant des étudiants. Comme le prescrit le Code des marchés publics il avait sollicité à cet effet l'avis du Service Régional des Marchés publics, pôle de Thiès (SRMP PT), démembrement de la Direction Centrale des Marchés publics pour la Région de Thiès.

Le SRMPPT émet un avis négatif. Le Directeur du CROUS de Thiès saisit alors le CRD qui décide que la DCMP était fondée à émettre un avis négatif parce que les conditions n'étaient pas réunies pour conclure un marché par entente directe. Toutefois, en raison de la sensibilité de ce service public, à titre exceptionnel, le CRD autorise la conclusion d'un tel marché pour une durée de six (06) mois à compter de la notification de la décision.

8. Pour décider comme il l'a fait, le CRD s'est fondé sur l'article 142.3 du CMP14 ainsi conçu :

Art. 142 : *Si l'Autorité contractante n'accepte pas les avis et recommandations qui, le cas échéant, auront été formulées par la Direction chargée du contrôle des marchés publics concernant la possibilité d'utiliser une procédure autre que l'Appel d'Offres ouvert ou relatives à la proposition d'attribution du marché, elle ne peut poursuivre la procédure de passation qu'en saisissant le Comité de Règlement des Différends près l'Organe chargé de la régulation des marchés publics.*

Ces dispositions sont complétées par l'article 22 du décret n° 2007-546 du 25 avril 2007, portant organisation et fonctionnement de l'ARMP, ainsi conçu.

Article 22 : *La Commission Litiges statue sur les litiges entre les organes de l'Administration intervenant dans le cadre de la procédure de passation ou d'exécution des marchés publics et délégations de service public dont le Comité a été saisi.*

La procédure fondée sur ces dispositions se déroule comme suit :

- a) Le requérant saisit obligatoirement la DCMP ou son démembrement dans les matières où une telle saisine est prescrite.
- b) La DCMP peut émettre un avis de non-objection, un avis négatif (on dit aussi qu'il **réserve** son avis), ou donner des recommandations.
- c) Le requérant, non satisfait, peut saisir le CRD d'un recours.
- d) Aucun délai n'est prescrit pour la saisine du CRD.

9. L'issue de cette voie de recours, c'est, soit l'octroi de l'autorisation sollicitée, soit le rejet de la demande d'autorisation, ou enfin le retour du dossier à la DCMP pour avis ou revue. Quelques exemples peuvent être cités

9.1. Autorisations accordées

- a) Pour conclure un marché par entre **directe** *ARMP/CRD 005 du 17 Janvier 2018 Centre Régional des Œuvres Universitaires ; ARMP/CRD 017 du 30 Janvier 2019 Agence des Travaux et de Gestion des Routes (Ageroute) ; ARMP/CRD 019 du 06 Février 2019 Faculté de Médecine de Pharmacie et D'Odontologie ; ARMP/CRD 008 du 16 Janvier 2019 Commune de Dodel ; ARMP/CRD 046 du 05 Avril 2018 Ministre de L'Education Nationale Centres Régionaux de Formation des Personnels de L'Education (CRFPE).*
- b) **Conclusion d'un avenant sur la base d'une convention de financement (art. 3 CMP14)** *(ARMP/CRD 104 du 01 Août 2018 Centre Hospitalier National de Pikine)*
- c) **Immatriculation d'un marché conclu par DRPCO** *(ARMP/CRD 108 du 08 Août 2018 Agence Sénégalaise d'Electrification Rurale (ASER) ; ARMP/CRD 008 du 16 Janvier 2019 Commune de Dodel)*

9.2. Rejets décidés

- a) **Demande de 2^e renouvellement de marché arrivé à expiration** *(ARMP/CRD 030 du 21 Mars 2018 Ageroute) ; ARMP/CRD 066 du 02 Mai 2018 Agence de Construction des Bâtiments et Edifices Publics).*
- b) **Contestation d'une liste restreinte de l'appel d'offres restreint** *(ARMP/CRD 104 du 01 Août 2018 Centre Hospitalier National de Pikine).*
- c) **Rétractation de la décision de rejet du CRD ; poursuite de la procédure sur la base de l'article 3 CMP14** *(ARMP/CRD 044 du 05 Avril 2018 Senelec (Financement KFW)).*
- d) **Demande d'immatriculation d'un marché ; contrat frappé de nullité ; art. 51 COA** *(ARMP/CRD 110 du 08 Août 2018 Projet de Parc de Technologies).*
- e) **Demande de prorogation du délai d'exécution d'un marché** *(ARMP/CRD 112 du 16 Août 2018 Agence Sénégalaise d'Electrification Rurale (ASER)).*

- f) **Annulation de la procédure de sélection d'un partenaire, lancée par l'ADIE** (*ARMP/CRD 021 du 06 Février 2019 Ministre de la Communication, des Télécommunications, des Postes et de l'Economie Numérique*).

9.3. Retour à la DCMP pour avis

- a) **Avenant au marché clé en mains (offre spontanée)** (*ARMP/CRD 146 du 18 Septembre 2019 Senelec*)
- b) **Cellule relais basée à Paris pour un marché non inscrit au PPM** (*ARMP/CRD 169 du 23 Octobre 2019 Direction de la Coopération Technique du Secrétariat General du Gouvernement*).

IV. Cas d'incompétence

A. Incompétence territoriale

10. L'organisation pour la Mise en Valeur du Fleuve Sénégal (OMVS) a lancé un marché pour le recrutement d'un constructeur pour la conception, la fourniture, la construction et la mise en service du projet d'aménagement hydro-électrique de Koukoutamba en République de Guinée.

La société requérante, non satisfaite de l'attribution provisoire de ce marché par l'OMVS, saisit le CRD pour la contester. Conformément à l'article 91 CMP14, après s'être assuré de la régularité de sa saisine, le CRD ordonne la suspension de la procédure de passation de ce marché. Statuant ensuite au principal dans la présente espèce, il se déclare incompétent et annule sa précédente décision de suspension.

11. Les motifs pour lesquels le CRD s'est déclaré incompétent sont les suivants :

- a) L'OMVS est une organisation internationale créée par une convention qui regroupe la République de Guinée, la République du Mali, la République Islamique de Mauritanie et la République du Sénégal
- b) L'OMVS s'est dotée d'un instrument juridique appelé « **Législation des marchés de l'OMVS** »

12. Sur le plan juridique, ces motifs sont justifiés. Toutefois, en tant que Régulateur des marchés publics, le CRD aurait pu avoir une autre approche du règlement de ce litige. Ainsi, il aurait pu d'abord constater que « la législation des marchés de l'OMVS » peut être assimilée aux directives prises en application de l'article 3 du CMP14, relatives aux marchés passés en application d'accords de financements ou de traités. Les marchés de l'OMVS peuvent être assimilés à ceux-là. Lors de leur passation, ce sont les dispositions contraires de la « législation des marchés de l'OMVS » qui s'appliqueraient. Toutefois, étant donné que les travaux objet du marché se déroulent en République de Guinée, le CRD est incompétent pour en suivre la procédure de passation.

13. Les fonctions pédagogiques d'une telle décision auraient été les suivantes :

- a) Le CRD est incompétent, non pas parce qu'il s'agit de marché de l'OMVS, mais parce que l'activité objet du marché ne se trouve pas sur le territoire national sénégalais. Il ne s'agit pas d'une incompétence matérielle, mais d'une incompétence territoriale.

b) Pour l'avenir, le CRD exercera toutes ses compétences pour les marchés de l'OMVS qui se déroulaient au Sénégal.

14. La présente espèce montre les limites de la procédure de suspension de la procédure de passation des marchés. Dans le système les articles 89, 90 et 91 du CMP14, en matière de contestation de la procédure d'attribution provisoire des marchés, dès que le recours du candidat remplit les conditions de recevabilité relatives aux délais, la suspension est décidée. Contrairement au juge de référé administratif de suspension qui peut apprécier les moyens présentés pour ordonner ou non la suspension, le CRD semble avoir compétence liée : il est tenu d'ordonner la suspension, dès lors que les délais de procédure sont respectés.

Ainsi dans la présente espèce, le régulateur des marchés publics a pu s'apercevoir, dès sa première saisine, qu'il se déclarerait incompétent pour examiner le recours au principal, mais ne disposait d'aucun moyen juridique pour arrêter la procédure à ce stade-là.

15. En l'état actuel de la réglementation, l'incompétence territoriale est une présomption qu'aucun texte ne réglemente formellement. Les intitulés mêmes des textes ne l'imposent pas. Par exemple, les principaux instruments ne sont pas intitulés : **Code des obligations de l'Administration sénégalaise** ; ou encore : **Code des marchés publics du Sénégal**. Aucune disposition de ces actes ne prescrit qu'ils ne s'appliquent qu'au Sénégal. Dès lors en application d'un principe inspiré de celui de la compétence universelle en matière criminelle, rien ne s'oppose à ce que le droit de la commande publique du Sénégal, notamment sa jurisprudence, s'applique en dehors de son territoire, au moins dans l'espace communautaire de l'UEMOA.

B Incompétence matérielle

16. L'incompétence territoriale se distingue de l'incompétence matérielle.

Celle-ci vise les cas dans lesquels **l'objet du marché** ne rentre pas dans les attributions du CRD. On en trouve un exemple dans la décision du CRD n° 21 du 6 février 2019, dans laquelle l'ARMP s'opposait à l'ADIE. Le CRD constate et décide :

Considérant que le CRD, dans le cadre de l'examen de cette demande, devra au préalable trancher la question préjudicielle liée au droit de propriété ou non de l'ADIE sur l'infrastructure à fibre optique, ce qui excède ses pouvoirs au regard des dispositions du Code des marchés publics et du décret 2007-546 du 25 Avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'ARMP.

Dit que le CRD se déclare incompétent pour trancher le conflit de compétence opposant l'ADIE au MCTPEN portant sur la sélection d'un partenaire en vue de l'exploitation des surcapacités ; (ARMP/C'RD 021 du 06 Février 2019 Ministre de la Communication, des Télécommunications, des Postes et de l'Economie Numérique).

La question peut se poser de savoir ce que déciderait le CRD, s'il étant saisi de l'une des matières exclues du champ d'application du Code des marchés publics énumérées à l'article 3, al 3 et 4 du CMP14. Il devrait **se déclarer** incompétent.

2

Compétence consultative du Comité de Règlement des Différends de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP/CRD)

Régime des Avis

1^{er} Espèce

Applicabilité de la réglementation des marchés publics aux travaux de réhabilitation du patrimoine privé

Avis n° 004/19/ARMP/CRD du 10 juillet 2019

L'OBJET DE LA DEMANDE

Il résulte de la saisine et des faits qui la sous-tendent, que la demande porte sur l'applicabilité des dispositions du Code des Marchés publics au processus de réhabilitation du patrimoine privé, subventionné par l'État, dans le cadre du programme de développement touristique de la ville de Saint- Louis.

ÉMET L'AVIS QUI SUIVIT :

- 1) Dit que la saisine de l'APIX est recevable ;*
- 2) Constate que la subvention qui vient en complément des ressources propres supportées par les propriétaires privés est un appui financier de l'Etat, destinée à la réhabilitation du patrimoine privé se trouvant dans l'Ile de Saint-Louis, classée patrimoine mondial de l'Humanité depuis 2000 par l'Unesco ;*
- 3) Constate que l'accord de financement précise expressément que, dans le cadre de la composante « patrimoine », les propriétaires des maisons privées, bénéficiaires de subventions, sont les maîtres d'ouvrage des travaux sur les biens ;*
- 4) Dit que les caractéristiques d'un marché public, telles que définies à l'article 4.24 du Code des Marchés publics, ne sont pas réunies au cas d'espèce ;*
- 5) Dit que les personnes privées, bénéficiaires de la prestation de réhabilitation n'ont pas la qualité d'autorité contractante au sens de l'article 2 du Code des marchés publics ;*
- 6) Déclare, en conséquence, que le processus de réhabilitation du patrimoine privé sur la base de subventions accordées à des privés dans le cadre du programme de développement touristique de Saint-Louis et de sa région n'est pas soumis aux dispositions du Code des Marchés publics ;*

2^e Espèce

Mise en œuvre de la réfaction proposée par la CCBM, Pôle automobile

Avis n° 006/18/ARMP/CRD du 2 mai 2018

OBJET DE LA DEMANDE

Il résulte de la saisine et des faits qui la sous-tendent que la demande d'avis porte sur la mise en œuvre de la réfaction proposée par la CCBM-Pôle Automobile en 2015.

ÉMET L'AVIS QUI SUIT :

- 1) *Constate que la demande d'avis du Ministère du Renouveau urbain et du Cadre de Vie porte sur le lot 2 du marché n° F 2684/15 souscrit et approuvé respectivement le 30 novembre et le 07 décembre 2015;*
- 2) *Constate que CCBM Automobile a proposé une réfaction qui consiste à réduire d'un million de francs CFA le prix unitaire initial afin de livrer à la place du véhicule 4x4 pick up double cabine toutes options avec une boîte automatique, le même type de véhicule mais avec une boîte manuelle ;*
- 3) *Constate que la réfaction prévue par l'article 109 du décret n°2014 — 1212 du 22 septembre 2014 portant code des marchés publics consiste en une réduction sur le prix global du marché ou sur les prix unitaires et qu'en cas d'accord du titulaire du marché sur cette proposition de réfaction, une réception provisoire soit effectuée, constatant l'accord des parties sur la réfaction retenue ;*
- 4) *Dit que la réfaction est soumise à un régime juridique ;*
- 5) *Constate que l'autorité contractante peut admettre une réfaction du prix proportionnelle à l'importance des imperfections constatées ;*
- 6) *Dit, toutefois, que les imperfections constatées ne doivent pas être de nature à porter atteinte à la sécurité, au comportement ou à l'utilisation des ouvrages, fournitures et services ;*
- 7) *Dit que les avantages et les inconvénients de la boîte manuelle et de celle automatique se manifestent sous plusieurs aspects qui permettent de considérer que l'imperfection induite n'est pas mineure.*
- 8) *Dit que pour le cas d'espèce, la mise en œuvre de la réfaction telle que prévue, aurait pour conséquence de fausser les règles de concurrence prévues dans le dossier d'appel à concurrence*

Commentaires

Les deux décisions visées ont donné l'occasion au CRD d'exercer sa compétence consultative en émettant des avis sur **la notion d'autorité contractante** régie par les articles 2 et 4.5 du CMP14, ainsi que sur l'article 109 du CMP14 relatif à **la réfaction des marchés**.

Dans **son avis n° 4/19/ du 10 juillet 2019**, 1^{er} espèce ci-dessus, à la demande de l'APIX, le CRD émet l'avis que les dispositions du CMP14 ne sont pas

applicables au processus de réhabilitation du patrimoine privé de l'île de Saint-Louis du Sénégal, même si ce patrimoine bénéficie des subventions de l'État dans le cadre du programme de développement touristique de cette ville, parce que leurs bénéficiaires **n'ont pas la qualité d'autorités contractantes** au sens de l'article 2 du CMP14.

Dans l'affaire qui a donné lieu à **l'avis n° 6/18 du 2 mai 2018**, 2^e espèce ci-dessus, la CCBM Automobile, attributaire d'un marché de vente d'automobiles, proposait de livrer au Ministère du Renouveau Urbain et du Cadre de vie, autorité contractante, à la place d'un véhicule 4x4 pick up boîte automatique, le même type de véhicule, mais avec une boîte manuelle, moyennant une réfaction consistant à réduire de 1 million CFA, le prix unitaire initial. Le ministre saisissait le CRD d'une demande d'avis à cet effet. Après analyse de **l'article 109 du CMP14** qui régit la réfaction, le CRD émet un avis défavorable au motif que la réfaction telle que prévue, aurait pour conséquence de fausser les règles de concurrence prévues dans le dossier d'appel à concurrence.

Les décisions susvisées donnent l'occasion de préciser

- I. Le cadre juridique et stratégique des avis du CRD.
- II. Les particularités de sa compétence consultative.
- III. Les questions de fond traitées et la portée de ses avis,
- IV. Ainsi que sa pratique consultative.

I. Cadre juridique et stratégique

La compétence consultative du CRD, l'habilite à donner des avis. Les textes qui organisent cette compétence renforcent son rôle de régulateur des marchés publics.

A. Les textes

1. La compétence consultative du CRD est organisée par différents articles ci-après du décret n° 2007-546 du 25 avril 2007, portant organisation et fonctionnement de l'ARMP.

- a) Avis sur les faiblesses éventuelles du Code des marchés *Article 2, .al.1.*
 1. *d'identifier les faiblesses du Code des Marchés publics et proposer, sous forme d'avis, de proposition ou de recommandation, toute mesure législative, réglementaire, de nature à améliorer le système, dans un souci d'économie, de transparence et d'efficacité ;*
- b) Veiller à l'application de la réglementation et des études
 5. *de veiller, par ses avis et recommandations, à l'application de la réglementation et des procédures relatives à la passation des marchés publics et délégations de service public des documents standards et contribuer à la promotion d'un environnement transparent favorable au jeu de la concurrence et au développement des entreprises et de compétences nationales stables et performantes ;*
- c) Rendre des avis dans le cadre de la procédure de règlement amiable des litiges.

Art 21. al 2.

- *de rendre des avis dans le cadre de la procédure de règlement amiable des litiges relatifs à l'exécution des Marchés publics et délégations de service public*

B. Compétence consultative, outil de régulation des marchés publics

2. L'habilitation à rendre des avis est un instrument mis à la disposition du CRD pour développer sa stratégie de régulation des marchés publics. Ainsi :

Les avis peuvent intervenir en amont, alors qu'aucun litige n'est pendant, en vue de proposer toute mesure législative ou réglementaire de nature à améliorer le système de passation des marchés. Les avis peuvent intervenir simultanément avec les recours au contentieux pour interpréter la réglementation et les procédures de passation des marchés. Les avis peuvent aussi : intervenir en prolongement du litige contentieux, dans le cadre du règlement amiable des litiges

La fonction stratégique de l'avis tient du fait qu'il est l'outil privilégié d'élaboration des principes généraux de la régulation et de la commande publique. Les textes ci-dessus encadrant les avis énoncent certains de ces principes, par exemple :

- le principe d'économie, de transparence et d'efficacité (art 2, al 1^{er} du décret 2007-565 du 25 avril 2007)
- la promotion et la protection du jeu de la concurrence (art. 2, al 5)
- le développement des entreprises et des compétences nationales qu'on désigne parfois par le terme de préférence nationale (art 2. al 5)

II. Particularités de la compétence consultative

Les particularités de la compétence consultative du CRD portent sur sa procédure et le fond des avis émis.

A. Particularités de la procédure consultative

3. Quelques particularités de la procédure consultative sont mentionnées dans la motivation de l'avis n° 004 du 10 juillet 2019, relatif à **l'applicabilité du Code des marchés publics aux travaux de réhabilitation d'un patrimoine privé**, 1^{ère} espèce

Ces particularités sont au nombre de trois

3.1. Le fondement de la compétence consultative. Dans l'espèce, le CRD fonde sa compétence sur l'art 2.5 du décret 2007-546 du 25 avril 2007 qu'il reproduit dans son intégralité. En effet, la formulation même de la demande d'avis montre qu'il s'agit d'un problème d'application de la réglementation.

3.2. La saisine du CRD. Le CRD vise les trois catégories suivantes des personnes habilitées à soumettre une demande d'avis : toute autorité contractante, tout candidat ou titulaire de marché. Il ne peut s'agir que d'une liste indicative. Le

décret 2007-546 du 25 avril 2007 ne donne nulle part la liste des personnes habilitées à faire une demande d'avis. En particulier l'autorité contractante ne figure nulle part dans ce texte. Les articles 20, 2^e alinéa et 21, 1^{er} alinéa de ce décret ne visent que **les candidats et les soumissionnaires aux marchés** comme recevables à intenter des recours contentieux.

En ajoutant les autorités contractantes à cette liste, le CRD a simplement estimé, à juste titre, qu'il n'était pas logique que des candidats et soumissionnaires soient habilités à demander des avis, mais que les autorités contractantes ne soient pas admises à les solliciter. Dans le même esprit d'ouverture, le CRD pourrait reconnaître que **des tiers** aux marchés soient recevables à demander des avis. Ce sera le cas des établissements bancaires qui fournissent des garanties et des lignes de crédit aux candidats, ou encore qui sont impliqués en cas de nantissement des marchés publics. On pourrait même envisager de recevoir, en matière d'avis, la demande des «dénonciateurs» reconnus à l'article 20 du décret 2007-546 du 25 avril 2007.

3.3. Délai de la saisine. Dans la présente espèce, le CRD statue qu'aucun délai n'est requis. En réalité, il ne s'agit pas d'une particularité exclusive à la demande d'avis ; les recours contentieux intentés contre les avis de la DCMP, notamment ceux rendus sur la base de l'article 142.3 du CMP14 et de l'article 22 du décret 2007-546 du 25 avril 2007, ne sont soumis à aucune condition de délai.

B. Particularités de l'instrumentum portant les avis

4. L'acte formel, l'instrumentum portant les avis est similaire, pour l'essentiel, à celui de la décision rendue au contentieux. Ainsi, on observe les similarités ci-après :

- a. Les avis sont rendus par le CRD siégeant en Commission Litiges.
- b. Le libellé est conçu et formalisé de la même manière ; sauf toutefois que les actes mentionnent bien qu'il s'agit d'Avis. Ils sont enregistrés dans une série propre, distincte de celle des décisions rendues au contentieux
- c. Les visas sont aussi complets que possible
- d. La structuration est la même ; elle distingue la présentation des faits ; le résumé de la demande d'avis, les moyens présentés à l'appui de la demande ; l'objet de la demande ; ensuite, l'examen de la demande. Dans cette partie, le CRD présente la motivation au soutien de l'avis qu'il émettra. La décision finale de fond, le dispositif, est précédé de l'expression **Émet l'avis qui suit.**

L'instrumentum se termine par la formule exécutoire, la même que celle que portent les décisions rendues au contentieux.

Dans l'avis n° 8 du 2 mai 2018, portant sur la refaction des véhicules, 2^e espèce ci-dessus, le CRD a tenté de donner aux avis une formulation et un style différents de la décision prise au contentieux. À cet effet, il commençait sa motivation de la manière suivante :

«Considérant que votre demande d'avis porte sur le lot 2»...

«Considérant que dans votre lettre de saisine»...

Cette initiative, fort opportune, n'a pas été poursuivie dans les autres avis du CRD. Elle était pourtant bien adaptée au type de délibération que constitue l'avis.

III Questions des fond traitées et portée des avis du CRD

Sur la période de 2018 à 2019, les avis publiés du CRD traitent des questions d'application de la réglementation des marchés, et notamment du Code des Marchés. Ces avis se fondent donc sur l'article 2.5 du décret n° 2007-546 du 25 avril 2007.

A. Questions de fond

5. Dans la 1^{er} espèce ci-dessus, objet de l'avis n° 4 du 10 juillet 2019, la question, objet de la demande d'avis, était de savoir si les travaux de réhabilitation du patrimoine privé par leurs propriétaires, bénéficiaires des subventions de l'État, relevaient du Code des marchés. La motivation du CRD était la suivante
- a. Pour que le Code des marchés s'applique à ces travaux, il faut qu'ils présentent le caractère des marchés publics.
 - b. Le marché public est défini par l'article 4. 24 du Code des marchés comme un «contrat écrit, conclu à titre onéreux par une autorité contractante». Ainsi, pour qu'il y ait marché public, il faut qu'une autorité contractante paie un prix en contrepartie des travaux, fournitures ou services qu'elle achète
 - c. La subvention versée aux propriétaires privés par l'État ne présente pas le caractère d'un prix payé par un acheteur public pour acquérir des travaux, fournitures ou services nécessaires à son service ; cette subvention est un appui financier effectué dans le cadre d'un programme de développement du tourisme. À cela s'ajoute que l'État n'a pas agi en tant qu'autorité contractante au sens de l'article 2 du Code des marchés publics.

Le CRD conclut dès lors que ces travaux ne présentent pas le caractère des marchés publics et **émet un avis dans ce sens.**

Cet avis a ainsi permis d'approfondir les articles 2 et 4.5 du Code des marchés publics.

6. La 2^e espèce ci-dessus, relative à la refaction d'un véhicule, fait application de l'article 109 du Code des marchés publics, ainsi conçu :

Article 109 :

Lorsque la commission chargée de la réception des travaux, fournitures ou services constate que les prestations fournies par le titulaire ne satisfont pas entièrement aux prescriptions du marché, mais qu'elles peuvent être admises en l'état, l'Autorité contractante peut proposer au titulaire une refaction sur le prix global du marché ou sur les prix unitaires.

En cas d'accord du titulaire du marché sur cette proposition de réfaction, une réception provisoire est effectuée constatant l'accord des parties sur la réfaction retenue.

Le CRD précise ainsi cet article

Que l'on peut, dès lors, définir la réfaction comme la décision motivée prise par l'autorité contractante de réduire le montant du prix des prestations à verser au titulaire lorsque les prestations ne satisfont pas entièrement aux prescriptions du marché, mais peuvent être reçues en l'état ;

En d'autres termes, la réfaction, c'est la constatation d'une imperfection dans les travaux, fournitures ou services, objet de la commande publique, que le titulaire du marché propose de compenser par le paiement d'un prix.

7. Dans cette affaire, CCBM automobile s'était vu attribuer le marché de livrer un véhicule 4x4 avec **boîte automatique** au Ministère du Renouveau urbain. Il lui propose finalement de réduire le prix d'un million (une réfaction de 1 million) et de lui livrer le même type de véhicule, mais **avec une boîte manuelle**. C'est dans ces conditions que le ministre a saisi le CRD pour avis. Dans le silence du Code des marchés sur la question, le CRD devait déterminer **le régime juridique de la réfaction**. À cet effet, il pose les principes ci-après

7.1. Son application doit être prévue par les textes, les cahiers des CAG et le cahier des CAP.

7.2. L'Autorité contractante doit décider que les prestations, sans être entièrement conformes, peuvent être admises en l'état.

7.3. Le prix à payer doit être proportionnel aux imperfections constatées, et le montant déduit doit pouvoir couvrir la réparation de la réfaction, si nécessaire les imperfections.

7.4. Les imperfections doivent être mineures en ce sens qu'elles ne doivent pas porter atteinte à la sécurité, au comportement ou à l'attribution des ouvrages, fournitures et services.

Le CRD constate alors que le remplacement d'une boîte automatique par une boîte manuelle ne constitue pas une imperfection mineure ; qu'au contraire, cette opération fausse les règles de la concurrence et aboutirait finalement à la livraison d'un véhicule de qualité inférieure à celle qui est prévue dans le marché.

Par ces motifs, le CRD émet un avis négatif à la réfaction proposée par CCBM Automobile.

B. Portée des avis du CRD

La portée des avis du CRD se détermine au regard du demandeur d'avis et au regard des tiers.

a. Portée à l'égard du demandeur d'avis

8. Les avis sont classés selon leur force contraignante **à l'égard de la personne qui en fait la demande.**

- a) Les avis simples ne créent pas d'obligation pour le demandeur ; il peut suivre leurs conclusions ou les ignorer.
- b) Les avis obligatoires désignent ceux qui doivent être obligatoirement sollicités. La seule obligation qui pèse sur le demandeur, c'est de les solliciter avant de prendre une décision déterminée. Ensuite, il est libre de suivre ou de ne pas suivre les conclusions de l'avis.
- c) Les avis conformes ou contraignants sont ceux que le demandeur est tenu de solliciter, et tenu de suivre. Il doit solliciter l'avis avant de prendre la décision et sa décision doit l'être conforme à l'avis sollicité.

La réglementation des avis ne procède pas à leur classement en fonction de leur force contraignante, ce qui peut affecter leur régime.

On peut d'abord estimer que de ce fait, le CRD ne rend que **des avis simples** : le demandeur n'est pas tenu de les prendre et, au cas où il les sollicite, n'est pas tenu de les suivre. Dans le cas de la réfaction du véhicule par exemple, malgré l'avis négatif du CRD, le propriétaire peut accepter le véhicule avec la boîte manuelle, sachant qu'il est de qualité inférieure à celui qui a été commandé.

L'autre approche consiste à admettre que le CRD émet des **avis conformes** ; le demandeur est tenu de les solliciter, et de les respecter. Ainsi, dans l'affaire de la réhabilitation des propriétés privées, une procédure de passation des marchés qui serait engagée sur ces travaux financés par une subvention, se heurterait à l'objection de la DCMP. De même, un ministre qui accepterait une réfaction de son véhicule malgré l'avis réservé du CRD pourrait faire l'objet de reproches à l'occasion des vérifications des corps de contrôle, ou de l'audit de ses services. Dans un cas limite, le demandeur d'avis pourrait ne pas le suivre en annulant la procédure de passation du marché concerné. Sauf cas exceptionnel en effet, l'autorité contractante **n'a pas compétence liée** pour lancer un marché, contrairement aux autres autorités administratives qui ont compétence liée pour prendre certains actes lorsque les conditions prescrites à cet effet sont réunies.

Cette interprétation est confortée par l'article 21 dernier alinéa du décret 2007-546 du 25 avril 2007 aux termes duquel **«les décisions de la Commission sont contraignantes et ont force obligatoire sur les parties»**. À l'évidence, cette disposition vise les **«décisions»** de la Commission Litiges rendues au contentieux. Mais on pourrait considérer qu'au sens large, le terme «décision» désigne toute **«délibération»** du CRD. L'avis est délibéré et adopté par le CRD selon les mêmes formes que les décisions rendues au contentieux.

b. Portée des avis à l'égard des tiers

9. À l'égard des tiers, la portée des avis se ramène à la question de leur opposabilité ; il s'agit de savoir si, et dans quelle mesure les avis du CRD sont **opposables** aux tiers. Aucune réglementation ne décide de cette question.

Toutefois, les avis constituent le corpus de **la doctrine administrative du CRD**. Ils ne sont pas opposables aux tiers en tant qu'ils créeraient des droits à leur profil ou des obligations à leur charge, mais ils sont opposables à tous en tant qu'ils **expriment l'opinion officielle de l'ARMP sur les questions traitées**.

IV. Pratique consultative du CRD

10. Au cours de la période 2018-2019, les avis rendus par le CRD sont fondés sur l'article 2 du CMP14 et l'article 2. al 5 du décret n° 2007-546 du 25 avril 2007. Ils visent à clarifier la notion d'autorité contractante et à préciser la réglementation en matière de passation des marchés.

On peut en relever quelques-uns.

AVIS N° 002/18/ARMP/CRD DU 28 FÉVRIER 2018

Question : La manière de se conformer à l'exigence de désigner un responsable des services techniques ou son représentant dans la commission des marchés publics des autorités contractantes tel que l'Hôpital Principal de Dakar.

Avis : Dit qu'en conséquence, le sens qu'il faut donner à la disposition est que les autorités contractantes concernées, doivent désigner un responsable ou son représentant par service technique visé dans l'organigramme officiel ;

AVIS N° 003/18/ARMP/CRD DU 28 FÉVRIER 2018

Question : Une éventuelle obligation de la SDE de créer une nouvelle société à l'égard de la prestation de la SDE de créer une nouvelle société.

Avis : Qu'en cas de désignation de la SDE attributaire du contrat susvisé, elle ne sera pas obligée de mettre en place une nouvelle société.

AVIS N° 004/18/ARMP/CRD DU 14 MARS 2018

Question : L'applicabilité des dispositions du Code des marchés publics au processus de souscription d'un contrat d'adhésion ou d'abonnement.

Avis :

3) Dit que la sélection de prestataires ou de fournisseurs pour l'hébergement de site web et l'abonnement à des services, sous forme électronique ou seulement

distribuée en réseau, n'est pas compatible avec les procédures édictées par le Code des Marchés publics ;

3) Dit, en conséquence, que par dérogation, les autorités contractantes n'ont pas à soumettre la souscription des contrats d'hébergement de site internet et d'abonnement à des services et fournitures, sous forme électronique ou seulement distribuée en réseau aux dispositions du Code des Marchés publics ;

4) Dit, cependant, qu'il est mieux indiqué, pour l'ADIE, de fixer la durée du contrat d'abonnement à trois (3) ans renouvelable au lieu de quinze (15) ans ;

AVIS N° 005/18/ARMP/CRD DU 28 MARS 2018

Question : Régularité de la conclusion de la convention signée entre l'Hôpital Principal de Dakar et RAN International Sénégal

Avis :

1) Constate que la convention, transmise pour avis, est une délégation de service public sous la forme d'une concession ;

2) Constate que la convention a été signée sans saisine préalable de la DCMP ;

3) La déclare nulle en application de l'article 51 du Code des Obligations de l'Administration ;

AVIS N° 006/18/ARMP/CRD DU 28 MARS 2018

Question : Applicabilité des dispositions du Code des Marchés publics à la procédure de souscription de contrats d'assurance retraite complémentaire et assurance indemnité de fin de carrière.

Avis : Dit que l'article 3.3.b exclut la passation des prestations résultant des contrats de travail aux dispositions du Code des Marchés publics ;

Déclare, en conséquence, que la souscription d'une police d'assurance retraite complémentaire et d'une police d'assurance fin de carrière pour le compte des employés des autorités contractantes n'est pas soumise aux dispositions du Code des Marchés publics.

AVIS N° 007/18/ARMP/CRD DU 02 MAI 2018

Question : Le caractère fractionnaire de la gestion, par chaque entité autonome de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, de ses marchés publics.

1) Dit que le fait que chaque entité de l'Université, à qui les lois et règlements reconnaissent le pouvoir d'administrer ses crédits et d'ordonner son budget, conduise, de manière autonome, ses marchés ne constituent pas un fractionnement ;

Avis : Dit qu'en conséquence, le Rectorat, comme chaque entité autonome de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, doit disposer d'une commission et d'une cellule de passation des marchés ainsi que de son propre plan de passation.

AVIS N°001/19/ARMP/CRD DU 30 JANVIER 2019

Question : APIX S.A souhaite obtenir du CRD un avis pour définir une conduite à tenir sur la poursuite de la procédure d'entente directe entamée, suite au refus de la DCMP de connaître du dossier.

Avis : Dit que la DCMP est compétente pour procéder à la revue a priori sur la base des directives de tous les marchés qui ne sont pas examinés par la banque et à toutes les étapes de la procédure ;

AVIS N° 002/19/ARMP/CRD DU 15 MAI 2019

Question : La PNA souhaite obtenir du CRD un avis sur la soumission des marchés subséquents issus de l'accord-cadre international AOI-PNA 6/2016 au contrôle a priori, notamment à l'examen juridique et technique.

Avi s :

6) Dit, en conséquence, que les marchés subséquents à la conclusion d'un accord-cadre ne sont pas soumis à l'examen juridique et technique de la Direction centrale des Marchés publics ;

7) Dit, en revanche, que lesdits marchés, à l'exception de ceux revêtant la forme de bons de commande, doivent être soumis pour immatriculation à l'organe chargé du contrôle a priori ;

8) Dit que le processus de passation et d'exécution de ces marchés subséquents doit, quel que soit le montant des contrats, faire partie de ceux à auditer dans le cadre de l'exercice du contrôle a posteriori ;

AVIS N° 003/19/ARMP/CRD DU 26 JUIN 2019

Question prise en charge des indemnités dues aux membres de la commission des marchés notamment au taux applicable aux DPRCO.

Avis : Estime que l'indemnité de 30 000 FCFA applicable à l'appel d'offres est celle applicable au DRPCO ;

Procédure
Conditions de recevabilité des recours.
Délais
Régime général des articles 89, 90 et 91 CMP14

ARMP/CRD/SUS 022 du 28 Février 2019
DELGAS ASSAINISSEMENT

PAR CES MOTIFS :

- 1) *Constate que l'autorité contractante a, par lettre du 19 février 2019, adressé à la société Delgas Assainissement SUARL une correspondance pour l'informer du rejet de son offre ;*
- 2) *Constate que la requérante, en application des dispositions précitées, a saisi l'autorité contractante d'un recours gracieux le 21 février 2019 auquel cette dernière a répondu par courrier du 25 février 2019 ;*
- 3) *Dit qu'à compter de la réception de la réponse de l'autorité contractante, la requérante avait un délai de trois (3) jours ouvrables et francs pour saisir le CRD de l'ARMP ;*
- 4) *Constate que le recours contentieux de la société Delgas Assainissement SUARL est parvenu au service courrier de l'ARMP le 27 février 2019, soit avant l'expiration du délai légal ;*
- 5) *Déclare le recours recevable et ordonne, par conséquent, la suspension de la procédure de passation du marché relatif à une délégation de service public, par affermage, portant sur la gestion des stations de traitement des boues de vidange dans les régions de Dakar, Thiès et Diourbel (CC-PRMBV-077) lancé par l'Office national de l'Assainissement du Sénégal (ONAS) ;*

Commentaires

I FAITS

L'Office National de l'Assainissement du Sénégal a lancé un marché relatif à une délégation de service public par affermage portant sur la gestion des stations de boues de vidange dans certaines régions du pays. L'offre de la société Delgas Assainissement a été rejetée. Celle-ci conteste l'attribution provisoire de ce marché et à cet effet, en application de l'article 90 du CMP14, saisit le CRD d'un recours. Statuant sur ce recours dans sa décision susvisée CRD/SUS n° 022 du 28 février 2019, le CRD constate que la requérante remplit les conditions de recevabilité relatives aux délais, prescrites par les articles 89 et 90 du CMP14, la déclare recevable et ordonne la suspension de la procédure de passation de ce marché.

L'appréciation de cette décision conduit à examiner la réglementation des délais et son application par le CRD pendant la procédure de passation des marchés, la computation des délais et la jurisprudence du CRD sur cette question.

II. Réglementation des délais et application par le CRD

A. Les textes

2. Pour statuer comme il l'a fait, le CRD se fonde sur l'article 91 CMP14 qui prescrit que, lorsqu'il est saisi, il doit s'assurer que le requérant remplit les conditions de recevabilité. Dans l'ordre chronologique, ce sont les conditions de recevabilité relatives aux délais qui sont instituées. Elles sont prescrites par les articles 89, al 3 et 4, ainsi que l'article 90, al 1^{er} CMP14. Elles sont les suivantes :

a) Le candidat ou le requérant doit, obligatoirement, exercer un recours gracieux auprès de l'autorité contractante. Ce recours doit être exercé dans **les cinq (5) jours francs et ouvrés** suivant la publication de l'avis d'attribution provisoire du marché (art 89, al 3 CMP14).

b) L'autorité contractante dispose de **trois (03) jours ouvrables** pour répondre au recours gracieux. À cet effet, l'autorité contractante peut :

donner une **suite favorable** au recours gracieux, auquel cas, la procédure se termine à ce stade ;

rejeter expressément le recours gracieux, par exemple, par écrit.

garder le silence ; ne donner aucune réponse ; dans ce cas, le silence gardé par l'autorité contractante pendant plus de trois (03) jours ouvrables constitue un **rejet implicite** du recours gracieux (article 89, al.4 CMP14).

c) Le requérant, dont le recours gracieux est rejeté expressément ou implicitement, peut introduire un recours gracieux auprès du CRD dans les trois (03) jours ouvrables selon les modalités ci-après :

- en cas de rejet exprès du recours gracieux, le requérant doit saisir le CRD dans les trois (03) jours ouvrables suivant la réception de la réponse négative de l'autorité contractante,
- en cas de rejet implicite du recours gracieux, le requérant doit saisir le CRD dans **les trois (03) jours ouvrables** à compter de l'expiration du délai de trois (03) jours ouvrables qui étaient impartis à l'autorité contractante pour répondre au recours gracieux.

De ce qui précède, il résulte que le point de départ des délais de procédures organisées par les articles 89 et 90 CMP14 doit être un jour ouvrable.

B. Application des textes dans l'affaire Delgas Assainissement

3. En vue de l'identification des points de départ des délais, la décision du CRD dans l'affaire Delgas Assainissement peut être transcrite ainsi qu'il suit

Mardi 19 février 2019, notification au requérant du rejet de son offre. À compter de cette date, il dispose de cinq (05) jours francs et ouvrés pour introduire un recours gracieux.

Jeudi 21 février 2019, il introduit son recours gracieux. Il n'a utilisé qu'un jour franc sur les cinq (5) auxquels il avait droit. L'autorité contractante disposait de trois (03) jours ouvrables pour répondre.

- **Lundi 25 février 2019** l'autorité contractante rejette expressément son recours gracieux. Elle disposait de trois (03) jours ouvrables pour répondre ; elle a répondu dans les délais. À partir de cette date le requérant disposait de trois (03) jours ouvrables pour saisir le CRD.

Mercredi 27 février 2019, le requérant saisit le CRD ; il est dans les délais ; son recours est recevable.

III. La computation des délais

La computation des délais fixés dans les articles 89 et 90 CMP14 soulève deux problèmes. Celui du samedi, pour savoir s'il constitue un jour ouvrable ou ouvré, et celui du caractère franc des délais.

4. Le CRD considère le samedi comme ouvrable ou ouvré. C'est ce qui résulte de sa décision n° 149 du 31 octobre 2018. Dans cette affaire, le requérant dénonçait les irrégularités qui auraient entaché la procédure de passation de marché. Il dénonçait entre autres, **«la publication de l'avis d'attribution provisoire du marché effectuée le samedi 29 septembre 2018 jour ouvrable»**. Le CRD rejette ce moyen en motivant ainsi sa décision.

Qu'au surplus, s'agissant des « irrégularités » soulevées par le requérant, il convient de rappeler que l'autorité contractante s'est conformée à la réglementation en procédant à la publication de l'avis d'attribution provisoire un samedi, étant jour ouvrable, de même qu'il importe de relever que cette formalité a permis au requérant, en l'absence de notification, d'être informé du rejet de son offre ; (ARMP/CRD 149 du 31 Octobre 2018 Sénégalaise d'équipement, de travaux et de services (SETS).

Ce n'est pas la publication de cet avis un samedi qui soulève des difficultés ; cet avis aurait pu être publié même un dimanche, dès lors que le point de départ du délai pour le contester serait un jour ouvrable. La difficulté tient au fait que selon cette décision, le samedi serait un jour ouvrable. Cette affirmation est contraire à une jurisprudence établie en sens contraire,

C'est le cas, dans l'affaire ABN dans laquelle la Cour suprême déclare

Considérant cependant que le recours gracieux de la société ABN a été rejeté par l'autorité contractante par lettre du 5 Août 2016 ; Que cette date tombant un vendredi, la requérant disposait donc des deux jours ouvrables, les lundi 8 et mardi 9 Août, pour déposer son recours devant le CRD, étant entendu que les samedi 6 et dimanche

7 étaient des jours non ouvrables ; (CS. arrêt n°8 février 2008, Société Africaine Business Net Work ABN).

C'est également le cas dans l'affaire Société DIOKAR Holding Group dans laquelle l'on peut lire.

Considérant que la société Diokar Holding Group a reçu notification de la réponse de l'autorité contractante le mardi 22 mars 2016 ; Que le point de départ du délai est le mercredi 23 mars 2016 et son terme le mardi 29 mars 2016, compte tenu de ce que les samedi 26, dimanche 27 et lundi de Pâques 28 mars 2016 étaient des jours non ouvrables ; (CS. arrêt n° 59 du 23 novembre 2017, la société DIOCAR HOLDING GROUP).

Une harmonisation des textes et des pratiques en concertation avec l'Administration du travail permettrait une compréhension commune et partagée de la notion de « jour ouvrable » en droit sénégalais.

5. Le caractère franc constitue le mode normal de computation des délais de procédure. Le jour franc et le jour ouvrable ne coïncident pas ; ils ne sont pas superposables. Ainsi ; le jour franc s'étend de zéro heure à 23h59, tandis que le jour ouvrable ou ouvré, c'est la partie du jour franc dans laquelle se déroulent les activités professionnelles. Il couvre en général la période de 8h à 18h. On s'explique alors les mécanismes de la computation des délais en jours francs.

a) Le premier jour, jour de l'évènement et de la notification des actes, appelé aussi **dies a quo** est un jour ouvrable. C'est le jour des notifications et significations, des convocations, des réunions des instances de tous les évènements qui déclenchent le **point de départ** des délais. **Ce dies a quo** point de départ du délai, n'est pas pris en compte dans sa computation en jours francs. Le 1^{er} jour franc commencera à zéro heure, suivant le premier jour ouvrable.

b) Si pour une raison quelconque l'évènement générateur de la procédure s'est produit un jour férié ou un jour non ouvrable, le point de départ du délai (le **dies a quo**) sera le prochain jour ouvrable et le délai franc commencera à zéro heure le lendemain de ce premier jour ouvrable.

c) Pour les mêmes raisons, le terme du délai franc, le dernier jour ouvrable aussi appelé **dies a quem**, ne compte pas, le dernier jour franc commencera à zéro heure, à la fin du dernier jour, et se terminera le lendemain à 23h 59.

d) Si pour une raison quelconque, le dernier jour n'était pas ouvrable, le délai sera prorogé jusqu'au tout prochain jour ouvrable et expirera le lendemain de ce jour ouvrable à 23h 59.

6. Les articles 89 et 90 CMP14 ne sont pas cohérents sur la prescription des délais. En effet,

L'alinéa 3 de l'article 89 prescrit que le recours gracieux doit être exercé dans un délai de **cinq (05) jours francs et ouvrés**.

L'alinéa 4 du même article 89 prescrit que l'autorité contractante dispose de **trois (03) jours ouvrables** pour répondre au recours gracieux.

L'alinéa 1^{er} de l'article 90 prescrit que le requérant dispose de **trois (03) jours ouvrables** pour saisir le CRD.

Au regard de ce texte, le caractère franc de délai ne s'appliquerait pas au délai de réponse au recours gracieux, ni au délai de saisine du CRD en cas de rejet du recours gracieux. Dans son arrêt n° 59 du 23 novembre 2017 la Cour suprême a décidé comme suit, que le délai de trois (03) jours prescrit à l'alinéa 1^{er} de l'article 90 CMP est un délai franc

Considérant que selon les dispositions de l'article 90 du Code des Marchés publics, en l'absence d'une suite favorable à son recours gracieux, le requérant dispose de trois jours ouvrables à compter de la réception de la réponse de l'autorité contractante pour présenter un recours au Comité de Règlement des Différends ;

Considérant que ce délai de trois jours ouvrables est franc ; (CS n° 59 du 23 novembre 2017).

Dans sa décision n° 85 du 20 juin 2018, le CRD a fait application de cet arrêt de la Cour suprême. Dans cette affaire, l'autorité contractante soutenait la forclusion du requérant sur les délais d'exercice du recours contentieux devant le CRD conformément à l'article 90 CMP14. Le requérant avait reçu la réponse négative à son recours gracieux le mardi 15 mai 2018. Il aurait dû saisir le CRD dans les trois (3) jours, c'est-à-dire jusqu'au vendredi 18 mai 2018. Au lieu de cela, il n'a déposé son recours que le mardi 22 mai 2018. Il serait donc forclos. Le CRD rejette cet argument en ces termes

Considérant que la Cour suprême, dans son arrêt n° 59 du 23 novembre 2017, a retenu, à l'occasion d'un recours en annulation contre une décision de CRD, que le délai prévu à l'article 90 du Code des marchés publics doit être computé en jours ouvrables et francs

Que le CRD a donc fait une bonne application de la loi lors de l'examen de la recevabilité du recours des ETS APS ;

(ARMP/CRD 085 du 20 Juin 2018 Entreprise Établissements ETS).

Bien que cela n'apparaisse pas dans la décision, le détail de la computation de ce délai franc s'établit ainsi :

Mardi 15 mai 2018: le requérant reçoit une réponse négative à son recours gracieux. Il dispose de trois jours francs et ouvrables pour saisir le CRD. Le mardi 15 mai 2018, jour de notification, ne compte pas. Il se termine à 23h59.

Mercredi 16 mai 2018, de zéro heure à 23h59, c'est le point de départ de la computation du délai ; c'est le **dies a quo** ; il ne compte pas

1^{er} jour franc jeudi 17 mai 2018 de zéro heure à 23h59

2^e jour franc vendredi 18 mai 2018 de zéro heure à 23h59

Samedi 19 mai 2018 zéro heure à dimanche 20 mai 2018 23h59 ne comptent pas ; ils ne sont pas ouvrables.

3^e jour franc, le lundi 21 mai 2018 de zéro heure à 23h59. C'est le terme du délai ; le dernier jour ; le **dies a quem** ; il ne compte pas

Le délai de trois jours francs expire le mardi 22 mai 2018 à 23h59.

7. La jurisprudence de la Cour suprême visant à rationaliser la computation des délais de procédure, appelle deux observations.

7.1 Les délais de procédure sont fixés par le Code des Marchés publics. En ses articles 89 et 90, porté par un décret. La Cour suprême n'a pas compétence pour modifier les décrets. Elle peut les annuler entièrement ou partiellement pour illégalité. L'illégalité suppose la violation d'une disposition du décret attaqué en vigueur. En procédant à la computation des délais, sans tenir compte de leur caractère franc, l'ARMP/CRD ne viole aucune disposition de l'article 90 du Code des Marchés publics. S'il est normal que la Cour suprême crée un principe général selon lequel les délais fixés par l'article 90 CMP14 sont des délais francs, il paraît excessif que, dans l'arrêt même où elle crée ce principe, elle sanctionne le Régulateur des Marchés publics pour avoir violé ce principe qui n'existait pas au moment où il prenait sa décision.

7.2 Les articles 89 et 90 CMP14 s'inscrivent dans la logique de l'efficacité managériale. Cinq (05) jours francs et ouvrables étaient impartis au candidat pour saisir la personne responsable de son recours gracieux. Ce délai lui donne le temps de s'assurer du bien-fondé de sa requête, et oblige la personne responsable du marché de suspendre la procédure de la passation des marchés. L'extension du caractère franc au délai de saisine du CRD allonge la procédure, dans un contexte où certains acteurs de la commande publique se plaignent de la longueur de la procédure de passation des marchés publics. On constate là un exemple de conflit entre la rationalité managériale et la rationalité juridique.

IV. État de la jurisprudence de l'ARMP/CRD

La jurisprudence du CRD des années 2018 et 2019 révèle un nombre important de rejets de recours pour les motifs de violation, la méconnaissance ou de mauvaise application des délais prescrits par les articles 89 et 90 CMP14. Saisi d'un recours, le CRD

- Vérifie la régularité du recours gracieux : son existence ; le cas échéant son effectivité (*ARMP/CRD 029 du 14 Mars 2018 Sirmel*).
- Vérifie la bonne application des délais, pour s'assurer notamment qu'il n'est pas tardif. Toute irrégularité au niveau du recours gracieux entraîne l'irrecevabilité du recours.

- Vérifie le respect des délais de saisine du CRD et rejette le recours si la saisine est anticipée ou tardive.

L'état de cette jurisprudence pour les années 2018 et 2019 se présente comme suit :

8. Recours gracieux

8.1 Rejet pour absence du recours gracieux

Le recours gracieux est absent ou réputé absent et le recours irrecevable dans les cas suivants

a) Aucun document ne révèle l'existence du recours gracieux
(ARMP/CRD 060 du 25 Avril 2018 GARECGO)

b) La demande de prorogation de délai n'équivaut pas à un recours gracieux et n'en tient pas lieu (ARMP/CRD 167 du 05 Décembre 2018 Cahinei Symbiose Office)

c) La saisine directe du CRD d'un recours gracieux est constitutive d'absence de recours gracieux (ARMP/CRD 023 du 28 Février 2018 Cayor Techno Plus) (ARMP/CRD 178 du 28 Novembre 2018 Groupe Sen Ingénierie).

d) Le recours gracieux est tardif dans les circonstances suivantes. Le requérant a saisi l'autorité contractante d'un recours gracieux le 5 octobre 2018. L'autorité contractante n'a pas répondu et le 18 octobre 2018, a publié l'avis d'attribution provisoire du marché. Le 19 octobre 2018 il saisit le CRD. Il aurait dû saisir le CRD après le silence gardé, suite à son recours gracieux ; ou alors tenter un autre recours gracieux après la publication de l'avis d'attribution provisoire du marché
(ARMP/CRD 147 du 31 Octobre 2018 Sénégalaise de l'Automobile).

e) La saisine du CRD n'est pas précédée d'un recours gracieux
(ARMP/CRD 184 du 11 Décembre 2019 Société Industrielle Sahélienne de Mécanique de Matériels Agricoles (SISMAR)).

8.2 Rejet pour tardivité du recours gracieux

Ont été rejetés pour tardivité

a) Recours tardif après rejet implicite du recours gracieux
(ARMP/CRD 133 du 03 Octobre 2018 Contechs)

b) Recours gracieux et contentieux tardifs (ARMP/CRD 150 du 07 Novembre 2018 Astone Sénégal)

c) Recours gracieux tardif (ARMP/CRD 035 du 27 Février 2019 Qualitec MCS) ; (ARMP/CRD 047 du 20 Mars 2019 Probatis Sénégal)

9. Recours contentieux devant le CRD

9.1 Rejet pour saisine prématurée

Recours introduit avant expiration du délai du recours gracieux (*ARMP/CRD 083 du 13 Juin 2018 Société Neurotech*) ; (*ARMP/CRD 086 du 27 Juin 2018 Etablissements Galaye Ndiaye*) ; (*ARMP/CRD 046 du 13 Mars 2019 Entreprise Grands Travaux et Services (GTS)*) (*ARMP/CRD 051 du 20 Mars 2019 Nariel*) ; (*ARMP/CRD 174 du 06 Novembre 2019 C'operative des Gros Porteurs du Senegal (COOP-GPS)*).

9.2 Rejets pour saisine tardive du CRD

Le requérant a saisi le CRD après expiration des trois(03) jours ouvrables et francs suivant le rejet exprès ou implicite de son recours gracieux. (*ARMP/CRD 102 du 25 Juillet 2018 Société Biolye Pharma D'Ontario (CANADA)*) ; (*ARMP/CRD 144 du 24 Octobre 2018 Entreprise Sen Buti*) (*ARMP/CRD 166 du 05 Décembre 2018 Focus Audit et Entreprise*) (*ARMP/CRD 012 du 23 Janvier 2019 Sencom*) ; (*ARMP/CRD 047 du 20 Mars 2019 Probatiss Sénégal*) (*ARMP/CRD 082 du 15 Mai 2019 Sarl Eccotra*) ; (*ARMP/CRD 092 du 29 Mai 2019 Iligh tech Energy*) ; (*ARMP/CRD 110 du 17 Juillet 2019 Madame Wolette Thiam*) (*ARMP/CRD 154 du 02 Octobre 2019 Entreprise Office Consommables*) ; (*ARMP/CRD 162 du 09 Octobre 2019 Société China Raily Seventh*)

9.3 Cas particulier

On a observé le cas particulier de deux recours simultanés, concomitants : le requérant a saisi en même temps l'autorité contractante et le CRD. Dans cette espèce, le recours a été rejeté pour n'avoir «**pas respecté les délais exigés**». Le CRD n'a pas indiqué si le recours était prématuré ou tardif (*ARMP/CRD 159 du 14 Novembre 2018 Tpro-Plus Sénégal*).



Le nombre relativement élevé de violations des règles de procédure des articles 89 et 90 du CMP14 invite à poursuivre les actions de sensibilisation sur cette question centrale de la passation des marchés publics.

4

**Organisation de la Commande publique
Constitution des Commissions des marchés
et des cellules de passation des marchés
CMP14 Art. 2 ; 35**

1^{er} Espèce

**Programme de Développement national de la
Microfinance islamique au
Sénégal (PROMISE)**

DÉCISION N° 017/18/ARMP/CRD/DEF DU 14 FÉVRIER 2018

PAR CES MOTIFS :

- 1) *Constate que le Programme de Développement national de la Microfinance Islamique au Sénégal (PROMISE) n'a pas le statut d'autorité contractante au sens de l'article 2 du Code des Marchés publics ;*
- 2) *Dit que la réglementation ne permet pas au Programme de Développement national de la Microfinance Islamique au Sénégal de constituer une commission des marchés et une cellule de passation des marchés ;*
- 3) *Constate, toutefois, que l'envergure des marchés du Programme de Développement national de la Microfinance Islamique au Sénégal justifie la mise en place d'une commission et d'une cellule des marchés ;*
- 4) *Constate que le Ministère de l'économie solidaire et de la Microfinance ne s'oppose pas à la demande du Programme de Développement national de la Microfinance Islamique au Sénégal pour la mise en place d'une commission et d'une cellule des marchés ;*
- 5) *Dit qu'au vu des missions du Programme de Développement national de la Microfinance Islamique au Sénégal, la mise en place d'une commission et d'une cellule des marchés facilite l'atteinte des objectifs qui lui sont assignés par l'État ;*
- 6) *Dit que la cellule de passation des marchés est un service dont la mise en place relève du texte portant organisation et fonctionnement du service Programme de Développement national de la Microfinance Islamique au Sénégal ;*
- 7) *Autorise, à titre exceptionnel, le Programme de Développement national de la Microfinance Islamique à constituer une commission des marchés pour une durée d'un (1) an ;*
- 8) *Dit que les copies des actes de nomination et des déclarations de prise de connaissance de la charte de transparence et d'éthique en matière des marchés publics signées par les membres de la commission et de la cellule*

doivent être communiquées à la Direction centrale des Marchés publics et à l'Autorité de Régulation des Marchés publics ;

2^e Espèce

Ministre du Pétrole et des Énergies

DÉCISION N° 130/18/ARMP/CRD/DEF DU 26 SEPTEMBRE 2018

Considérant que « GES- PETROGAZ », est créée par arrêté pris conjointement par le Ministre de l'Économie, des Finances et du Plan et le Ministre du Pétrole et des Énergies le 09 mai 2018 sous le numéro 009760 fixant les règles d'organisation et de fonctionnement de « GES- PETROGAZ » ;

Considérant que l'article premier (1') de l'arrêté stipule que l'Unité d'Exécution et de Gestion du Comité d'Orientation stratégique du Pétrole et du Gaz, dénommée «GES-PETROGAZ» est chargée de la mise en œuvre des délibérations du Comité d'Orientation stratégique COS-PETROGAZ. Elle est placée sous la tutelle du Ministère du pétrole et du gaz ;

Considérant que dans le même article, l'arrêté précise que l'unité est chargée, notamment :

de suivre en rapport avec le secrétariat permanent de « COS- PETROGAZ », la mise en œuvre des stratégies pour la promotion et le développement de projets pétroliers et gaziers,

de suivre toutes les études relatives aux réserves de pétrole et de gaz naturel ainsi que les gisements à développer ;

d'assurer la coordination et le suivi de la mise en œuvre de tous les documents stratégiques, programmes et plans d'action, en relation avec les acteurs publics et privés du secteur ;

Considérant que l'arrêté ne lui confère pas la personnalité morale ;

Qu'à cet égard, « GES- PETROGAZ », étant dépourvue de la personnalité morale, n'a pas la qualité d'autorité contractante et ne peut en conséquence mettre en place ses propres cellule de passation des marchés et commission de marchés ;

Considérant, toutefois, que l'aide-mémoire du partenaire technique et financier, relatif à la mission de soutien aux négociations dans le cadre des projets gaziers et renforcement des capacités institutionnelles, souligne que l'établissement du premier inventaire des ressources en pétrole et en gaz oblige l'autorité contractante à se doter des expertises requises pour l'appuyer dans la négociation du développement des productions, dans la planification de l'utilisation des quotas réservés au marché national et le développement des capacités de gestion de ces ressources ;

Considérant qu'en plus, le même arrêté dispose, respectivement aux articles 4 et 5, que le chef de « GES- PETROGAZ » signe les actes et conventions relevant de l'Unité d'exécution et de Gestion et qu'il dispose d'un compte de dépôt ouvert dans les livres du Trésor ;

Considérant qu'il en ressort que « GES- PETROGAZ » est investie d'une mission spécifique d'exécution et de gestion des ressources en pétrole et en gaz ;

Qu'il résulte de ce qui précède, que «GES- PETROGAZ» est régie par des modalités d'administration et de gestion et d'un régime comptable, similaires à

ceux des agences d'exécution ayant la qualité d'autorité contractante au sens de l'article 2 du Code des Marchés publics ;

Qu'en conséquence, il y a lieu, à titre exceptionnel, de permettre à « GES — PETROGAZ » de constituer une commission des marchés et une cellule de passation des marchés pour lui permettre d'exécuter son programme d'acquisition de biens et services en conformité avec la réglementation ;

PAR CES MOTIFS :

- 1) Constate que le Ministère du Pétrole et des Énergies a formulé une demande d'autorisation de mise en place d'une cellule de passation des marchés et une commission de marchés au sein de « GES- PETROGAZ » ;*
- 2) Constate que «GES-PETROGAZ» n'est pas une autorité contractante ;*
- 3) Constate que «GES-PETROGAZ» est régie par des modalités d'administration et de gestion et d'un régime comptable, similaires à ceux des agences d'exécution ayant la qualité d'autorité contractante au sens de l'article 2 du Code des Marchés publics ;*
- 4) Dit qu'il y a lieu, en conséquence et à titre exceptionnel, d'autoriser «GES-PETROGAZ» à mettre en place ses propres organes de passation des marchés ;*

3^e Espèce

**Secrétariat Permanent stratégique du Pétrole et du G
AZ (COS-PETROGAZ)**

**DÉCISION N° 149/19/ARMP/CRD DU 18 SEPTEMBRE
2019**

PAR CES MOTIFS :

- 1) Constate que le COS-PETROGAZ, structure administrative placée sous l'autorité de la Présidence de la République, n'a pas de personnalité juridique ,*
- 2) Constate que ses ressources budgétaires sont inscrites dans le budget de la Présidence de la République et que son manuel de procédures est approuvé par le Président de la République ;*
- 3) Rejette, au regard de ce qui précède, la demande du COS-PETROGAZ de disposer d'une commission et d'une cellule de passation des marchés ;*
- 4) Demande au COS-PETROGAZ de recourir à la Commission et à la Cellule de passation des marchés de la Présidence de la République pour passer ses marchés*

Commentaires

Les trois décisions susvisées ont donné l'occasion au CRD de préciser les modalités d'application des **articles 2 et 35 du CMP14, relatifs à la constitution des commissions des marchés et des cellules de passation des marchés** des autorités contractantes

Dans la 1^{ère} espèce, décision n° 17/18 du 14 février 2018, le CRD constate que la réglementation ne permet pas au Programme de Développement national de la Microfinance Islamique au Sénégal (PROMISE), qui sollicite la mise en place d'une commission des marchés (CM) et d'une cellule de passation des marchés (CPM), de disposer de ces organes de passation des marchés, parce qu'il n'a pas la qualité d'autorité contractante au sens de l'article 2 du CMP14. A cela s'ajoute que la mise en place d'une cellule de passation des marchés relève du texte portant organisation et fonctionnement du PROMISE. Toutefois, en raison de l'envergure des marchés du PROMISE, le CRD l'autorise à mettre en place une commission des marchés pour une durée de six (06) mois.

Dans la 2^e espèce, décision 130/18 du 26 septembre 2018, le CRD décide que le GES-PETROGAZ entité placée sous la tutelle du Ministre du Pétrole et des Énergies. n'est pas une autorité contractante, mais que les modalités de son administration de sa gestion, ainsi que son régime comptable sont similaires à celles des agences d'exécution ayant la qualité d'autorité contractante au sens de l'article 2 du CMP14 ; qu'en conséquence, GES-PETROGAZ est autorisé à mettre en place ses propres organes de passation des marchés.

Dans le 3^e espèce, décision n° 149/19/ du 18 septembre 2019 le CRD rejette la demande de COS-PETROGAZ visant à la mise en place d'une cellule de passation de marché (CPM) et d'une commission des marchés (CM). Le CRD constate que **cette entité est une structure administrative, sans personnalité juridique**, placée sous l'autorité de la Présidence de la République, dont les ressources budgétaires sont inscrites dans le budget de la Présidence de la République. Le CRD demande donc au COS-PETROGAZ de recourir à la cellule de passation des marchés et la commission des marchés de la Présidence de la République..

A la lumière de ces décisions, trois questions sont abordées ;

- La motivation et le contexte des décisions susvisées
- La notion d'autorité contractante en rapport avec la mise en place des organes de passation des marchés publics
- La jurisprudence pragmatique du CRD et ses limites

I. Motivation et enjeux

1. Le Programme de développement national de la Microfinance islamique (PROMISE), est une entité non personnalisée, placée sous la tutelle du Ministre chargé de la microfinance. Il sollicite du CRD l'autorisation de constituer sa propre Commission de marchés et sa propre cellule de passation de marché, comme le prescrit l'article 35 du CMP14.

Dans sa décision, 1^{er} espèce ci-dessus le CRD rappelle qu'au regard de la réglementation, seule une entité ayant **la qualité d'autorité contractante** au sens de l'article 2 du CMP14 peut constituer sa propre commission de marché et propre cellule de passation de marchés. Le CRD poursuit :

«Qu'il s'ensuit que dans le cas d'espèce, le PROMISE n'a pas le statut d'autorité contractante au sens de l'article 2 du Code des Marchés publics susvisé ; Que dans ces conditions, la réglementation ne permet pas à cette entité de disposer en son sein d'une commission et d'une cellule des marchés, puisqu'elle l'astreint à s'appuyer sur les organes du Ministère de l'Économie solidaire et de la Microfinance ;

Dans ces conditions, l'autorisation de constituer une commission des marchés et une cellule de passation des marchés ne peut être accordée à PROMISE que **par dérogation** à la réglementation, à **titre exceptionnel**.

1.1. Pour la constitution de la commission des marchés, le CRD

recherche si de telles conditions sont réunies, et en arrive aux constatations ci-après :

- a) L'arrêté n° 21688 du 7 décembre 2017 portant création et fixant les règles de fonctionnement du PROMISE dote cette entité d'un Conseil d'orientation, d'un Comité de gestion et d'une unité de gestion
- b) L'unité de gestion, organe exécutif du Programme comprend un personnel permanent de plus de vingt (20) agents, dont un spécialiste en passation de marchés
- c) L'objectif global du Programme est d'améliorer le revenu des bénéficiaires en leur permettant d'accéder à des services financiers islamiques adaptés sur l'ensemble du territoire.
- d) *«Qu'à cet égard, l'atteinte des objectifs assignés au PROMISE et la réalisation de ses missions requièrent une mise en œuvre diligente des procédures de passation des marchés publics à travers une réactivité et une efficacité des organes chargés de dérouler les procédures.»*
- e) Par lettre du 12 janvier 2018, le Ministre de l'Économie solidaire et de la microfinance a sollicité la validation de la mise en place de la commission des marchés et de la cellule de passation des marchés pour ce programme. Le ministre de tutelle ne s'oppose donc pas à cette demande
- f) La commission des marchés est constituée pour une durée d'un an. Étant donné qu'une **«dérogation ne peut être accordée que pour une durée limitée»**, elle serait justifiée pour la mise en place d'une commission des marchés.

Par ces motifs, décide le CRD : *«Autorise, à titre exceptionnel, le Programme de Développement national de la Microfinance Islamique à constituer une commission des marchés pour une durée d'un (1) an » ;*

1.2. Pour la constitution de la cellule de passation des marchés, le CRD est réservé. Dans le dispositif de la décision, on ne trouve aucune allusion à cette question. C'est dans la motivation que l'on peut lire : **«Considérant que la cellule de passation des marchés est un service permanent à la différence de la commission dont la composition est fixée par le Code des Marchés publics pour une durée d'un an»**.

La cellule de passation des marchés est en principe instituée par le texte qui organise le service, comme une structure permanente dudit service.

2. Dans sa décision, 2^e Espèce ci-dessus, le CRD examinait une demande du Ministre du Pétrole et des Énergies sollicitant la constitution **d'une commission des marchés et d'une cellule de passation des marchés propres au GES-PETROGAZ** : Pour répondre à la demande, le CRD procède en deux étapes.

2.1. Le CRD recherche la nature juridique et le statut du GES

PETROGAZ et constate ce qui suit :

- a) Le GES-PETROGAZ est créé par un arrêté conjoint du Ministre de l'Économie et des Finances et du Ministre du Pétrole et des Énergies en date du 9 mai 2018
- b) C'est une Unité d'Exécution et de gestion du Comité d'Exécution et de gestion du Comité d'Orientation Stratégique du Pétrole et du Gaz (COS-Petrogaz,
- c) C'est l'organe exécutif du COS-Petrogaz, chargé de la mise en œuvre de ses délibérations
- d) L'unité est placée sous la tutelle du Ministre du Pétrole et du GAZ
- e) Elle n'est pas dotée de la personnalité morale.

Sur ce premier point, le CRD conclut : **«Qu'à cet égard, « GES-PETROGAZ », étant dépourvue de la personnalité morale n'a pas la qualité d'autorité contractante et ne peut en conséquence mettre en place ses propres cellules de passation des marchés et commission de marchés ;»**

2.2. Le CRD recherche les justificatifs pour accorder une dérogation au requérant et constate ce qui suit

- a) Le chef du GES-Petrogaz signe les convocations et actes de cette entité et dispose d'un compte de dépôt ouvert dans les livres du Trésor
- b) L'Unité est investie d'une mission spécifique d'exécution et de gestion des ressources en pétrole et en gaz.

Le CRD conclut : «Qu'il résulte de ce qui précède, que « GES-PETROGAZ » est régie par des modalités d'administration et de gestion et d'un régime comptable, similaire à ceux des agences d'exécution ayant la qualité d'autorité contractante au sens de l'article 2 du Code des Marchés publics».

Au regard de ces constats, le CRD autorise le GES-Petrogaz à mettre en place **« ses propres organes de passation de marchés. »**

Ce dispositif indique que l'autorisation porte aussi bien sur la commission des marchés que sur la cellule de passation de marchés.

3. Le Secrétaire Permanent du **Comité d'Orientation stratégique du Pétrole et du GAZ (COS-Petrogaz)** demandait au CRD l'autorisation de mettre en place une cellule de passation des marchés et une commission de passation de marchés spécifiques à cette entité. Dans sa décision ci-dessus 3^e espèce, le CRD rejette cette demande pour les motifs ci-après

Considérant, que le COS-PETROGAZ est une structure administrative placée sous la tutelle de la Présidence de la République ;

Que les ressources budgétaires nécessaires à son fonctionnement sont inscrites dans le budget de la Présidence de la République ;

Que son manuel de procédures est approuvé par le Président de la République ;

Qu'il s'ensuit que le COS-PETROGAZ n'a donc pas de personnalité morale et n'est pas une autorité contractante au sens de l'article 2 du Code des Marchés publics ;

Qu'au regard de ce qui précède, il y a lieu de rejeter la demande du COS-PETROGAZ de disposer d'une Commission et d'une cellule propres de passation des marchés, ce dernier devant recourir à la Commission et à la Cellule de passation des marchés de la Présidence de la République pour passer ses marchés.

4. Toute la jurisprudence du CRD en matière de **constitution, de mise en place** des organes de passation des marchés publics, est structurée comme les décisions susvisées. Ainsi,

- a) Il s'agit toujours d'entités dont certaines ne remplissent pas les conditions pour constituer ou mettre en place les organes propres de passation des marchés.
- b) Le CRD le constate systématiquement et l'inscrit dans le dispositif de ses décisions.
- c) Si le CRD estime que l'entité concernée ne peut pas se doter de ces organes, il le constate, motive sa décision et rejette la demande dont il est saisi. C'est le cas pour la décision de la 3^e espèce ci-dessus concernant le COS-Petrogaz. L'entité concernée est alors invitée à utiliser les organes de passation de sa structure de tutelle.

d) Dans le cas où le CRD dispose de justificatifs suffisants pour autoriser l'entité, par dérogation, à constituer ces organes, il motive sa décision dans ce sens et autorise leur mise en place ou leur constitution. L'autorisation porte plus fréquemment sur la mise en place des commissions des marchés ; elle n'excède pas un an.

5. Les enjeux de la constitution des commissions des marchés sont déterminants pour l'efficacité de la commande publique. Ce sont les commissions des marchés qui ouvrent les plis des offres, vérifient leur conformité aux documents des marchés, apprécient la qualification des candidats, évaluent des offres et procèdent au classement des candidats.

On s'aperçoit ainsi que tous les progrès de la réglementation, ainsi que les efforts de la régulation pour garantir la concurrence et la transparence peuvent être anéantis par une commission des marchés incompétente, ou mal intentionnée. Les nombreuses annulations des attributions provisoires des marchés s'expliquent par des manquements des commissions des marchés à l'égard de la réglementation ou des documents des marchés. Ces manquements **rejaillissent sur l'autorité contractante** qui pourtant, n'est qu'une partie prenante de la commission des marchés. C'est ainsi que **les recours ne sont pas dirigés contre les Commissions des marchés, mais contre l'autorité contractante.**

À cela s'ajoute que, le nombre élevé de demandes de dérogations pour la constitution des commissions des marchés amène à s'interroger sur l'interprétation de la notion **d'autorité contractante.**

II. La notion d'autorité contractante en rapport avec la mise en place des organes de passation des marchés publics

6. La mise en place des organes de passation des marchés est réglementée comme suit par l'article 35 CMP14.

Article 35 :

Au niveau de chaque Autorité contractante, sont mises en place une commission des marchés chargées de l'ouverture des plis, de l'évaluation des offres et attribution provisoire des marchés ainsi qu'une cellule de passation des marchés chargées de veiller à la qualité des dossiers de passation des marchés ainsi qu'au bon fonctionnement de la commission des marchés, dans les conditions fixées par arrêté du Ministre chargé des Finances après avis de l'Organe chargé de la régulation des marchés publics.

L'autorité contractante est ainsi définie par l'article 4.5 du CMP14 : **«Autorité contractante : personne morale, service et organisme visés à l'article 2 du présent décret»**.

L'article 2 du CMP14 auquel il est renvoyé mérite d'être relu, notamment en ce qui concerne son paragraphe 1. Il est ainsi conçu.

Article 2 :

1. Les dispositions du présent décret s'appliquent aux marchés passés par les autorités contractantes suivantes :

- a) l'État, y compris ses services déconcentrés et les organismes non dotés de la personnalité morale placés sous son autorité ;*
- b) les collectivités locales, y compris leurs services déconcentrés et les organismes non dotés de la personnalité morale, placés sous leur autorité, ainsi que les groupements mixtes et les établissements publics locaux ;*
- c) les établissements publics ;*
- d) les agences ou organismes, personnes morales de droit public ou privé, autres que les établissements publics, sociétés nationales ou sociétés anonymes à participation publique majoritaire, dont l'activité est financée majoritairement par l'État ou une collectivité locale et s'exerce essentiellement dans le cadre d'activités d'intérêt général ;*
- e) les sociétés nationales et les sociétés anonymes à participation publique majoritaire ;*
- f) les associations formées par les personnes visées aux paragraphes a) à e) ci-dessus.*

Ces textes appellent les observations ci-après :

- a) L'autorité contractante n'est pas exclusivement une personne morale, elle n'a pas nécessairement une personnalité juridique. C'est le cas des services déconcentrés et **des organismes non dotés de la personnalité morale** placés sous l'autorité de l'État, ou des collectivités territoriales.
- b) Ces organismes non dotés de la personnalité morale tiennent cette qualité **du décret lui-même** et non pas d'une délégation de leur administration de rattachement.
- c) L'article 2, 1d régit **«Les organes ou organismes, personnes morales de droit public ou privé»** C'est dans cette catégorie d'autorités contractantes que se trouvent les Fonds, Programmes, Bureaux d'études, Agences. Le CRD lit ce texte comme signifiant que tous les organismes concernés doivent avoir la personnalité morale. C'est la raison pour laquelle il privilégie ce critère pour reconnaître ou dénier la qualité d'autorité contractante à des organismes non personnalisés tels que certains Programmes, des Fonds et d'une manière générale des entités

qui n'ont pas de rattachement administratif avec l'Administration centrale ou décentralisée.

- d) C'est un dysfonctionnement de l'article 2.1d de n'avoir pas visé les organismes non personnalisés parmi les autorités contractantes. Il appartient au Régulateur des marchés publics de rétablir l'équilibre par une jurisprudence très ouverte à l'égard de tels organismes. La qualité d'autorité contractante ne doit leur être refusée que dans des cas exceptionnels.
- e) Sous ce rapport, le CRD semble avoir fait preuve d'une sévérité particulière dans les affaires GES-Petrogaz et COS-Petrogaz. Les deux entités sont des démembrements non personnalisés de l'État, l'un rattaché au Ministère de l'Économie et des Finances, l'autre à la Présidence de la République. L'article 2. 1a du CMP14 leur confère la qualité d'autorité contractante de manière indiscutable. Il semble donc excessif d'avoir reconnu cette qualité à GES-Petrogaz et de l'avoir déniée à COS-Petrogaz.

III. La jurisprudence pragmatique du CRD et ses limites

7. Le CRD a traité la question de la mise en place des organes de passation des marchés avec souplesse et pragmatisme. Toutefois il ne s'est pas donné une ligne directive, une **«doctrine jurisprudentielle»**. De ce fait, ses décisions laissent l'impression d'une **jurisprudence de cas d'espèces** : elle donne l'impression de **décider au cas par cas**, avec comme conséquences le risque de contradictions.

8. L'impression d'une jurisprudence au cas par cas est confortée lorsqu'on examine les décisions du CRD **par thématiques**. Ainsi, pour la même thématique, le Régulateur des marchés publics, tantôt autorise la création des commissions des marchés, tantôt rejette la demande présentée à cet effet, sans que, **dans plusieurs cas, les justifications soient convaincantes**. Les illustrations de ce phénomène sont les suivantes.

a) Les Fonds d'intervention

L'autorisation de mise en place d'une Commission des marchés est refusée au Fonds d'Entretien Routier Autonome (FERA) (*ARMP/CRD 025 du 28 Février 2018 Fonds D'entretien Routier Autonome (FERA)*). L'autorisation est accordée pour le Fonds d'Intervention de l'Inspection générale d'État (IGE) (*ARMP/CRD 007 du 16 Janvier 2019 Société Ecorel*).

b) Les Programmes

L'autorisation est accordée au Programme d'Urgence de Développement communautaire (PDUC) (*ARMP/CRD 087 du 22 Mai 2019 Programme d'Urgence de Développement Communautaire (PUDC)*) ; au Programme de Développement national de la microfinance (PROMISE) (*ARMP/CRD 020 du 06 Février 2019 Programme de Développement National de la Microfinance*.)

L'autorisation est refusée au Projet d'Appui Institutionnel à la mobilisation des ressources et à l'attractivité des investissements (PAIMRAI) (*ARMP/CRD 066 du 17 Avril 2019 Office National de L'Assainissement du Sénégal (ONAS)*). Elle est aussi refusée au Programme national des domaines Agricoles (PRODAC)

(ARAIP/CRD 001 du 02 Janvier 2019 Programme National des Domaines Agricoles (PRODAC)). Il est vrai que dans ce cas, le PRODAC avait déjà bénéficié des autorisations par dérogation pendant trois (03) années consécutives. Toutefois, cela n'est pas une justification satisfaisante ; en effet, on ne peut pas reprocher à cet organisme de n'avoir pas profité de ce délai pour se **transformer en autorité contractante**. Un organisme non personnalisé le reste, tant qu'un texte n'a pas modifié son statut.

c) Divers organismes non personnalisés

Ont été autorisés à constituer une Commission des marchés : le Bureau d'enquête et d'analyse pour la sécurité de l'aviation civile (BEA) (ARMP/CRD 074 du 02 Mai 2019 Bureau d'Enquête et d'Analyse Pour la Sécurité de L'Aviation Civile (BEA)), l'unité de Gestion du Projet PARIIS (UGP) (ARMP/CRD 137 du 10 Octobre 2018 Ministère de l'Agriculture et de l'Équipement) ; l'Agence nationale des chemins de Fer (ANCE) ; (ARMP/CRD 026 du 13 Février 2019 Agence Nationale des Chemins de Fer (ANCF)) ; le GES-Petrogaz (ARMP/CRD 130 du 26 Septembre 2018 Ministère du Pétrole et des Énergies)

N'ont pas été autorisés, la constitution d'une Commission des marchés réservée aux demandes de renseignements et de prix à compétition ouverte ou restreinte. Ce refus est tout à fait justifié ; il n'existe pas de commissions de marchés dédiés à des modes spécifiques de passation des marchés (ARMP/CRD 061 du 25 Avril 2018 Ministère de la Gemme, de la Famille et du Genre) ; le COS-Petrogaz (ARMP/CRD 149 du 18 Septembre 2019 Secrétariat Permanent du Comité d'Orientation Stratégique du Pétrole et du Gaz). Dans cette espèce, l'Administration n'a pas facilité la tâche du CRD. Les GES-Petrogaz, organe d'exécution du COS-Petrogaz est rattaché du Ministère de l'Économie et des Finances, tandis que le COS-Petrogaz qui l'abrite est rattaché à la Présidence de la République ; ce dysfonctionnement peut expliquer que le COS-Petrogaz soit tenté de se doter de ses propres organes de passation des marchés. Il pouvait légitimement y prétendre puisqu'il est autorité contractante selon les critères de l'article 2. la du CMP14.

c) Dans un nombre significatif de cas, le CRD rejette la demande de mise en place d'organes de passation des marchés, et renvoie les organismes demandeurs à s'appuyer sur les organes de leur **Administration de tutelle**. Les principaux cas sont les suivants : ARMP/CRD 002 du 10 Janvier 2018 Haute Autorité du WAQF ; ARMP/CRD 012 du 31 Janvier 2018 Grand Théâtre National Ministère de la Culture ; ARMP/CRD 024 du 28 Février 2018 Société des Mines de Fer du Sénégal Oriental (MIFERSO) ; ARMP/CRD 179 du 12 Décembre 2018 Haute Autorité du WAQF ; ARMP/CRD 048 du 20 Mars 2019 Ministère de L'Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l'Innovation ; ARMP/CRD 103 du 03 Juillet 2019 Secrétariat Exécutif du 8^e Forum Mondial de l'Eau ; ARMP/CRD 185 du 11 Décembre 2019 Haute Autorité du WAQF ; ARMP/CRD 149 du 18 Septembre 2019 ; Secrétariat Permanent du Comité D'Orientation Stratégique du Pétrole et du Gaz.

Organisation de la commande publique Composition des Commissions des Marchés publics

CMP14 Art. 2 ; 36 ; 37.

1^{er} espèce

**Ministère de l'Emploi, de l'Insertion
professionnelle et de l'Intensification
de la main-d'œuvre**

(ARMP/CRD n° 96 18 juillet 2018)

PAR CES MOTIFS :

1) *Constate que le Ministère de l'Emploi, de l'Insertion Professionnelle et de l'Intensification de la Main d'œuvre a mis en place une commission des marchés dans laquelle certains services maîtres-d'œuvre ne sont pas représentés ;*

2) *Constate que le Ministère de l'Emploi, de l'Insertion Professionnelle et de l'Intensification de la Main-d'œuvre est confronté à un déficit de personnel et qui le place dans l'impossibilité de respecter les conditions fixées par la réglementation relative à l'organisation et au fonctionnement des commissions des marchés des autorités contractantes*

3) *Dit que le défaut de fonctionnement de la commission des marchés risque de compromettre l'efficacité de l'action du Ministère de l'Emploi, de l'Insertion Professionnelle et de l'Intensification de la Main-d'œuvre ;*

4) *Autorise, à titre exceptionnel, le Ministère de l'Emploi, de l'Insertion Professionnelle et de l'Intensification de la Main-d'œuvre à mettre en place, pour la gestion 2018, une commission des marchés au sein de laquelle, le Centre d'Initiative pour l'Emploi local, l'Inspection technique et le SAGE seront représentés par une même personne, qui ne doit pas être un agent de l'Inspection technique ;*

2^e espèce

Commune de Gawane

ARMP/CRD n° 84 du 15 mai 2019

PAR CES MOTIFS :

1) *Constate que la commune de GAWANE est une autorité contractante au sens de l'article 2 du Code des Marchés publics ;*

2) *Constate que le Code des Marchés prévoit que la Commission des marchés d'une commune doit comprendre deux (02) représentants composés de l'organe exécutif et, selon le cas, du secrétaire général ou du secrétaire municipal ;*

- 3) *Constate que le poste de secrétaire municipal est vacant au niveau de la commune de GAWANE ;*
- 4) *Constate que cette situation empêche la commune de GAWANE de mener à bien ses procédures de passation des marchés, ce qui est source de blocage pour l'atteinte de ses objectifs de gestion ;*
- 5) *Autorise, à titre exceptionnel, la composition de la commission telle que proposée, en remplaçant le secrétaire municipal par un conseiller municipal, pour l'exercice 2019 ;*
- 6) *Ordonne le retrait du conseiller municipal désigné comme suppléant du percepteur municipal et son remplacement par un agent issu du même service que ce dernier ;*

3^e espèce

Conseil national de Régulation de l'Audiovisuel (CNRA) ARMP/CRD n° 105 du 3 juillet 2019

PAR CES MOTIFS :

- 1) *Constate que le CNRA est une autorité contractante au sens du Code des Marchés publics ;*
- 2) *Dit que le CNRA doit mettre en place une commission des marchés conforme à l'article 2 de l'arrêté n° 00864 du 22 janvier 2015 ;*
- 3) *Constate, toutefois, que le CNRA ne dispose ni de service financier, ni de service approvisionnement ;*
- 4) *Autorise le CNRA, à titre exceptionnel, à mettre en place une commission des marchés composée ainsi qu'il suit :*
 - Titulaires :**
 - le Secrétaire Exécutif, président ;*
 - le responsable informatique ;*
 - une assistante administrative ;*
 - un agent administratif chargé des matières.*
 - Suppléants :**
 - le Directeur de Cabinet du Président (suppléant du Président) ;*
 - un agent du service monitoring ;*
 - le Conseiller du Président spécialiste en NTIC.*

4^e espèce

Société des Infrastructures de réparation navale (SIRN) ARMP/CRD n° 45 du 5 avril 2018

PAR CES MOTIFS :

- 1) *Constate que la SIRN est une autorité contractante au sens de l'article 2.1.e du Code des marchés publics ;*
- 2) *Dit que la SIRN doit se doter d'une commission des marchés composée de quatre (04) membres titulaires et de quatre (04) membres suppléants ;*

- 3) *Constate que le DAF n'est ni présent ni représenté dans la commission des marchés comme le dispose l'arrêté 00864 du 22/01/2015 ;*
- 4) *Constate que le DAF est membre de la cellule de la SIRN ;*
- 5) *Dit que le DAF ou son représentant doit être dans la commission des marchés comme le dispose l'arrêté 00864 du 22/01/2015*
- 6) *Constate, toutefois, que la SIRN dispose d'un personnel réduit ;*
- 7) *Dit que l'inexistence d'une commission des marchés, au sein de l'autorité contractante, risque de compromettre sérieusement son efficacité sur le plan de la commande publique ;*
- 8) *Autorise en conséquence la SIRN à mettre en place une commission des marchés composée de quatre (04) membres titulaires seulement, sans préjudice du représentant du Ministre chargé de la tutelle de la société et du représentant du Contrôleur financier ;*

se espèce

Société des Infrastructures de réparation navale (SIRN)

ARMP/CRD n° 03 du 9 janvier 2019

PAR CES MOTIFS :

- 1) *Constate que la SIRN est une autorité contractante au sens de l'article 2.1.e du Code des marchés publics ;*
- 2) *Dit que conformément à la réglementation, la SIRN doit se doter d'une commission des marchés composée de quatre (04) membres titulaires et de quatre (04) membres suppléants ;*
- 3) *Constate que la SIRN a formé une commission des marchés avec quatre titulaires et trois suppléants ;*
- 4) *Constate que toutefois, la SIRN est confrontée à un déficit réel de personnel de nature à constituer un obstacle réel à la composition régulière de ses organes de passation des marchés ;*
- 5) *Dit que dans la composition de la commission des marchés proposée, la SIRN devra inclure l'un des représentants du contrôleur financier et du ministère de tutelle comme membres titulaires, conformément à l'alinéa 3 de l'article 37 du CMP, sans compter leurs suppléants respectifs ;*
- 6) *Dit qu'il existe un risque réel pour la commission, qui se trouve au complet au titre des membres titulaires, de fonctionner sans suppléants pour les membres issus de l'autorité contractante ;*
- 7) *Constate que la SIRN a affecté trois membres à la cellule privant ainsi la commission des marchés de suppléants ;*

8) *Dit que ce choix comporte de potentiels risques sur le quorum nécessaire à la tenue régulière des sessions de la commission ;*

9) *Recommande que l'un des membres de la cellule soit désigné comme membre suppléant du président à la commission des marchés ;*

10) *Dit que la SIRN devra faire preuve de diligences pour lever, dans le futur, ces contraintes en vue de se doter d'organes de passation des marchés conformes à la réglementation ;*

11) *Accorde, en conséquence, à la SIRN, à cet effet la dérogation sollicitée pour une durée d'une année avec une commission des marchés et une cellule sous réserve de la prise en compte des recommandations précitées;*

Commentaires

I. Les décisions susvisées ont donné au CRD l'occasion de préciser les modalités d'application des textes relatifs à **la composition des commissions des marchés** et d'utiliser son pouvoir de régulation pour assister les entités concernées dans la mise en place de ces organes

Les textes concernés sont les articles 2, 36 et 37 du CMP14, complétés par des arrêtés. Ces textes instituent quatre (04) catégories d'autorités contractantes ; la composition des commissions des marchés varie selon les catégories d'autorités contractantes concernées. Aux termes de l'article 35 du CMP14, chaque autorité contractante doit instituer en son sein une cellule de passation des marchés et une commission de passation des marchés (*voir nos commentaires dans Recueil des décisions et avis du CRD, 2018-2019, Commentaire 4, Organisation de la commande publique. Constitution des commissions des marchés*).

Le bon fonctionnement de ces organes dépend, en grande partie, de **leur composition**. Les entités qui saisissent le CRD sur cette question ont des difficultés pour respecter la réglementation relative à la composition de leurs organes de passation des marchés, en général, parce que leur effectif est insuffisant, ou parce que certains membres proposés n'ont pas qualité pour siéger dans ces commissions. Le CRD assiste alors les entités concernées à se conformer à la légalité.

Les quatre espèces choisies ci-dessus correspondent aux quatre catégories d'autorités contractantes. Les règles de composition de leurs organes de passation sont fixées par une réglementation qu'il convient de rappeler. Il sera ensuite loisible d'examiner comment le CRD les applique à travers ses décisions.

I. Réglementation de la composition des organes de passation des marchés publics

1. Les cellules de passation des marchés, visées à l'article 35 du CMP14, sont régies par l'arrêté n° 865 du 22 janvier 2015, qui fixe leur organisation et leur fonctionnement. Aux termes de l'article 1^{er} de cet arrêté, elles sont chargées de veiller à la qualité des dossiers de passation des marchés des autorités contractantes.

L'article 3 dudit arrêté est ainsi conçu ;

Article 3 ; Le nombre et la composition du personnel des cellules de passation des marchés sont fonction de la spécificité et de la charge de travail de chaque Autorité contractante. Dans tous les cas, ce personnel devra comprendre au moins une personne choisie en fonction de

ses compétences particulières en matière des marchés publics.

La cellule de passation des marchés est un service permanent de l'autorité contractuelle.

2. La composition de la commission des marchés est régie par les textes ci-après

2.1. L'article 36 CMP14 pose les principes dont les suivants

- a) La composition des commissions des marchés, le nombre et les conditions de désignation de leurs membres sont déterminés **par catégorie d'autorité compétente** et fixés par arrêté.
- b) Les membres de la commission représentant l'autorité contractante sont nommés pour un an.
- c) Pour chaque membre titulaire, il est désigné un suppléant.

2.2. L'article 37 CMP14 pose les principes ci-après

- a) Lorsqu'il s'agit des marchés de l'État conclus en dehors de Dakar, un représentant du gouverneur de région participe à la commission des marchés.
- b) Lorsqu'il s'agit des marchés des collectivités territoriales, l'autorité contractante est assistée par deux membres de l'organe délibérant.
- c) *« Dans le cas des marchés des sociétés nationales et des sociétés anonymes à participation publique majoritaire, établissements publics, agences ou autres organismes dotés de la personnalité morale, mentionnés à l'article 2.1.d) du présent décret : un représentant du Ministre chargé de la tutelle de la société, établissement, agence ou organisme concerné et un représentant du Contrôleur financier. »*

2.3. L'arrêté n° 864 du 22 janvier 2015 fixent le nombre et les conditions de désignation des membres des commissions des marchés des autorités contractantes pris en application de l'article 36-1 du Code des marchés publics.

- a) L'article 2 institue quatre (04) catégories d'autorités contractantes et, pour chacune d'elle fixe le nombre des membres des commissions des marchés ainsi que les conditions de leur désignation.
- b) L'article 4 prescrit que les membres des commissions des marchés ne doivent pas être des agents relevant des structures de **contrôle interne ou de la cellule de passation des marchés**.
- c) Pour l'État, les membres de Commissions doivent appartenir au moins à la catégorie B ou assimilée. Pour les sociétés nationales et les établissements publics, ils doivent être de niveau cadre ou assimilé.

II. Jurisprudence du CRD en matière de composition des commissions des marchés publics

3. Le statut et les modes de désignation des membres des commissions des marchés varient selon les catégories d'autorités contractantes concernées. Dès lors, il paraît indiqué de retenir **le critère de catégorie d'autorité contractante** pour rendre compte de la jurisprudence du **CRD** sur cette question, cette approche d'apprécier les groupes de décisions selon les mêmes critères et références.

L'arrêté n° 864 du 22 janvier 2015 distingue, dans son article 2 quatre catégories d'autorités contractantes :

- l'État ;
- les collectivités territoriales ;
- les agences et autres organismes non dotés de la personnalité morale placés sous la tutelle de l'État ou des collectivités territoriales ;
- les sociétés anonymes à participation publique majoritaire, les établissements publics et les agences ou autres organismes dotés de la personnalité morale.

Pour chacune de ces catégories d'autorités contractantes, le CRD a rendu des décisions.

A. Composition des commissions des marchés des entités de l'État

9e espèce

Ministère de l'Emploi, de l'Insertion Professionnelle et de l'Intensification de la main-d'œuvre

Décision n° 96 du 18 juillet 2018

4. Les textes, et notamment l'article 2 du Code des marchés publics, concernent l'État qui regroupe des entités tels que les services déconcentrés et les organismes dotés de la personnalité morale, placés sous son autorité. Les ministères figurent au nombre de ces entités.

Aux termes des articles 2 et 3 de l'arrêté n° 864 du 22 janvier 2015, la commission des marchés des entités de l'État comprend deux groupes de membres répartis comme suit :

- a. **Un premier groupe** de trois membres titulaires et trois suppléants répartis comme suit :
 - le Président ;
 - le responsable du service maître d'œuvre ou son représentant ;
 - un 3^e membre non identifié dans l'arrêté.
- b) **Un deuxième groupe** de membres dont le nombre varie selon la configuration ou l'organigramme du service et leurs suppléants.

Ces membres représentent les services de l'entité. Ils doivent appartenir à la hiérarchie B au moins, ne pas relever des structures chargées du contrôle interne, ni de la cellule de passation des marchés de l'entité.

Un Rapporteur de la Commission des marchés est désigné par l'autorité contractante parmi les membres de la cellule de passation des marchés. Il n'a pas la qualité de membre, mais est tenu aux mêmes obligations de secret que les membres.

5. La jurisprudence du CRD pour cette catégorie d'autorité contractante est illustrée par la décision, 1^{ère} espèce ci-dessus, n° 96 du 18 juillet 2018 dans l'affaire **Ministre de l'Emploi de l'Insertion professionnelle et de l'Intensification de la main-d'œuvre**. En raison d'un déficit de personnel, sa commission des marchés était configurée comme suit :

- Le centre d'initiative pour l'emploi local, l'Inspection technique et le Service de l'Administration générale et de l'Équipement (SAGE), tous présentant les caractères de services maîtres d'œuvre au sens de la réglementation, n'étaient représentés

dans la commission des marchés ni par des titulaires, ni par des suppléants.

La même personne, membre de la cellule de passation des marchés, siégeait comme membre de la commission des marchés, en violation de la réglementation.

Le CRD prend la décision ci-après, inscrite dans son dispositif :

- Les trois services maîtres d'œuvre, seront représentés à la Commission des marchés par une même personne, à la condition qu'elle ne relève pas de l'Inspection technique, corps de contrôle interne.
- La dérogation ainsi accordée à la réglementation est valable pour la gestion 2018.

6. Le ministre de l'Emploi informait également le CRD qu'un agent de la cellule de passation des marchés siégeait comme membre de la commission des marchés. L'article **4 in fine** de l'arrêté n° 864 du 22 janvier 2018 précité interdit cette pratique.

Dans la motivation de sa décision, le CRD proposait une solution dont le résultat aurait été le suivant :

- a. Le membre de la cellule de passation des marchés qui siège à la commission des marchés, reste membre de la commission des marchés.
- b. Il est mis fin à ses fonctions comme membre de la cellule de passation des marchés.
- c. Cette cellule pourra fonctionner avec une seule personne, à condition qu'elle possède les qualifications requises en matière de marchés publics, comme le prévoit l'article 3 de l'arrêté n° 865 du 22 janvier 2015.

La motivation du CRD sur ce point est la suivante.

*Considérant que l'article 3 de l'arrêté n° 00865 du 22 janvier 2015 relatif à l'organisation et au fonctionnement des cellules de passation des marchés dispose que « le nombre et la composition du personnel des cellules de passation des marchés sont fonction de **la spécificité et de la charge** de travail de chaque autorité contractante. Dans tous les cas, ce personnel devra comprendre au moins une personne choisie en fonction de ses compétences particulières en matière de marchés publics » ;*

Considérant qu'il ressort de l'instruction du dossier que le Ministre de l'Emploi, de l'Insertion Professionnelle et de l'Intensification de la Main-d'œuvre a mis en place une commission des marchés sans représentants de certains services ;

Qu'en outre, un agent de la Cellule de Passation des marchés est désigné comme membre suppléant au niveau de la Commission des Marchés ;

Considérant, qu'au regard de la réglementation susvisée, il est possible pour une autorité contractante de n'affecter qu'un seul

agent au niveau de la Cellule de Passation des Marchés, à condition que celui-ci possède les qualifications requises en matière de marchés publics, conformément aux dispositions de l'article 3 de l'arrêté n° 00865 susvisé ;

Qu'ainsi, pour éviter le cumul de fonction entre membre de la commission des marchés et agent de la Cellule de Passation des marchés, et pour tenir compte du déficit de personnel invoqué, le Ministre de l'emploi, de l'Insertion Professionnelle et de l'Intensification de la Main-d'œuvre peut désigner un seul agent pour la Cellule de Passation des Marchés ;

Le dispositif de la décision du CRD ne fait aucune allusion à cette question. Le CRD n'a donc pas autorisé le ministre à constituer sa cellule de passation des marchés avec une seule personne. Il n'a pas non plus répondu à cette préoccupation du requérant.

Pour justifier la dérogation qu'il accorde, le CRD motive :

Considérant, toutefois, que le défaut de fonctionnement de la commission des marchés risque de compromettre l'efficacité de l'action du Ministre de l'Emploi, de l'Insertion Professionnelle et de l'Intensification de la Main-d'œuvre ;

Ainsi, le Régulateur des marchés publics tente toujours d'éviter le grippage de la machine administrative en faisant prévaloir l'impératif de l'efficacité sur la légalité.

B. Composition des commissions des Marchés publics des collectivités territoriales

2^e espèce

Commune de Gawane

Décision n°64 du 15 mai 2019

7. La commune de Gawane est une collectivité territoriale, anciennement appelée collectivité locale. Comme telle, elle est une autorité contractante au sens de l'article 2 du CMP14 ; à ce titre, elle doit se doter d'organes de passation des marchés. La décision n° 84 du 15 mai 2019 du CRD, 2^e espèce ci-dessus, illustre les difficultés qu'ont certaines communes pour respecter cette obligation légale, en l'occurrence, en ce qui concerne **la composition de leurs commissions de marchés.**

8. L'article 2 de l'arrêté n°864 du 22 janvier 2015 qui fixe le nombre et les conditions de nomination des membres des commissions des marchés des autorités contractantes prescrit que, pour les collectivités territoriales, le nombre de représentants de l'autorité contractante dans les commissions des marchés

est de deux (02), **composés de l'organe exécutif et**, selon le cas, du Secrétaire général ou municipal.

La commune de Gawane est dotée d'un secrétaire municipal dont le poste est vacant, **«suite à l'arrivée à son terme du contrat du précédent titulaire dudit poste»** (Cité dans la motivation de la décision). La commune propose de le remplacer par un conseiller municipal. Au titre des représentants d'autres services, la commune propose le percepateur comme membre titulaire, suppléé par un conseiller municipal.

Le CRD décide ce qui suit :

Le secrétaire municipal peut effectivement être remplacé par un conseiller municipal ;

En revanche, le suppléant du percepateur municipal ne peut pas être un conseiller municipal ; la commune doit décimer à ce poste

"un agent issu du même service" que le Percepateur municipal

Cette dérogation est accordée **pour l'exercice 2019**

9. L'intérêt de cette décision réside certes dans son résultat pratique d'avoir permis à la commune de Gawane de sortir de l'impasse, due à son déficit de personnel et de retrouver ses capacités opérationnelles en matière de marchés publics, au moins pour l'exercice 2019.

Mais l'intérêt de la décision réside aussi dans sa motivation. À cet effet, on peut lire dans la décision :

Qu'il est apparu de l'instruction du dossier que cette situation empêche la commune de Gawane de mener à bien ses procédures de passation des marchés, ce qui est source de blocage pour l'atteinte de ses objectifs de gestion ;

Qu'il est nécessaire de tenir compte du principe d'efficacité ainsi que des exigences d'atteinte des objectifs de gestion de la commune ;

Le Régulateur des marchés publics ne porte pas d'appréciation sur la réglementation, comme le ferait le juriste, par exemple pour observer que toutes les collectivités territoriales n'auraient pas dû être érigées en autorités contractantes, mais seulement celles qui ont la capacité de contracter. La démarche du Régulateur des marchés publics est différente. Pour lui, dès lors qu'une entité présente le caractère d'autorité contractante au regard de la réglementation, la priorité, c'est de la mettre dans les conditions lui permettant d'atteindre ses objectifs ; dès lors, toutes les solutions **compatibles** avec la réglementation, permettant d'atteindre ce résultat, doivent être explorées.

**C. Composition des commissions des marchés
des Agences ou autres organismes non dotés de la
personnalité morale, placés sous l'autorité
de l'État ou des collectivités territoriales**

3^e espèce

CNRA

Décision n° 105 du 13 juillet 2019

10. Le Conseil national de Régulation de l'Audiovisuel (CNRA) est une autorité contractante au sens de l'article 2d du CMP14. Pour cette catégorie d'autorités contractantes, l'arrêté n°864 du 22 janvier 2015. prévoit dans son article 2c que le nombre de représentants de l'autorité contractante dans les commissions des marchés est de quatre (04) ainsi composés :

- a) le président de la commission des marchés ;
- b) le directeur financier ou son représentant ;
- c) le responsable des services techniques ou son représentant ;
- d) le responsable du service chargé des approvisionnements et marchés ou son représentant .

Le CRD constate que le CNRA ne dispose «*ni de service financier, ni de responsable chargé des approvisionnements, d'où l'impossibilité pour ce dernier de mettre en place une commission des marchés conformément à l'article 2 de l'arrêté n° 864 du 22 janvier 2015*» (Motivation de la décision).

C'est dans ces conditions que, dans le dispositif de sa décision, le CRD formalise la composition de la commission des marchés à mettre en place comme suit,

Titulaires :

- le Secrétaire Exécutif, président ;
- le responsable informatique ;
- une assistante administrative ;
- un agent administratif chargé des matières.

Suppléants :

- le Directeur de Cabinet du Président (suppléant du Président)
- un agent du service monitoring ;
- le Conseiller du Président spécialiste en NTIC.

11. C'est une pratique courante pour le CRD de formaliser la composition des commissions des marchés alors qu'il aurait pu se contenter de donner des directives à l'autorité contractante pour le faire. Ainsi :

a. Dans l'affaire ONP, une commission des marchés qui ne comportait que deux (02) membres au lieu de quatre (04) a été formalisée et complétée comme suit :

Autorise l'ONP à constituer sa commission des marchés ainsi qu'il suit :

- *Président le Secrétaire Exécutif de l'ONP :*

- le Responsable Administrative et Financière de l'ONP/Membre ;
- le Représentant de la Présidence de la République/Membre
- le Représentant du Contrôle Financier/Membre ;
- **Rapporteur** : Responsable suivi-évaluation de l'ONP ;
- le Représentant de la Présidence de la République ;
- le Représentant du Contrôle Financier ;

, (ARMP/CRD 067 du 17 Avril 2019 Observatoire National de la Parité)

- b. Dans une autre espèce, l'ARD de Sedhiou, le CRD s'est borné à constater que «l'autorité contractante a proposé une composition des marchés dont certains de ses membres ne remplissent pas le critère sus évoqué en raison de l'absence de certains services requis», sans mentionner les services manquants auxquels il se réfère. Le CRD propose alors la composition de la commission des marchés suivante **dans ce dispositif de sa décision.**

- *Président :*
 - Titulaire - Chef de Division Suivi Evaluation ARDS ;*
 - Suppléant - Assistant planificateur ARDS*
- *Membres*
 - Titulaires*
 - ✓ *Chef de la division administrative et Financière ARDS ;*
 - ✓ *Responsable des Infrastructures ARDS*
 - ✓ *Comptable matières ARDS*
 - Suppléants :*
 - ✓ *Assistant suivi évaluation ARDS ;*
 - ✓ *Assistante chargée de la communication ARDS ;*
- ✓ *Assistante ARDS. (ARMP/CRD 075 du 24 Mai 2018 Agence Régionale de Développement (ARD) de Sedhiou))*

- c. Dans la décision relative à l'Université Amadou Mahtar Mbow, le CRD a décidé que la dérogation ainsi accordée ne peut pas être renouvelée plus de deux (02) fois. Le CRD dispose :

3) *Proroge, à titre exceptionnel, l'autorisation accordée à l'Université Amadou Mahtar MBOW par décision N°013//18/ARMP/CRD/DEF du 31 janvier 2018 pour la gestion 2019, en attendant la finalisation du processus de renforcement de son personnel ;*

4) *Dit que la dérogation accordée ne pourrait être renouvelée plus deux (2) fois et que, par conséquent, l'Université doit, dans les meilleurs délais, procéder au recrutement de son personnel complémentaire ;(ARMP/CRD 041 du 13 Mars 2019 Université Amadou Mahtar Mbour)*

D. Composition des commissions des marchés des sociétés nationales, des sociétés anonymes à participation publique majoritaire, des établissements publics et des Agences ou autres organismes dotés de la personnalité morale.

4^e et 5^e espèces

Société des Infrastructures de réparation navale (SIRN)

Décision n° 45 du 5 avril 2018

Société des Infrastructures de réparation navale (SIRN)

Décision n° 3 du 9 janvier 2019

12. La Société des Infrastructures de réparation navale (SIRN) est une société anonyme à participation publique majoritaire. Elle appartient à la catégorie des autorités contractantes visée par l'article 2d de l'arrêté n°864 du 22 janvier 2015. Pour cette catégorie d'autorités contractantes, les commissions des marchés sont composées comme suit :

le Président de la commission des marchés ; le Directeur financier ou son représentant ;

le Responsable des services techniques ou son représentant

le Responsable du service chargé des approvisionnements et marchés ou son représentant un Représentant du ministre chargé de la tutelle de la société, établissement, agence ou organisme concerné (article 37.3 du CMP14).

En 2018, la SIRN a demandé et obtenu du CRD par décision 4^e espèce ci-dessus, une dérogation pour la composition de sa commission des marchés dans les conditions ci-après. En raison de son effectif réduit, la SIRN propose trois (03) membres titulaires pour la commission des marchés et trois (03) agents pour la cellule de passation des marchés, auxquels s'ajouteront les deux membres de droit, à savoir, le représentant du ministère chargé de la tutelle et le représentant du contrôleur financier, comme prescrit par l'article 37.3 du CMP14.

Le CRD constate que le Directeur de l'Administration et des Finances ne figure pas dans la commission des marchés et n'y est pas représenté : il propose donc qu'il soit désigné comme membre de la commission des marchés. Ainsi la commission, composée de quatre (04) membres sans suppléant, sera conforme à l'arrêté. 864 du 22 janvier 2015, « **ne serait-ce que sur le nombre de titulaires** ».

Dans la motivation de la décision, il est bien spécifié que la dérogation est accordée **pour l'année 2018**. Cette limite n'est pas mentionnée dans **le dispositif** de la décision.

13. Le 27 décembre 2018, la SIRN sollicite du CRD une dérogation pour la composition de sa commission des marchés. Par sa décision n° 3 du 9 janvier

2019, 5^e espèce ci-dessus le CRD lui accorde la dérogation sollicitée. Le contexte dans lequel cette décision a été rendue est le suivant.

La SIRN propose qu'en raison de son effectif réduit, elle ne peut constituer qu'une commission des marchés de quatre (04) membres sans suppléants, et une cellule de passation des marchés de trois (03) membres.

Le CRD propose de désigner comme membres : un représentant du ministère de tutelle et un représentant du contrôleur financier **«conformément à l'alinéa 3 de l'article 37 du CMP»** Ce réaménagement permettra à la SIRN d'avoir un nombre de membres de la commission des marchés conformes à la réglementation, ainsi que deux (02) suppléants.

Le CRD propose également de réduire de trois (03) à deux (02) le nombre de membres de la cellule de passation des marchés. Le 3^e agent de la cellule sera nommé membre de la commission des marchés et désigné suppléant du Président de la commission.

14. Le cas de la SIRN et son traitement par le CRD soulèvent quelques observations.

a) L'interprétation que le CRD donne de l'article 37, al 3 du CMP¹⁴ mérite d'être reformulée. En effet, les représentants du ministère de tutelle et du Contrôleur Financier ne peuvent pas siéger dans la commission des marchés de ces entités comme représentants de l'autorité contractante, ni comme représentants des services maîtres d'œuvre. Le Ministère de tutelle et le Contrôleur Financier ne sont pas des services de la SIRN, ce sont **des entités extérieures** à la SIRN. Leurs représentants **siègent de droit**, pour représenter leurs entités. Ils viennent en complément de la commission des marchés **au complet avec ses titulaires et ses suppléants**. Il paraît dès lors difficile d'admettre qu'ils soient désignés comme membres titulaires ou suppléants de la commission des marchés.

b) La SIRN bénéficie des dérogations pour la composition de sa commission des marchés régulièrement renouvelées depuis 2014, alors que par ailleurs, le CRD pose comme principe que la dérogation est nécessairement limitée dans le temps, et ne peut être renouvelée plus de deux fois (*ARMP/CRD 041 du 13 Mars 2019 Université Amadou Mahtar Mbour*).

Ce traitement de faveur fait à la SIRN affaiblit l'autorité des décisions du CRD. Il en est ainsi entre autres parce que la SIRN est une entité qui, en raison de son statut et de son objet, mobilise des ressources financières importantes, devant justifier qu'elle dispose de ressources humaines suffisantes pour constituer ses organes de passation des marchés.

15. On observe d'autres formes d'aménagements de la composition des commissions des marchés de cette catégorie d'autorités contractantes. Ainsi

- a) Le CRD valide la proposition d'aménagement de la commission des marchés de l'Agence Régionale de Développement de Diourbel (ARD) (*ARMP/CRD 020 du 21 Février 2018 Agence Régionale de Développement (ARD) de Diourbel*)
 - b) Le CRD dispense l'Agence Régionale de développement (ARD) de Thiès de la désignation de deux membres titulaires de sa commission des marchés (*ARMP/CRD 077 du 30 Mai 2018 Agence Régionale de Développement (AR) de Thiès*).
 - c) L'institut Islamique de Dakar, Établissement public, est dispensé de désigner les suppléants de deux (02) de ses membres.
-

6

Appels d'Offres. Examen préliminaire et recevabilité des offres.

CMP14 Art. 68 al 1^{er}

CMP14 Article 68 alinéa 1^{er}

Avant de procéder à l'analyse, à l'évaluation et à la comparaison des offres, la commission des marchés compétente procède à un examen préliminaire, afin de déterminer si les candidatures sont recevables en application de l'article 43 et sont accompagnées des pièces mentionnées à l'article 44, et rejette les offres non recevables.

Société GeoTop Ingénierie

ARM P/CRD n° 169 du 5 décembre 2018

PAR CES MOTIFS :

- 1) *Constate que la clause j de la clause 11 des IC du DAO avait exigé des attestations justifiant que le soumissionnaire a satisfait à ses obligations à l'égard de la caisse de sécurité sociale et l'inspection du travail ;*
- 2) *Constate que l'offre de GEOTOP contenait une attestation de la caisse de sécurité sociale valable jusqu'au 15 juillet 2018 et une attestation de l'inspection régionale du travail avec une date de validité jusqu'au 20 mars ;*
- 3) *Constate que la commission des marchés du PADAER dans son rapport d'évaluation a considéré ces pièces comme périmées et relevé des manquements ;*
- 4) *Constate que le soumissionnaire a produit une déclaration sur l'honneur ;*
- 5) *Dit que l'article 44 du CMP prévoit que ces pièces doivent être fournies à la signature du marché et qu'une simple déclaration sur l'honneur suffit à l'ouverture ;*
- 6) *Dit que cette décision de la commission des marchés n'est pas justifiée ;*
- 7) *Constate que le DAO avait exigé une attestation de ligne de crédit de 130 millions pour le lot 1 et de 80 millions pour le lot 2 ;*
- 8) *Constate que GEOTOP a soumissionné pour les deux lots mais n'a produit qu'une attestation de ligne de crédit de 130 millions ;*
- 9) *Constate que le PADAER a, lors de l'examen préliminaire de l'évaluation, rejeté l'offre pour capacité financière insuffisante ;*
- 10) *Dit que la production de capacité financière est un critère de qualification ;*

- 11) *Dit que l'analyse de la ligne de crédit durant l'examen préliminaire est prématurée ;*
- 12) *Dit que le rejet de l'offre pour la ligne de crédit ne couvrant pas les deux lots en examen préliminaire n'est pas justifié ;*
- 13) *Déclare, en conséquence, le recours fondé, ordonne la reprise de l'évaluation et la restitution de la consignation ;*

Commentaires

Dans sa décision n° 169 du 5 décembre 2018 Société Géo Top Ingénierie rapportée, le CRD, **en application de l'article 68, al. 1^{er} du CMP14**, a jugé que c'est à tort que la commission des marchés a rejeté l'offre du requérant, **en examen préliminaire**, pour capacité financière insuffisante, suite à l'analyse de sa ligne de crédit ; que la capacité financière dont la preuve peut être rapportée par la production d'une ligne de crédit, est **un critère de qualification des candidats** aux marchés publics ; que l'analyse de la ligne de crédit lors de l'examen préliminaire est prématurée ; que dès lors, il y a lieu d'annuler l'attribution provisoire du marché et d'ordonner la reprise de l'évaluation.

Toutefois, malgré la clarté du **cadre réglementaire** sur l'étape de l'examen préliminaire des offres en matière de passation, la **jurisprudence** du CRD pour la période de référence 2018-2019, reste **hésitante**.

A. Cadre réglementaire

1 La décision n° 169 du 5 décembre 2018 **Société Géo Top Ingénierie** rapportée, **est relative à l'étape de la passation appelée examen préliminaire de la recevabilité des offres. Cette étape est régie par l'article 68, al. 1^{er} du CMP14.**

Pour la commission des marchés, l'examen préliminaire s'inscrit ainsi dans les autres étapes :

- a. L'ouverture des plis (art 67 CMP14).
- b. L'examen préliminaire de la recevabilité des offres (art 68, al 1^{er} ; art 43 ; art 44 du CMP14). A cette étape la commission rejette **les offres non recevables**.
- c. L'examen de la qualification des candidatures. A cette étape, la commission rejette **les candidatures non qualifiées** (art 44 et 43 CMP14)
- d. L'examen de la **conformité des offres aux prescriptions du DAO** (art 68, al 2 ; art 69 ; art 43 et art 44). A cette étape, la commission rejette **les offres non conformes au DAO**.
- e. L'évaluation, l'analyse, la comparaison et le classement des offres (art 70 et 59 CMP14). A l'issue de cette étape, l'autorité contractante procède à **l'attribution provisoire du marché** (ou renonce au marché, ou déclare l'infructuosité du marché).

2. Les articles 43 et 44 du CMP14 sont donc inséparables de l'article 68. Ils sont aussi conçus

Article 43 :

Ne sont pas admises à prendre part aux marchés publics, quel que soit le mode de passation du marché :

a) les personnes physiques en état de faillite personnelle ;

b) les personnes physiques ou morales admises au régime de la liquidation des biens ;

c) les personnes physiques ou morales en état de redressement judiciaire lorsque la poursuite de l'activité est interdite par décision du juge commissaire ;

d) les personnes physiques ou morales frappées d'une mesure temporaire ou définitive d'interdiction d'obtenir des commandes publiques résultant d'une décision du Comité de Règlement des

Différends en vertu du présent décret, d'une décision de justice ou d'une disposition législative ;

e) les personnes physiques candidates et les dirigeants de personnes morales candidates ayant fait l'objet d'une condamnation pour une infraction pénale liée à leurs activités professionnelles ou consistant en des déclarations fausses ou fallacieuses quant aux qualifications exigées d'eux pour l'exécution du marché ;

f) les personnes qui, au 31 décembre de l'année précédant celle au cours de laquelle a eu lieu le lancement de la consultation, n'ont pas souscrit les déclarations leur incombant en matière fiscale et sociale, ou n'ont pas effectué le paiement des impôts, taxes et cotisations exigibles à cette date ;

g) les personnes visées à l'article 46 du Code des Marchés publics qui n'auront pas produit l'attestation de qualification et la classification des entreprises, entrepreneurs et artisans de bâtiments et de travaux publics ;

il en est de même pour les candidats aux marchés relatifs à la défense et à la sécurité de l'État, lorsqu'il est exigé au candidat d'être préalablement qualifié selon soit le système de qualification de l'Autorité contractante, soit par celui d'organismes tiers. S'il est recouru à un système de qualification établi par un organisme tiers, le nom de celui-ci est communiqué aux candidats intéressés ou sollicités ; •

h) les entreprises ou agences publiques lorsqu'elles sont soumises à la tutelle technique de l'Autorité contractante. Seules sont admises à participer les entreprises publiques qui peuvent établir ;

i. qu'elles jouissent de l'autonomie juridique et financière ;

ii. qu'elles sont gérées selon les règles du droit commercial ; et, qu'elles ne sont pas des agences qui dépendent de l'Autorité contractante.

Les dispositions du présent article sont également applicables aux sous-traitants.

Article 44

Sous réserve du respect de ses droits en matière de protection de la propriété intellectuelle ou industrielle et de la confidentialité des informations concernant ses activités, tout candidat à un marché public doit justifier qu'il dispose des capacités juridiques, techniques, financières et environnementales requises pour exécuter le marché, en présentant tous documents et attestations appropriés énumérés par le dossier d'appel à la concurrence, comprenant notamment :

- a) une déclaration indiquant son intention de faire acte de candidature pour réaliser le marché et mentionnant :

 - i. s'il s'agit d'une personne physique, son nom, qualité, domicile ;*
 - ii. s'il s'agit d'une personne morale, sa forme juridique, sa dénomination sociale, son siège, le nom du représentant ainsi que la qualité en vertu de laquelle il agit;*
 - iii. s'il y a lieu, le numéro d'immatriculation au registre du commerce et*
 - iv. du crédit mobilier ;*
 - v s'il y a lieu, le numéro d'immatriculation au registre des métiers.**
- b) une note présentant le candidat et indiquant notamment ses moyens humains et techniques, toutes informations utiles sur les activités et marchés réalisés de même nature que le marché concerné ;*
- c) des attestations justifiant, dans les conditions fixées par arrêté ministériel, qu'il a satisfait à ses obligations à l'égard de la Caisse de Sécurité sociale, de l'Institut de Prévoyance Retraite du Sénégal (IPRES), des services chargés des recouvrements fiscaux et de l'Inspection du Travail ;*
- d) une attestation justifiant le paiement des redevances de régulation exigibles au titre des marchés publics de l'exercice précédent;*
- e) une déclaration sur l'honneur attestant qu'il ne fait pas l'objet d'une procédure de liquidation de biens ou de faillite personnelle ;*
- f) une déclaration attestant qu'il a pris connaissance des dispositions de la Charte de Transparence et d'Éthique en matière de marchés publics adoptée par décret et qu'il s'engage à les respecter ;*
- g) la garantie de soumission, le cas échéant;*
- h) des renseignements sur le savoir-faire du candidat en matière de protection de l'environnement, le cas échéant ;*
- i) éventuellement, tout autre document permettant de juger de sa capacité financière.*

Le défaut de fournir la garantie de soumission à l'ouverture des plis entraîne le rejet de l'offre.

Les documents prévus aux alinéas a), b), d), e), f), et éventuellement h) et i), non fournis ou incomplets, sont exigibles dans un délai au plus égal à celui imparti à l'Autorité contractante pour prononcer l'attribution provisoire.

Les documents prévus à c) sont produits à la signature du marché et les candidats doivent s'engager sur l'honneur, dans leurs offres, qu'ils sont en règles avec les administrations visées audit alinéa.

Pour les marchés liés à la défense et à la sécurité de l'État visés à l'article 76 du présent décret, l'Autorité contractante peut exiger des candidats, outre les renseignements indiqués au présent article, des renseignements complémentaires concernant leur habilitation préalable si cela est exigé par une réglementation en vigueur, la composition de leur actionnariat, la valeur ajoutée créée sur le territoire national, l'implantation de leur patrimoine technologique, leurs capacités industrielles sur le site de réalisation du marché.

3. L'une des difficultés d'application de l'article 68 tient au fait que **certaines conditions de recevabilité** des offres qu'il prescrit constituent aussi des critères de qualification des candidats fixés par l'article 44. L'alinéa 1^{er} de l'article 44 dispose en effet que tout candidat à un marché public doit justifier qu'il dispose de capacités juridiques, techniques, financières et environnementales requises pour exécuter le marché. La justification se fait par la production des pièces visées à l'article 43 et reprises, sous une forme un peu différente, à l'alinéa 2 de l'article 44.

L'application de ce dispositif peut conduire à invalider un candidat à l'étape de l'examen préliminaire pour absence ou non-conformité de certaines pièces qui n'auraient dû être exigées qu'à l'étape de la qualification, avec cette particularité qui n'existe pas à l'étape préliminaire que ; dans le cadre de l'article 44, des délais peuvent être accordés aux candidats pour produire certaines de ces pièces. Enfin, le Code des marchés ne prescrit pas des critères différenciés d'appréciation de ces pièces selon qu'elles sont examinées à l'étape préliminaire ou à l'étape de la qualification des candidats. La Commission des marchés a simplement l'obligation de ne pas en examiner la conformité à l'étape de l'examen préliminaire.

B. Incohérence de la jurisprudence du CRD

4. Les décisions du CRD en matière d'examen préliminaire ne sont pas cohérentes. Certaines situent l'examen préliminaire dans le **cadre de l'article 68 alinéa 1'** comme le prescrit le CMP14. C'est la conception étroite, conforme au Code. D'autres décisions en revanche appliquent la conception large ; elles intègrent l'examen préliminaire au contrôle de conformité.

5. L'affaire GeoTop Ingénierie, décision n° 169 du 5 décembre 2018, 1^{er} espèce ci-dessus, développe la conception étroite de l'examen préliminaire. Les faits sont les suivants.

Suite à un Appel d'Offres lancé par le Projet d'Appui au Développement Agricole et à l'Entreprenariat Rural (PADAER), l'offre de GeoTop Ingénierie a été rejetée à l'étape de l'examen préliminaire. GeoTop a donc contesté l'attribution provisoire et le rejet de son offre devant le CRD. Ce rejet était motivé par le fait qu'au titre des pièces visées par l'article 44c du CMP14. GeoTop avait produit une attestation de caisse de sécurité sociale périmée depuis le 15 juillet 2018, une attestation d'inspection régionale du travail périmée depuis le 20 mars 2018 et une ligne de crédit de 130 millions à la place des 210 millions demandés. Le CRD rejette cet argument pour les motifs ci-après.

- a. Pour les pièces visées à l'article 44c, le même article dispose qu'elles sont produites à la signature du contrat ; que les candidats doivent s'engager sur l'honneur qu'ils sont en règle avec la caisse de sécurité sociale et l'inspection du Travail. Le CRD constate que GeoTop a produit une attestation sur l'honneur affirmant qu'il est en règle avec les Administrations fiscales et sociales : Dès lors, décide le CRD, la Commission des marchés ne peut pas retenir les manquements relèvés au niveau de l'examen préliminaire.
- b. S'agissant de la ligne de crédit, le CRD constate que dans la clause 5.1 du DAO, cette pièce est prévue comme un critère de qualification. En conséquence, décide le CRD : *l'appréciation de la ligne de crédit devrait se faire au niveau de la qualification une fois que l'offre du candidat est déclarée conforme ;*

Qu'ainsi, en appréciant la ligne de crédit au niveau de l'examen préliminaire, le PADAER a de manière prématurée vérifié la qualification sans au préalable s'assurer de la conformité de l'offre du candidat ;

Que par conséquent le rejet de l'offre de GEOTOP pour le lot 1 à l'examen préliminaire pour une ligne de crédit insuffisante n'est pas justifié ;

Qu'il convient, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs de déclarer le recours fondé, d'ordonner la reprise de l'évaluation et la restitution de la consignation;

6. Pour la période de référence 2018-2019, le site de l'ARMP ne publie pas d'autres décisions statuant exclusivement sur l'application de l'article 68, 1^{er} alinéa. Cela peut signifier que toutes les offres retenues comme conformes auront été présentées par des candidats recevables lors de la phase de «l'examen préliminaire». Cela pourrait aussi «signifier que certains rejets pour non-conformité l'ont été en fait pour irrecevabilité à la phase de l'examen préliminaire».

Cette situation peut s'expliquer par la divergence de conception de l'examen préliminaire dans les décisions du CRD.

7. L'affaire Laniane Entreprises, décision n° 33 du 27 février 2019, développe une conception large de l'examen préliminaire, en l'assimilant au contrôle de conformité.

Dans cette affaire, le CRD devait statuer sur la conformité de l'offre de Laniane Entreprises ainsi que sur la régularité de l'attribution du marché à un autre soumissionnaire. Dans l'examen du litige, le CRD commence par rappeler comme suit le 1^e alinéa de l'article 68 du corpus dans son intégralité :

Considérant qu'il ressort de l'article 68 du Code des Marchés Publics qu'avant de procéder à l'analyse, à l'évaluation et à la comparaison des offres, la commission des marchés procède à un examen préliminaire afin de vérifier si les candidatures sont recevables, en application de l'article 43 et sont accompagnées des pièces visées à l'article 44, et rejette les offres non recevables ;

On voit bien qu'aux termes de ce texte, l'examen préparatoire a pour objet d'identifier et de rejeter les candidatures non recevables. Les offres des candidats concernées n'ont fait encore l'objet d'aucune analyse. C'est plus tard, après avoir écarté les candidatures non recevables que la commission des marchés examinera la

conformité des offres des candidats restés en lice, en application de l'alinéa 2 de l'article 68 CMP14. L'analyse de conformité ne concerne que les offres des déclarées recevables.

Contrairement à cette vue, le CRD poursuit dans l'affaire Laniane Entreprises :

Considérant qu'il importe de préciser que l'examen préliminaire des offres a pour objet d'identifier et de rejeter celles qui sont incomplètes, non recevables ou non conformes aux dispositions du dossier d'appel d'offres ;

On note que ce considérant contredit totalement le 1^{er} alinéa de l'article 68 du Code des marchés. L'examen préliminaire et l'examen ou l'analyse de conformité sont confondus en une seule opération. Alors que l'examen préliminaire prescrit par l'article 68 CMP14 ne vise qu'un seul objet : identifier et rejeter les offres irrecevables, la conception que le CRD lui donne dans cette décision lui en assigne trois : rejeter les offres incomplètes ; rejeter les offres irrecevables, et rejeter les offres non conformes.

Le CRD poursuit

Considérant qu'il est constant que l'offre de Laniane Entreprises a été écartée à ce stade par la commission des marchés du MSAS, pour défaut d'exhaustivité et non-conformité de l'offre pour l'essentiel ;

Il paraît difficile d'admettre, en droit, qu'au stade de l'examen préliminaire, une offre soit écartée pour non-conformité **puisque, selon l'article 68, à ce stade-là, la commission n'a pas encore procédé à l'analyse des offres.**

Appels d'offres

Conformité des offres

CMP14 art 68 alinéa 2

CMP14 art 68 alinéa 2

***La Commission détermine ensuite si les
Offres sont conformes aux conditions
et spécificités des cahiers des charges***

1^{er} espèce

Groupement SAGEMCOM/GEESY

Décision n° 40 du 28 mars 2018

PAR CES MOTIFS :

- 1) *Constate que l'autorité contractante a exigé « que le candidat fournisse une description complète du plan de formation requis » ;*
- 2) *Constate que le groupement reconnaît n'avoir pas produit de programme de formation ;*
- 3) *Dit que la non-production de programme de formation est justifiée, puisqu'étant prévu à la phase exécution par le document contractuel dit « point à point technique » ;*
- 4) *Constate que le groupement SAGEMCOM/GEESY et l'ASER font référence respectivement à la puissance totale du générateur photovoltaïque (kwc) et à la puissance de sortie onduleur (kw) ;*
- 5) *Dit que la commission doit s'assurer qu'elle traite de la même unité de mesure et du même objectif recherché avec le groupement avant de le déclarer non conforme pour le point relatif à la conception ;*
- 6) *Constate que l'autorité contractante considère que les certificats ISO de conformité n'ont pas été fournis ;*
- 7) *Constate que le soumissionnaire a fourni en plus du document RECOM de conformité aux tests 61215 et 61730, les fiches techniques qui comportent la mention contractuelle de ces tests ;*
- 8) *Dit que la non-conformité pour le panneau photovoltaïque ne peut être retenue ;*
- 9) *Constate que l'autorité contractante affirme que les certificats de test pour les batteries ne sont pas fournis ;*
- 10) *Constate que les certificats de tests de conformité sont mentionnés dans les fiches techniques des batteries EXIDE SONNENSCHNAIN ainsi que les informations les plus importantes*

relatives au nombre de cycles et la relation de ces dits cycles avec la température, conformément aux clauses contractuelles ;

1 1) Dit que la non-conformité du groupement par rapport aux certificats de test des batteries n'est pas fondée ;

1 2) Constate, qu'au regard des conclusions du rapport d'expert en date du 21 mars 2018, les non-conformités soulevées par l'autorité contractante à l'encontre du soumissionnaire ne sont pas avérées ;

1 3) Constate que l'importante différence de 4 300 000 000 F CFA HT (quatre milliards trois cent millions francs CFA HT qui ressort du rapprochement de l'offre financière de l'attributaire provisoire à celle du requérant ne confirme pas une bonne application du principe de l'économie ;

1 4) Déclare, par contre, que la commission aurait dû recourir aux dispositions de l'article 69 pour disposer d'informations complémentaires sur les offres techniques nécessaires pour une meilleure évaluation des offres dans un but de préserver le principe de l'économie ;

1 5) Ordonne l'annulation de l'attribution provisoire, la reprise de l'évaluation et la restitution de la consignation ;

2^e espèce

Groupement SAGEMCOM/GGEESY

Décision n° 122 du 29 août 2018

PAR CES MOTIFS :

1) Constate que les fiches techniques des modules photovoltaïques et des batteries fournies par le groupement SAGEMCOM/GGEESY mentionnent leur conformité aux normes standards internationales ;

2) Constate que dans sa décision n° 040/18/ARMP/CRD/DEF du 21 mars 2018 relatif au premier recours, le CRD a déjà admis le caractère contractuel desdits documents qui font partie intégrante de l'offre et engageant de ce fait le soumissionnaire ;

3) Constate, en outre, que le requérant a fourni un document attestant que la marque de panneaux photovoltaïques RECOM qu'il a proposée « a été soumise à des tests de conformité aux normes standards CE! 61730 et 61215 et aux Directives CE » par des laboratoires indépendants ;

4) Dit que sur ce point la décision de la commission des marchés de déclarer l'offre du requérant non-conforme n'est pas fondée ;

5) Constate que les villages ou cluster sont classés en Type 1 (10 kWc) ; Type 2 (15 kWc) ; Type 3 (20 kWc) ; Type 4 (25 kWc) ; Type 5 (30 kWc) ; Type 6 (35 kWc) ; Type 7 (40 kWc) ; Type 8 (45 kWc) ; Type 9 (50 kWc) et Type 10 (60 kWc) ;

6) Constate que la clause 8.4 du DAO stipule que les valeurs admissibles du rapport entre la puissance installée et les onduleurs-chargeurs doivent être comprises entre 0,7 et 1 ;

7) Constate, à-dire-d' expert, que les fonctionnalités déterminantes pour les onduleurs-chargeurs sont principalement d'avoir, d'une part, une puissance supérieure à la puissance de pointe et, d'autre part, une puissance de charge suffisante pour charger les batteries à 100 % durant les heures de charge prévues, ce qui induit une comparaison entre la charge nocturne et la puissance de sortie de l'onduleur-chargeur qui doit permettre de couvrir la charge du village en heure de pointe ;

8) Constate que le rapport d'évaluation a conclu à une différence de 455, 4 KW, équivalant à 99 onduleurs bidirectionnels ;

9) Constate que la « non-conformité » soulevée n'est pas liée à une mauvaise conception ou fonctionnalité du système photovoltaïque proposé par le requérant mais à un gap d'onduleurs-chargeurs ;

10) Constate que la **clause 1.1.1 Informations contextuelles et Objectifs globaux** du DAO prévoit une actualisation des besoins pendant l'exécution du marché qui peut induire une évolution allant dans le sens d'une baisse ou d'une hausse de la puissance totale des onduleurs-chargeurs ;

11) Dit que la « non-conformité » alléguée n'est pas substantielle ;

12) Dit, de surcroît, que le gap de 99 onduleurs-chargeurs, invoqué par l'autorité contractante ne justifie pas l'écart de quatre milliards trois cent millions de francs (4 300 000 000) F CFA HT pour les deux (02) lots, entre l'offre financière du requérant et celle de l'attributaire provisoire ;

13) Dit en conséquence que l'autorité contractante n'a pas cherché à disposer de la meilleure offre en termes de coût et de performance ;

14) Dit que la décision de l'autorité contractante d'écarter l'offre du groupement SAGEMCOM/GEESY n'est pas justifiée ;

15) Déclare le recours fondé et ordonne l'annulation de la décision d'attribution provisoire du marché et la reprise de l'évaluation ;

Commentaires

I. Dans l'affaire du groupement SAGECOM/ GEESY, le CRD, par ses décisions susvisés n° 40 du 28 mars 2018 et 122 du 29 août 2018, a fait **application de l'article 68, al 2 du CMP14**, relatif à **l'examen de la conformité des offres en matière de marchés publics**

Les faits sont les suivants

L'Agence Sénégalaise d'Électrification rurale (ASER) a lancé un marché relatif à la fourniture et l'installation pour l'électrification des villages par mini centrales solaires photovoltaïques dans certaines régions du Sénégal. Le marché, comportant 2 lots, est provisoirement attribué au groupement Atersa Eleenor. Le groupement SAGECOM/GEESY conteste le rejet de son offre. Dans sa décision n°

40 du 18 mars 2018, le CRD constate un écart de quatre milliards trois cents millions entre l'offre financière du requérant et celle de l'attributaire provisoire. Au regard de cet enjeu économique de ce marché, le CRD décide que les non conformités reprochées au requérant ne sont pas justifiées ; que l'autorité contractante a méconnu le principe d'économie en ce qu'elle n'a pas mis à profit des *“dispositions pertinentes de la réglementation pour disposer d'une offre conforme et économiquement avantageuse dans un souci de nationaliser l'utilisation des fonds publics”*. En conséquence, le CRD annule l'attribution provisoire et ordonne la reprise de l'évaluation. A l'issue de la réévaluation, l'offre du requérant est à nouveau rejetée. Le CRD saisi, décide que la non-conformité alléguée **n'est pas substantielle**, que le gap de 99 ondulateurs invoqué par l'autorité contractante ne justifie pas le rejet de l'offre. Le CRD annule une nouvelle fois l'attribution provisoire du marché.

Les décisions ci-dessus, reprises dans les tableaux ci-après, montrent comment, dans la pratique, le CDR procède pour identifier les non conformités et les apprécier. Elles montrent aussi que **le CRD a des pouvoirs étendus de correction des DAO**. La validation de certaines non conformités conduit même à se demander si le CRD n'a pas remis en cause le principe de l'intangibilité des offres fixé par l'article 69 du CMP14.

I. Observations liminaires

1. Le texte de l'alinéa 2 de l'article 68 du CMP14, ainsi que des dispositifs de deux décisions du CRD rendues dans l'affaire **du groupement SAGECOM/GEESY**, respectivement le 28 mars 2018 et le 29 août 2018, reproduits ci-dessus, sont **relatifs à l'analyse de la conformité des offres** dans la procédure de passation des marchés publics.

A. L'analyse de la conformité des offres est différente et distincte de l'examen préliminaire de la recevabilité des offres

2. L'examen de la **conformité des offres** est réglementé par l'alinéa 2 de l'article 68 du CMP14. Ce texte, relativement court est ainsi conçu :

La Commission détermine si les offres sont conformes aux conditions et spécifications des cahiers des charges.

La rédaction de ce texte montre bien qu'une activité différente précède l'examen des Offres. Effectivement, le 1^{er} alinéa de l'article 68 prescrit que la Commission des marchés procède d'abord à un **examen préliminaire** afin d'éliminer **les candidatures irrecevables**. Ensuite seulement, alinéa 2 de l'article 68, la Commission procède à l'examen des Offres. Les candidatures examinées à l'étape du 2^e alinéa de l'article 68 sont celles des candidats dont les offres sont déjà déclarés **recevables** à l'issue de l'examen préliminaire.

B. La détermination du caractère conforme des offres est une activité matérielle. Sa théorisation se heurte à des considérations techniques.

3. L'examen de la conformité des offres se déroule d'une manière générale selon le schéma suivant :

- a) L'autorité contractante a l'intention d'acheter des travaux, fournitures ou services. Elle décrit les produits objets à acheter dans les documents d'Appel d'Offres (DAO). La description est toujours détaillée.
- b) Des candidats aux marchés se proposent de lui vendre ces produits. Avant de les acheter, l'autorité contractante demandera à la Commission des marchés de s'assurer qu'ils sont conformes à ceux décrits dans le DAO.
- c) L'examen de conformité est une opération matérielle par laquelle la Commission des marchés va comparer les produits qui lui sont proposés à ceux décrits dans les DAO.

Dans la pratique, on constate que la conformité n'est jamais totale entre le produit proposé et le produit décrit dans le DAO. Il **y a toujours une marge de non-conformité entre deux produits**. Finalement, l'examen de conformité se ramène à la gestion des marges de non-conformités entre les offres et les produits décrits dans le DAO.

4. La tentation est donc devenue forte de faire **la théorie de la conformité des offres**.

L'approche théorique consisterait à rechercher **les critères a priori d'une offre conforme**. Cette voie est semée d'obstacles. En effet, l'offre du candidat est rarement conforme aux prescriptions du DAO. Il existe toujours une certaine non-conformité entre l'offre et la commande. Finalement, la non-conformité devient la norme. **La mesure de la non-conformité permettrait de déterminer celle qui serait retenue ou rejetée à l'issue de l'évaluation des offres**. Cette mesure constitue le point de divergence entre l'autorité contractante et le CRD. ,

il paraît difficile de la déterminer *a priori* la mesure de la non-conformité pour toutes les branches de la commande publique. En effet, la théorisation des non conformités est difficile à faire en raison de la complexité de l'opération de déclaration de la conformité des offres. En matière de fournitures par exemple, la commande publique peut porter sur **un type de matériel** (appareil d'échographie par exemple), mais comportant des **spécifications techniques** propres. Ces spécificités peuvent porter sur le rendement de l'appareil, la qualité des images, le tout exprimé en termes techniques ou spécifiques. Ces spécificités peuvent varier selon les types d'appareil. Un même service hospitalier peut commander différents types d'appareils avec des spécifications techniques différentes. Dans certains cas, l'autorisation du fabricant du matériel peut être exigée. Dans d'autres cas, le candidat doit joindre la documentation technique et le mode d'emploi du matériel et, il est arrivé que des offres soient rejetées pour non-conformité lorsque certains de ces éléments font défaut, ou bien ne sont pas conformes. Les décisions ci-dessus, reprises dans les tableaux ci-après, montrent comment, dans la pratique, le CDR procède pour identifier les non conformités et les apprécier. Elles montrent aussi que le CRD a des pouvoirs étendus de correction des DAO. La validation de certaines non conformités conduit même à se demander si le CRD n'a pas remis en cause le principe de l'intangibilité des offres fixé par l'article 69 du CMP14.

5 L'approche pragmatique pose le problème en termes différents. Partant du constat que la quasi-totalité des offres sont non conformes aux prescriptions du DAO, elle en distingue deux cas limites : La **conformité pour l'essentiel** qui signifie que, même si l'offre n'est pas conforme à 100 %, elle est acceptée, si les non conformités qui l'entachent sont **mineures**. Les **non-conformités substantielles** : dans ce cas, l'offre n'est rejetée que si les non conformités qui l'entachent sont « **substantielles** ». Les DAO déterminent alors les critères **du caractère substantiel** de ces non conformités.

C. Les commissions des marchés doivent user de leurs prérogatives pour **limiter les non- conformités** ou, le cas échéant les contenir.

Le dialogue entre les commissions des marchés et le CRD porte sur cet aspect. Le CRD **veut s'assurer que les non- conformités sur lesquelles les commissions des marchés s'appuient pour évaluer les offres sont justifiées. En l'absence des critères a priori des non- conformités, le CRD se laisse guider par les principes généraux de la régulation ou de la commande publique.**

II. Pratique jurisprudentielle

Les méthodes du CRD

7. Les contestations des conformités ou les cas de non-conformités déferés au CRD sont des cas limites. En effet, lorsque l'autorité contractante commande un camion et que le candidat propose de livrer un véhicule 4 places, l'offre n'est pas conforme, la non-conformité est manifeste. Si de tels cas font l'objet de recours, le CRD ne pourra que constater la non-conformité de l'offre et rejeter le recours.

Les cas qui interpellent le CRD en sa qualité de Régulateur des marchés publics ce sont des cas limites dans lesquels la conformité ou la non-conformité de l'offre tient à quelques détails en général liés aux spécifications techniques fixées par le DAO.

Dans ces cas, le CRD se laisse guider par les principes généraux de la régulation et de la commande publique. Dans certains de ces cas, cela pourrait être un paradoxe, les non-conformités qui ne violent pas ces principes sont tolérées et n'entraînent pas le rejet des offres concernées

1^{er} espèce

A. L'affaire Groupement SAGEMCOM/GEESY

Décision n° 40 du 28 mars 2018

8. Les décisions rendues dans l'affaire du Groupement SAGEMCOM illustrent les méthodes du CRD en matière de détermination du caractère conforme des offres Pour la décision n° 40 du 28 mars 2018, 1^{er} espèce, les faits sont les suivants :

- a) Le 21 février 2018, le Groupement SAGEMCOM / GEESY a saisi le Comité de Règlement des différends pour contester le rejet de son offre du

marché relatif à la fourniture et l'installation pour l'électrification de 76 villages par mini centrales solaires photovoltaïques dans les régions de Matam et Tambacounda lancé par l'Agence Sénégalaise d'Électrification Rurale (ASER) du Sénégal.

- b) Quinze (15) offres ont été reçues à l'ouverture des plis. Le marché a été attribué au Groupement Atersa Eleenor pour les montants ci-après :

Lot 1 : 4 469 036734, 08

Lot 2 : 5 254 897484, 85

- c) Le groupement SAGEMCOM/GEESY conteste l'attribution provisoire. Son offre était estimée à

Lot 1 : 2192 545 515

Lot 2 : 2 734027 599

- d) Le 28 février 2018, le CRD prononce la suspension de l'attribution provisoire par décision n° 006/18/ARMP/CRD.

- e) Statuant ensuite au principal, dans la présente espèce (décision n° 40 du 28 mars 2018), le CRD se prononce sur la conformité technique de l'offre du requérant au regard du Dossier d'Appel d'offres.

9. L'ASER, autorité contractante, reproche au requérant des manquements de conformité. Les tableaux ci-après font apparaître ces manquements, les exigences du DAO sur ces projets, la réponse du requérant, et la décision du CRD.

Prescription du DAO	Manquements de conformité constatés par l'AC	Décision du CRD
Formation L'autorité contractante prévoit « que le candidat doit fournir une description complète du plan de formation requis. Le plan doit être conforme à la section IV, CCTS, Formation et transfert de connaissances vers la population locale ». Le plan doit inclure les CV des enseignants proposés et un programme complet et temporel	Formation Le programme de formation n'est pas fourni	Formation 1) Constate que l'autorité contractante a exigé « que le candidat fournisse une description complète du plan de formation requis » ; 2) Constate que le groupement reconnaît n'avoir pas produit de programme de formation ; 3) Dit que la non-production de programme de formation est justifiée, puisqu'étant prévu à la phase exécution par le document contractuel dit « point à point technique » ;
Conception Séparation de l'installation lorsque la puissance dépasse 50 KW	Conception La séparation des installations lorsque la puissance dépasse 50 KW n'est pas envisagée	Conception 4) Constate que le groupement SAGEMCOM/GEESY et l'ASER font référence respectivement à la puissance totale du générateur photovoltaïque (KWc) et à la puissance de sortie onduleur (KW) ; 5) Dit que la commission doit s'assurer qu'elle traite de la même unité de mesure et du même objectif recherché avec le groupement avant de le déclarer non conforme pour le point relatif à la conception ;
Panneau photovoltaïque Fournir le Certificat de conformité CEI 61 730 et 61 215	Panneau photovoltaïque Le certificat prescrit n'est pas fourni	Panneau photovoltaïque 6) Constate que l'autorité contractante considère que les certificats ISO de conformité n'ont pas été fournis ; 7) Constate que le soumissionnaire a fourni en plus du document RECOM de conformité aux tests 61215 et 61730, les fiches techniques qui comportent la mention contractuelle de ces tests ; 8) Dit que la non-conformité pour le panneau photovoltaïque ne peut être retenue

Prescription du DAO	Manquements de conformité constatés par l'AC	Décision du CRD
Batteries Fournir les certificats de test.	Batteries Les certificats de test des batteries n'ont pas été fournis	Batteries 9) Constate que l'autorité contractante affirme que les certificats de test pour les batteries ne sont pas fournis ; 10) Constate que les certificats de tests de conformité sont mentionnés dans les fiches techniques des batteries EXIDE SONNENSCHNAIN ainsi que les informations les plus importantes relatives au nombre de cycles et la relation de ces dits cycles avec la température, conformément aux clauses contractuelles ; 11) Dit que la non-conformité du groupement par rapport aux certificats de test des batteries n'est pas fondée ;
Coefficient de distorsion Le Coefficient de distorsion harmonique doit être inférieur à 3 %	Coefficient de distorsion Le coefficient proposé est de 4%	Coefficient de distorsion Qu'il en ressort que même si le groupement n'est pas conforme au regard de la spécification de 3 % demandée, il reste que le taux de distorsion de 4 % proposé par le groupement donnerait le même effet recherché par l'AC, Qu'ainsi, la non-conformité du groupement liée au coefficient de distorsion n'est pas fondée ;
Autorisation du fabricant Antivol	Autorisation du fabricant Absence de l'autorisation du fabricant	Autorisation du fabricant Considérant que le soumissionnaire groupement SAGEMCOM/GEESY est lui-même le fabricant du système antivol qui englobe, la surveillance, le contrôle à distance et l'enregistrement des données, il va de soi que les autorisations du Fabricant ne pouvait en être fournies ; Considérant, par ailleurs, que le chapitre 2 description technique des mini centrales solaires photovoltaïques, au point 2.8 intitulé Garantie Produit, il est mentionné que le groupement SAGEMCOM/GEESY a proposé trois (3) ans de garantie ; Que sous ce rapport, les non-conformités relevées par l'autorité contractante sur les autorisations du fabricant et la garantie du système de sécurité ne sont pas justifiées ;

Prescription du DAO	Manquements de Conformité constatés par l'AC	Décision du CRD
Eclairage public Nombre de Lumens minimum prévu 3863	Eclairage public Le candidat propose 3 000 Lumens ; il n'a pas respecté le nombre de Lumens	Eclairage public Considérant, toutefois, qu'en réponse à la demande d'éclaircissement du soumissionnaire l'autorité contractante avait admis « que les spécifications du DAO relatives aux ampoules LED de l'éclairage public sont celles d'une ampoule LED de 26 W qui correspond à 3377 lumens et qu'une lanterne ayant une ampoule de puissance minimum de 15 W (LED) ayant de bonnes caractéristiques peut être acceptée car le but est de réduire la consommation énergétique et optimiser l'impact de l'éclairage public sur la mini-centrale » ; Qu'à cet effet, le soumissionnaire a proposé une ampoule de 23 W ayant de bonnes caractéristiques provenant d'un fabricant de renommée OSRAM ; Qu'ainsi la non-conformité avancée par l'autorité contractante sur le nombre de lumens minimal n'est pas fondée ;
Lampes Lampes demandées Lampes de 8w	Lampes Lampes proposées Le candidat a fourni des lampes de 9w	Lampes Considérant que l'autorité contractante estime que le soumissionnaire a proposé les lampes de 9W alors qu'il était demandé des lampes de 8W ; Considérant que sur ce différend technique, il y a lieu de préciser que compte tenu de la technologie de l'ampoule demandée, les lampes LED de 8W sont fréquentes tandis que d'autres types de lampes de 8W sont plus rares à trouver sur le marché ; Considérant, par ailleurs, que la différence de 1W peut être « négligeable » en rapport avec le facteur d'échelle, de la simultanéité à la consommation et du dimensionnement préalable ; Qu'il en résulte que même si le groupement n'est pas conforme en proposant 9W au regard de la spécification de 8W demandée, la commission des marchés aurait pu s'assurer que l'efficacité recherchée est compromise par la différence de 1W ; Que de ce point de vue la non-conformité soulevée par l'autorité contractante n'est pas justifiée ;

Prescription du DAO	Manquements de conformité	Décision du CRD
Câbles Les courants admissibles des câbles pour les installations Intérieures doivent respecter les prescriptions du DAO	Câbles Les courants admissibles des câbles pour les installations intérieures ne respectent pas les prescriptions du DAO	Câbles 12) Constate qu'au regard des conclusions du rapport d'expert en date du 21 mars 2018, les non-conformités soulevées par l'autorité contractante à l'encontre du soumissionnaire ne sont pas avérées ; Il s'agit de caractéristiques standards à tous les câbles.

10. Les observations sur les tableaux ci-dessus sont les suivantes

- a) **Formation** : l'absence du programme de formation, pièce pourtant expressément requise par le DAO, n'a pas invalidé l'offre du requérant. Une **offre non exhaustive** peut être retenue si l'objet de la pièce manquante est pris en compte dans l'exécution du marché.
- b) **Conception** L'autorité contractante reproche au candidat de ne pas proposer la séparation des installations, lorsqu'elles dépassent 50 kw. Le candidat estime que cette séparation ne sera plus nécessaire puisqu'il propose 2 stations 25 kwc ; qu'il n'y a pas de différence entre une station de 50 kwc et deux stations de 25 kwc. Le CRD précise ce point dans la motivation de sa décision, comme suit ;

Qu'il s'impose de faire la différence entre kilo watt (kw) et kilo crête (kwc) ;

Considérant que KW fait référence à une puissance de sortie onduleur (puissance active) et kwc faisant référence à la puissance totale du générateur photovoltaïque qui est l'ensemble des panneaux installés ; Considérant que le groupement SAGEMCOM/GEESY fait référence à la puissance totale du générateur photovoltaïque (kwc) et que l'ASER fait référence à la puissance de sortie onduleur (kw) ;

Que sous ce rapport, la commission des marchés doit s'assurer qu'elle traite de la même unité de mesure et du même objectif recherché avec le groupement avant de le déclarer non conforme pour le point relatif à la conception ;

On constate par cet exemple qu'une offre peut être **formellement non-conforme** (l'autorité contractuelle commande une centrale de 50kw et le candidat lui en propose deux de 25kwc), mais retenue.

- c) **Panneau d'éclairage et batteries.** Une offre conforme peut être une offre **formellement différente** de celle objet de la commande publique. Dans l'espèce, le DAO commande un certificat de conformité de test d'un type bien spécifié. Le CRD accepte que ce produit soit remplacé par un autre dès lors qu'il garantit la fiabilité des tests prescrits.
- d) **Coefficient de distorsion des onduleurs.** Le coefficient de distorsion exigé est de 3 %. Le candidat propose un coefficient de 4 %. Son offre est non conforme, en principe. Le CRD décide cependant que, même si le requérant «**n'est pas conforme**» sur ce point, le taux de distorsion qu'il propose «**donnerait le même effet recherché par l'AC**». Ici, la conformité est déterminée par rapport aux résultats recherchés. Une offre peut donc être non conforme, mais être retenue, si elle garantit le même résultat recherché.
- e) **Absence de l'autorisation du fabricant.** Le CRD constate que cette pièce est effectivement manquante. L'offre devrait être considérée comme **non conforme** pour **non-exhaustivité**. Le CRD décide cependant qu'elle est

conforme, parce que la pièce exigée n'est pas nécessaire, étant donné que le candidat est aussi le fabricant de ce produit. L'approche juridique aurait consisté à demander au requérant de se donner cette autorisation, en signant un document établi à cet effet.

- f) **Éclairage public.** Le DAO exige 3863 Lumens alors que le requérant n'en propose que 3000. Il y a là une **non-conformité formelle** que le CRD ne retient pas comme pouvant justifier le rejet de l'offre.

Le CRD explique en effet que la différence des Lumens tient au type d'ampoules **LED** proposé par le requérant ; ces ampoules assurent une bonne luminosité. Elles doivent être acceptées, car le but recherché est de réduire la consommation énergétique et d'optimiser l'impact de l'éclairage public sur la mini-centrale.

- g) **Lampes.** Le DAO prescrit les lampes de 8w. Le requérant propose des lampes de 9w. En principe, l'offre est formellement non conforme. Le CRD la valide tout de même, "considérant que la différence de 1W peut être **«négligeable» «en rapport avec le facteur d'échelle de la simultanéité à la consommation et du dimensionnement préalable»**."
- h) **Câbles.** Le DAO exige des prescriptions particulières pour les câbles que le requérant n'a pas respecté. Le CRD n'invalide pas l'offre à cet effet parce qu'un Rapport d'expert a établi que les caractéristiques de ces câbles sont standards et s'appliquent à tous les câbles.

11. À la fin de la motivation de sa décision dans la présente espèce, le CRD a dévoilé l'idée directrice qui l'a conduit. Il rappelle qu'il y a une différence de 4 300 000 000 (quatre milliards trois cent millions) FCFA entre l'offre financière de l'attributaire et celle du requérant. Au regard des motifs invoqués par l'autorité contractante, le rejet de cette offre moins disante «ne confirme pas une bonne application du principe de l'économie». **Le CRD saisit cette occasion pour définir le principe d'économie en ses termes**

Considérant que l'importante différence de 4 300 000 000 F CFA HT (quatre milliards trois cent millions de francs CFA HT) entre l'offre financière de l'attributaire provisoire et celle du requérant ne confirme pas une bonne application du principe de l'économie ;

*Que pour la sauvegarde de ce principe, l'autorité contractante avait la possibilité de recourir aux dispositions de l'article 69 du Code des Marchés publics qui prévoit que la commission peut demander aux candidats de préciser la teneur de leurs offres afin d'en faciliter **l'examen, l'évaluation et la comparaison** ; que cette demande doit être faite par écrit dans le respect strict des cahiers des charges et que la réponse doit également être adressée par écrit ;*

Considérant que l'autorité contractante n'a pas recouru à cette possibilité qui lui aurait éventuellement permis de disposer d'informations complémentaires nécessaires sur les offres techniques pour une meilleure évaluation des offres ;

Qu'en agissant ainsi l'autorité contractante a omis, sans raison connue, de mettre à profit des dispositions pertinentes de la réglementation pour

*disposer d'une offre conforme et économiquement avantageuse dans un souci de rationaliser l'utilisation des fonds publics ;
Qu'en considération de ce qui précède, il y a lieu d'ordonner l'annulation de l'attribution provisoire et la reprise de l'évaluation ;*

Le CRD annule l'attribution provisoire du marché et ordonne la reprise de l'évaluation.

2^e espèce

B. L'affaire Groupement SAGEMCOM/GEESY, Décision n° 122 du 29 août 2018

12. Suite à la décision du CRD n° 40 du 28 mars 2018, l'autorité contractante reprend l'évaluation des offres. À l'issue de cette évaluation, l'offre du Groupement SAGEMCOM avait été à nouveau rejetée. Après un recours gracieux infructueux, devant l'autorité contractante, le requérant conteste l'attribution provisoire. Par décision n° 46 du 9 juillet 2018, le CRD déclare le recours recevable, ordonne la suspension de la procédure ainsi que la transmission des documents du marché. Statuant au principal dans la présente décision n° 122 du 29 août 2018, le CRD annule l'attribution provisoire et ordonne à nouveau la reprise de la produire.

13. Pour écarter à nouveau l'offre du requérant, l'autorité contractante n'a pas repris les critères non éliminatoires rejetés par le CRD dans sa décision du 28 mars 2018. Pour éliminer le candidat, elle s'est appuyée sur la conception de l'ouvrage et la qualité du matériel.

S'agissant en particulier de la conception, les divergences portent sur les spécificités techniques des onduleurs. Le CRD a reconnu que la proposition du requérant entraînerait une différence de puissance équivalant à 99 onduleurs bidirectionnels. Le CRD constate alors que la non-conformité relevée par l'autorité contractante n'est pas liée à la conception des mini centrales, mais à un gap d'onduleurs chargeurs. Le CRD décide alors :

- 11) Dit que la « non-conformité » alléguée n'est pas substantielle ;*
- 12) Dit, de surcroît, que le gap de 99 onduleurs-chargeurs, invoqué par l'autorité contractante ne justifie pas l'écart de quatre milliards trois millions de francs (4300 000 000) F CFA HT pour les deux (02) lots, entre l'offre financière du requérant et celle de l'attributaire provisoire ;*

14. Au-delà des enjeux économiques, relevés à juste titre par le CRD, la jurisprudence SAGECOM/GEESY soulève la question de la force juridique des clauses du DAO. Les soumissionnaires sont tenus de les respecter et ne peuvent pas les modifier. Dans cette espèce, l'autorité contractante rappelle au CRD que les clauses du DAO avaient reçu l'avis de non-objection de la DCMP et que le requérant **«tente de les redéfinir»**. Cette affirmation tient au nombre relativement élevé de non-conformités que le CRD a validées dans cette affaire, en raison des enjeux financiers du marché. On peut imaginer que la méthode du CRD n'aurait pas été la même, si la

différence entre les offres financières de l'attributaire et du requérant était raisonnable. Il est fréquent en effet que le CRD valide l'attribution d'un marché à un candidat qui n'est pas moins disant.

15. De nombreuses décisions du CRD portent sur l'évaluation des offres.

Plusieurs motifs justifient le rejet des offres pour non-conformité. Ainsi, le matériel médical n'est pas conforme (*ARMP/CRD 180 du 19 Décembre 2018 Société Technologies Services*) ; l'offre économiquement plus chère est rejetée et l'offre moins chère, conforme est retenue (*ARMP/CRD 100 du 25 Juillet 2018 Biotech Services*) ; gilets de sauvetage non conformes (*ARMP/CRD 035 du 21 Mars 2018 Groupe Speedo Europe Affaires*) ; le candidat ne fait aucune proposition sur les demandes d'offres (*ARMP/CRD 094 du 11 Juillet 2018 Entreprise Groupe Sene Ingénierie (GSI)*) ; liste des produits non conformes, jours de nettoyage non conformes (*ARMP/CRD 067 du 02 Mai 2018 Société ESEF SUARL*) ; non-conformité des pièces fournies (*ARMP/CRD 156 du 02 Octobre 2019 Société Ecorel*).

Dans d'autres cas, l'offre est conforme ; c'est à tort que le candidat a été écarté ; la procédure d'attribution du marché est annulée. L'annulation peut porter sur tout le marché, lorsque l'offre est conforme dans son entièreté, comme c'est le cas dans les affaires Groupement SAGEMCOM analysées ci-dessus. Lorsque la conformité est partielle, ne porte que sur certains lots qualifiés non conformes à tort, l'annulation est partielle ; elle ne porte que sur les lots concernés qui devront faire l'objet d'une nouvelle évaluation (*ARMP/CRD 01 du 03 Janvier 2018 Société GTS* ; *ARMP/CRD 006 du 17 Janvier 2018 Fourniture et Ingénierie SAU* ; *ARMP/CRD 088 du 27 Juin 2018 Générale D'Entreprise*). L'offre non exhaustive est non conforme (*ARMP/CRD 039 du 28 Mars 2018 Office National de L'Assainissement du Sénégal (ONAS)*). Toutefois, elle est conforme si les informations censées figurer sur l'item manquant se retrouvent dans d'autres documents contractuels (*ARMP/CRD 146 du 24 Octobre 2018 Société Grands Travaux & Services (GTS)*).

L'engagement de mettre l'offre en conformité après l'ouverture des prix est irrecevable ; il porte atteinte au principe de l'intangibilité de l'offre (*ARMP/CRD 136 du 10 Octobre 2018 Entreprise AEE Power*).

8

Délégation de service public (DSP)
Affermage
Conformité des offres
Non-conformités substantielles
Biens de retour et biens de reprise
CMP14 Art. 60.4 ; 68.2 ; 70 ; 82

1^{er} espèce

Sénégalaise des Eaux (SDE)
Décision n° 27 du 13 février 2019

PAR CES MOTIFS :

1) *Constate que SDE conteste la régularité de la procédure de passation pour défaut de notification des motifs de rejet de l'offre, dépassement du délai d'évaluation et prise en compte de critères non prévus dans le DAO ;*

2) *Dit que le CRD, prenant en compte l'impérieuse nécessité de respecter le principe du contradictoire, a permis à SDE de disposer du mémorandum du MHA et d'apporter sa version, en complément du recours contentieux ;*

3) *Dit que le moyen soulevé par SDE sur l'irrégularité de la procédure n'est pas fondé ;*

4) *Constate que SDE a projeté 408 000 branchements sociaux, en considérant que la quantité de 85 000 branchements sociaux, indiquée dans les documents de l'appel d'offres, ne concerne que la période 2020/2021, et s'avère irréaliste sur toute la durée de la concession ;*

5) *Constate que les documents de l'appel d'offres (DAO, réponses demandes d'éclaircissements, procès-verbaux de réunion) n'indiquent pas une quantité de 408 000 branchements sociaux ;*

6) *Constate que pour justifier le nombre de branchements sociaux, SDE déclare avoir utilisé, en l'absence de précision du DAO, la répartition de la période 2020-2021 qu'elle a extrapolé à l'ensemble du programme prévu sur la durée 2020-2035 ;*

7) *Dit que SDE avait l'opportunité de faire élucider la question du nombre de branchements sociaux projetés dans le DAO, à l'occasion des demandes de clarifications ;*

8) *Dit que le grief soulevé par le MHA sur la non-conformité du nombre de branchements sociaux projetés par SDE est fondé ;*

9) *Constate que sur la rubrique « autres travaux » du Compte d'Exploitation prévisionnelle (CEP), en réponse à la demande de clarifications*

du MHA durant l'évaluation, SDE avait déclaré que la rubrique ne comporte pas de branchements sociaux ;

10) Constate que la note explicative qui accompagne le CEP de SDE fait cas de branchements sociaux dans le chapitre « autres produits »

11) Constate que dans son mémoire en réplique, SDE se borne à invoquer « une coquille » sur la note d'accompagnement qui, selon elle, ne constitue pas une pièce contractuelle au sens des 1C ;

12) Dit que le grief tiré de la modification de l'offre à la suite de la demande d'éclaircissement sur le contenu de la rubrique « autres travaux » est fondé ;

13) Constate que SDE a décidé de classer les équipements de télé-relevé en biens de reprise, arguant d'une imprécision du DAO sur ce point ;

14) Dit que SDE aurait dû demander des éclairages au lieu de prendre la décision la moins favorable pour l'autorité contractante ;

15) Dit que le grief tiré d'un classement inadéquat des biens de retour en biens de reprise est fondé ;

16) Dit que les non-conformités susceptibles d'entraîner le rejet d'une offre doivent avoir un caractère substantiel ;

17) Constate que l'autorité contractante a apprécié le caractère substantiel des non-conformités par un mode de calcul qui consiste à estimer l'incidence sur le prix exploitant de l'eau ;

18) Dit que le mode de calcul adopté, non prévu dans le DAO, a permis de conclure que les offres de SUEZ et VEOLIA sont conformes et de rejeter celle de SDE ;

19) Dit que durant l'évaluation des offres, le pouvoir d'appréciation ne doit pas amener la commission des marchés à utiliser un critère, initialement non prévu dans le DAO, pour déterminer le caractère substantiel d'une non-conformité ;

20) Dit toutefois, que l'application aux candidats d'un mode de calcul non prévu dans le DAO durant l'évaluation, est contraire au principe de transparence ;

21) Ordonne l'annulation de l'attribution provisoire et la reprise de l'évaluation ;

22) Ordonne la confiscation de la consignation ;

2^e espèce

Sénégalaise des Eaux (SDE)

Décision n° 93 du 29 mai 2019

P A R C E S M O T I F S :

1) Constate que le Ministère de l'Eau et de l'Assainissement (MEA) a procédé à la reprise de l'évaluation et a saisi la DCMP pour obtenir l'avis de non-objection avant de publier un nouvel avis d'attribution provisoire du contrat d'affermage à SUEZ Groupe ;

- 2) *Constate qu'à l'occasion de la reprise de l'évaluation, les critères d'appréciation de non-conformités, prévus par le DAO ont été appliqués ;*
- 3) *Dit que le grief tiré de la non-application de la décision du CRD n'est pas fondé ;*
- 4) *Constate que la SDE subodore une situation de conflit d'intérêt entre SUEZ Groupe, attributaire provisoire du contrat d'affermage et SUEZ International, titulaire du marché de travaux de l'usine KMS 3, en groupement avec CDE ;*
- 5) *Constate que les études, le contrôle et la supervision de l'usine KMS 3 ne relèvent pas du titulaire du contrat, en l'occurrence, le groupement SUEZ International/CDE, même si l'attributaire du contrat d'affermage est amené à faire le suivi, le contrôle et la réception des travaux ;*
- 6) *Constate que la SDE n'a pas démontré que SUEZ Groupe a pu disposer d'information liée au projet KMS 3, lui procurant un avantage sur ses concurrents dans la procédure d'attribution du contrat d'affermage, même si elle indique que SUEZ International est une filiale de SUEZ Groupe ;*
- 7) *Dit que le fait de concevoir et construire l'usine de KMS 3 par le groupement SUEZ International/CDE et la participation de SUEZ Groupe au contrat d'affermage ne constitue pas une situation de conflit d'intérêt, tel que décrit dans le DAO ;*
- 8) *Dit que le grief relatif à la situation de conflit d'intérêt n'est pas fondé ;*
- 9) *Constate que le CRD avait jugé fondées les non-conformités sur les projections de branchements, le reclassement de biens de retour en biens de reprise, et la modification qui résulte de la réponse de la SDE à la demande d'éclaircissements sans les qualifier ;*
- 10) *Constate que les critères d'appréciation de la conformité des offres sont prévus dans les Dossiers d'Appels d'Offres de la première et de la deuxième étape ;*
- 11) *Dit que le moyen tiré du non-respect de la décision du CRD et de la discrimination entre candidats, n'est pas fondé ;*
- 12) *Dit que la Commission des marchés du Ministère de l'Eau et de l'Assainissement (MEA) est fondée à conclure que l'offre de la SDE à la deuxième étape n'est pas conforme, de manière substantielle, sur le reclassement de biens de retour en biens de reprise et la projection du nombre de branchements sociaux ;*
- 13) *Dit que le rejet de l'offre de la SDE, à l'étape d'analyse des offres techniques corrigées et offres financières de la deuxième étape, est justifié ;*
- 14) *Constate que la SDE demande au CRD de vérifier les prix des branchements pour apprécier l'offre économiquement la plus avantageuse ;*
- 15) *Dit que la vérification doit viser tous les candidats, à l'étape d'analyse financière détaillée, qui ne concerne que les seules offres techniques corrigées conformes à la seconde étape ;*
- 16) *Dit qu'il n'y a pas lieu de procéder à la vérification sollicitée par la SDE sur les prix des branchements proposés par les soumissionnaires ;*
- 17) *Déclare le recours de la SDE mal fondé et le rejette, en conséquence ;*
- 18) *Ordonne la confiscation de la consignation et la poursuite de la procédure ;*

Commentaires

L Contexte et problématique

Les deux décisions du CRD ci-dessus s'inscrivent dans la branche de la commande publique relative à la **Délégation de service public (DSP)**.

Elles concernent la légalité de la passation d'un marché par le **Ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement (MHA)**. Dans les deux décisions, la requérante est la **Sénégalaise Des Eaux (SDE)** La 1^{ère} espèce ci-dessus, décision n° 27 du 13 février 2019, est relative à la **sélection d'un opérateur** pour la gestion au service public de production et de distribution d'eau potable en zone urbaine et péri urbaine au Sénégal. L'offre de la SDE est rejetée. Elle saisit le CRD pour contester le rejet. Dans sa décision n° 27 du 13 février 2019, le CRD retient un moyen parmi ceux exposés par la SDE au soutien de sa demande. Le CRD constate en effet que le Comité Technique d'Évaluation des offres (CTED) a appliqué aux candidats un mode de calcul non prévu dans le dossier d'Appel d'offres (DAO). **Le CRD constate que cette pratique est contraire au principe de transparence, annule l'attribution provisoire du marché, et ordonne la reprise de l'évaluation.**

Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement (MHA), autorité contractante, reprend l'évaluation des offres en tenant compte de la décision n° 27 du 13 février 2019 du CRD. À l'issue de cette reprise de l'évaluation, l'offre de la SDE est rejetée. Le contrat du marché d'affermage est attribué provisoirement à SUEZ GROUPE La SDE conteste cette attribution devant le CRD. Dans sa décision n° 93 du 29 mai 2019, 2e espèce ci-dessus, le CRD rejette le recours de la SDE au motif que son offre, à la 2^e étape, **n'est pas conforme de manière substantielle, sur le reclassement des biens de retour en biens de reprise.**

Ces deux décisions présentent plusieurs intérêts : Un intérêt intellectuel en ce que la qualité de leur rédaction et la complexité des questions traitées obligent à revisiter plusieurs articles importants du CMP14, à en découvrir des facettes parfois méconnues, au besoin en se référant au droit comparé. **Un intérêt opérationnel ou pratique** en ce que la jurisprudence du CRD en matière de délégation de service public n'étant pas très développée, les moyens soulevés par les différentes parties, ainsi que la motivation du CRD sont de nature à susciter un regain d'intérêt pour cette branche de la commande publique.

Il en est ainsi pour la notion de non- conformités substantielles déterminées à partir de la distinction des **biens de retour et des biens de reprise**, notions sans équivalent en matière de marchés publics. C'est le principal apport des décisions analysées.

II. Non- conformités substantielles

A. Une notion mal définie

3. Il paraît indiqué de reconstituer le contexte dans lequel l'autorité contractante a qualifié certaines non- conformités de substantielles. Les tableaux

ci-après font apparaître les arguments de la SDE, les réponses du MHA, autorité délégente ou contractante et la décision du CRD.

Arguments de la SDE à l'appui de son recours	Réponses et Arguments du MHA autorité contractante	Décision du CRD
a) Violation des articles 70, 84 et 141 CMP14 ainsi que de la charte de transparence et d'éthique (Délais fixés par ces articles non respectés. Elle demande la nullité de la procédure)	L'AC avait demandé et obtenu de la DCMP et de l'ARMP la prorogation des délais d'évaluation des offres L'article 141 n'est pas concerné par les délais Aucun texte ne sanctionne de nullité la prorogation de la procédure	MHA a reçu l'autorisation de proroger les délais d'évaluation des offres de trois semaines
b) Violation de l'article 88 CMP14 <i>SDE n'a reçu aucune explication des motifs du rejet de son offre</i>		L'AC n'a pas fait une bonne application de l'article 88 du CMP14. Le défaut de notification des motifs de rejet de l'offre n'a pas empêché SDE d'exercer son droit de recours
c) Violation de l'article 36 des instructions aux candidats du DAO L'autorité contractante s'est fondée sur les demandes des précisions pour évaluer l'offre	L'autorité contractante AC a appliqué la clause 36 IC du DAO à tous les candidats et n'a appliqué la clause 37 IC qu'aux seules offres conformes	

Arguments de la SDE à l'appui de son recours	Réponses et Arguments du MHA autorité contractante	Décision du CRD
d) Violation de l'article 60 CMP14 et 37 des Instructions aux candidats du DAO <i>Le rejet de son offre, qui est la moins disante, constitue une violation de l'article 37 du DAO</i> <i>Les réponses aux demandes de clarification ne modifient pas l'offre financière</i> <i>Les branchements sociaux ne figurent que dans la rubrique : «travaux de branchements»</i>		La désignation de l'offre la moins disante ne peut intervenir que si, au préalable, la conformité de l'offre technique révisée est conforme.
	Les réponses aux demandes de clarification constituent une modification de l'offre	La réponse de SDE à la demande de clarification a modifié l'offre
<i>Les provisions relatives aux branchements sociaux ont été validées par la Commission technique chargée de l'évaluation</i>		Le grief excipé de la non-conformité de l'offre de SDE pour non-respect des prévisions des branchements est fondé

Arguments de la SDE à l'appui de son recours	Réponses et Arguments du MHA autorité contractante	Décision du CRD
e) Conformité de l'offre <i>Pour évaluer, l'autorité contractante s'est fondée sur des éléments qui ne figurent pas en DAO en les considérant comme des preuves extrinsèques</i>		
Seuls les compteurs ont le caractère essentiel de biens de retour. La télé relève est un élément détachable des compteurs ; elle constitue un bien de reprise, sans aucune conséquence sur la continuité du service. La reprise est une faculté et non une obligation pour l'autorité contractante	La télé relève est un bien de retour conformément à l'article 35 du contrat d'affermage	Le grief tiré du classement inadéquat de télé relève en bien de reprise est fondé.
C'est le DAO qui a fait une provision globale de 482 000 branchements. La SDE n'a fait que préciser la période de leur réalisation.	SDE prévoit des branchements particuliers sans rapport avec le DAO	

Arguments de la SDE à l'appui de son recours	Réponses et Arguments du MHA autorité contractante	Décision du CRD
L'autorité se base sur la non-conformité du nombre de branchement et la formule de calcul utilisée pour conclure au caractère substantiel de la non-conformité Il y a là rupture d'égalité de traitement des candidats	La vérification de l'impact des non-conformités ne constitue pas une évaluation détaillée des offres. L'offre de SDE n'a pas fait l'objet d'une évaluation détaillée en raison de sa non-conformité L'offre comporte d'autres produits non prévus comme les produits relatifs aux travaux de renouvellement dans la rubrique «autres travaux».	19) Dit que durant l'évaluation des offres, le pouvoir d'appréciation ne doit pas amener la commission des marchés à utiliser un critère, initialement non prévu dans le DAO, pour déterminer le caractère substantiel d'une non-conformité ; 20) Dit, toutefois, que l'application aux candidats d'un mode de calcul non prévu dans le DAO durant l'évaluation, est contraire au principe de transparence ; 21) Ordonne l'annulation de l'attribution provisoire et la reprise de l'évaluation ;
	SDE a pris volontairement des branchements particuliers pour des branchements sociaux	

4. L'appréciation des non-conformités substantielles par le CRD s'est effectuée dans les conditions ci-après

Le CRD reconnaît "**l'existence des non-conformités jugées substantielles**" dans l'offre de la SDE. Elles sont les suivantes :

*la décision de classer des équipements de la télé relève en biens de reprise ;
les prévisions de branchements sociaux sur la base de quantités non prévues dans le DAO ;
la réponse à la demande d'éclaircissements sur la rubrique «autres produits» du compte d'exploitation, qui prévoit les branchements sociaux ;*

En revanche, le CRD constate que le mode d'évaluation qui a conduit l'autorité contractante à qualifier ces non-conformités de «substantielles» n'était pas prévu dans le DAO. La motivation de décision sur ce point est ainsi conçue ;

Que cependant, la méthode d'estimation de l'incidence financière des non-conformités pour apprécier leur caractère substantiel, n'a pas été prévue dans le dossier d'appel d'offres.

Le dispositif formalise ainsi la décision

*19) Dit que durant l'évaluation des offres, le pouvoir d'appréciation ne doit pas amener la commission des marchés à utiliser un critère, initialement non prévu dans le DAO, pour déterminer le caractère substantiel d'une non-conformité ;
20) Dit, toutefois, que l'application aux candidats d'un mode de calcul non prévu dans le DAO durant l'évaluation, est contraire au principe de transparence ;
21) Ordonne l'annulation de l'attribution provisoire et la reprise de l'évaluation ;*

En d'autres termes, l'autorité contractante peut prévoir dans son DAO, des conformités qu'il qualifie de substantielles. Mais le mode de calcul et d'évaluation qui permet de décider qu'une non-conformité présente un caractère substantiel doit être prévu par le DAO. En l'espèce, c'est en cours d'évaluation que la commission a utilisé ce critère d'évaluation. Il y a donc lieu d'annuler l'attribution provisoire et de reprendre l'annulation.

B. Des critères souples et une portée limitée

5. En exécution de la décision du CRD, n° 27 du 13 février 2019, le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement (MHA), devenu ministre de l'Eau et de l'Assainissement (MEA), avait actualisé le Dossier d'Appel d'Offres pour y intégrer les critères d'évaluation des offres dont la non-conformité présente un caractère substantiel et qui, de ce fait, doivent être rejetées. Les dispositions actualisées du DAO de la 2^e étape sont reprises ainsi dans la motivation de la décision n° 93 du 29 mai 2019, 2^e espèce ci-dessus

Considérant que le Dossier d'appel d'offres de la deuxième étape prévoit, à la clause IC 36.4, l'évaluation de la conformité des offres et, stipule à la clause IC 29.2, que les divergences ou omissions substantielles sont celles qui

« Si elles étaient acceptées, limiteraient de manière substantielle la portée, la qualité des prestations spécifiées dans le contrat ; ou limiteraient, d'une manière substantielle et non conforme au dossier d'Appel d'Offres, les droits de l'Autorité contractante ou les obligations du Candidat au titre du contrat ou

Dont l'acceptation serait préjudiciable aux autres candidats ayant présenté des Offres conformes pour l'essentiel » ;

À partir de ces nouveaux critères d'évaluation, le CRD s'est assuré que la Commission Technique d'Évaluation des Offres (CTEO) a vérifié leur application aux Offres non-conformes de la SDE et a constaté l'effectivité de cette application. Ainsi

5.1. Le classement des biens de retour en biens de reprise est une non-conformité substantielle parce qu'elle «limite, d'une manière non conforme au Dossier d'Appel d'Offres, les droits de l'autorité contractante»

5.2. Les prévisions des branchements sociaux, non prévues dans le DAO, constituent une non-conformité substantielle, parce qu'elle **«limite l'autorité contractante dans ses décisions concernant ces branchements dont le financement doit être assuré par le concessionnaire».**

5.3. Le CRD, n'a retenu que ces deux non-conformités substantielles. Il n'a pas reconnu le caractère substantiel à la présence de produits non conformes au niveau de la rubrique «autres travaux».

5.4. L'intérêt pratique de la non-conformité substantielle, c'est d'introduire une certaine souplesse dans l'évaluation des offres. Cette notion permet de ne pas rejeter toutes les Offres qui présentent un écart par rapport aux critères pré établis. Seules seront écartées les Offres dont les non-conformités affecteront la procédure de passation de marché, les pouvoirs de l'autorité contractante, ou d'autres critères qui seront fixés au cas par cas.

Cette volonté d'introduire la souplesse dans l'évaluation des Offres est louable. Toutefois elle comporte des effets pervers.

Ainsi, il ne paraît pas logique de constater une non-conformité et de n'en tirer aucune conséquence sur l'attribution ou non du marché. À l'arrivée, l'Offre sera attribuée à deux catégories de candidats : ceux dont les offres sont conformes, et ceux dont les offres sont non conformes, mais sans que la non-conformité présente un caractère substantiel. Il était préférable d'inscrire dans les DAO **les critères de conformité** et, le cas échéant, de les rendre aussi sévères ou aussi larges que l'exigent les particularités du marché. Le principe sera ainsi maintenu que **c'est l'offre conforme qui est retenue.**

5.5. Finalement, la portée des non-conformités substantielles est limitée : Cette notion ne s'applique que dans les DAO dans lesquels elle est prévue. Au regard du Code des marchés, toute **non-conformité** entraîne le rejet de l'Offre, sans qu'il soit

besoin de procéder à l'évaluation de son degré de non-conformité, d'autant que les critères pour une telle évaluation n'existent pas dans le CMP14.

Il en va autrement pour les biens de retour et les biens de reprise en matière de délégation de service public. Cette question peut faire l'objet de réglementation en matière de délégation de service public.

III. Classement des biens de retour en biens de reprise Une non-conformité substantielle

6. En matière de délégation de service public, les biens sont classés en trois catégories

- a) **Les biens de retour** sont les biens meubles et immeubles qui font retour, gratuitement, à la collectivité publique délégante en fin du contrat. Ils sont indispensables à l'exécution du service public délégué.
- b) **Les biens de reprise** sont ceux qui n'ont pas été remis au délégataire par la collectivité publique délégante en vue de leur gestion. Ils ne sont pas indispensables au fonctionnement du service public, mais peuvent être utiles à cet effet. Ils peuvent, si la convention de DSP le prévoit, être amortis pendant l'exécution du contrat. En fin de contrat, deux options sont possibles : ils sont repris par les délégataires ; ou bien, ils peuvent être rachetés par la collectivité publique moyennant un prix correspondant à sa valeur vénale. Le rachat des biens de reprise n'est pas une obligation pour la collectivité publique.
- c) **Les biens propres** sont ceux du délégataire. Ils restent sa propriété, sauf accord avec l'autorité délégante.

Étant donné les enjeux financiers de la distinction de ces biens, leur inventaire ou leur classement doit rigoureusement tenir compte de leur nature.

6.1. Le classement de certains biens présente des difficultés ; c'est le cas pour la télé-relève. C'est un dispositif qui permet de lire les compteurs d'eau ainsi que certaines informations sans qu'il soit besoin d'accéder physiquement aux compteurs.

Dans le DAO, il n'était pas prévu qu'ils seraient inventoriés comme biens de retour ou biens de reprise. Dans son offre, la SDE les a classés comme bien de reprise. Le CTEO considéra ce dispositif comme **biens de retour** et que leur classement en biens de reprise constitue **une non-conformité substantielle** entraînant le rejet de l'offre.

6.2. La SDE soutient toujours que la télé-relève constitue un bien de reprise. Ses arguments sont les suivants

- a) Le DAO ne donne aucune directive pour le classement de ce bien.
- b) Sa classification en bien de reprise figurait déjà dans son offre technique de départ sans que l'autorité contractante le conteste. Sa non-conformité ne peut être soulevée à la seconde étape de la procédure de passation de marché

c) Le dispositif de télé-relève comprend trois parties, avec un complément amovible qu'on peut enlever sans impact sur la lecture manuelle du compteur, ni sur la continuité du service. Ce dispositif n'est donc pas indispensable au fonctionnement du service

d) La reprise n'est pas une obligation, mais une option pour l'autorité contractante.

6.3. Le CRD n'a pas été convaincu par les arguments de la SDE. **Déjà, dans sa décision n° 27 du 13 février 2019 (1^{er} espèce ci-dessus)**, se fondant sur le DAO de la 2^e étape du marché, ainsi que sur la jurisprudence française, admettait que le dispositif de télé-relève appartient à la catégorie des biens de retour. Il motivait sa décision comme suit

Considérant qu'il résulte de l'article 7 du dossier d'appel d'offres (deuxième étape) « contrat d'affermage » que les biens de retour sont les biens essentiels au service affermé du fermier, qui reviennent obligatoirement et gratuitement en bon état de fonctionnement, à l'expiration du contrat d'affermage, à l'autorité délégante ;

Considérant que SDE, se prévalant du silence du DAO sur le classement des équipements de télé-releve en biens de retour ou de reprise, a pris l'option de les classer en biens de reprise, arguant du fait qu'ils peuvent être détachés des compteurs (technologie amovible) et ne sont pas substantiels pour la continuité du service ;

Qu'au lieu de prendre la précaution de demander des éclairages ou précisions au MHA sur la nature des biens, compte tenu de leur incidence financière et de leur relations avec les compteurs, SDE a pris la décision la moins favorable pour l'autorité délégante, en classant les biens de la télé-releve en biens de reprise ;

Que du reste, selon la jurisprudence, en l'espèce (cf Conseil d'État en France arrêt de Commune de Douai), « dans le cadre d'une délégation de service public ou d'une concession de travaux mettant à la charge du cocontractant les investissements correspondant à la création et à l'acquisition des biens nécessaires au fonctionnement du service public, l'ensemble de ces biens, meubles ou immeubles, appartient, ab initio dans le silence de la convention, dès leur réalisation ou leur acquisition à la personne publique » ;

Le dispositif de la décision confirme cette motivation en ses termes.

2) *Constate que SDE a décidé de classer les équipements de télé-releve en biens de reprise, arguant d'une imprécision du DAO sur ce point ;*

3) *Dit que SDE aurait dû demander des éclairages au lieu de prendre la décision la moins favorable pour l'autorité contractante ;*

4) *Dit que le grief tiré d'un classement inadéquat des biens de retour en biens de reprise est fondé ;*

Il y a lieu d'observer que dans cette décision du 13 février 2019, le CRD se borne à constater et admettre que **la télé- relève est un bien de retour**, sans se prononcer sur la question de sa conformité.

Dans sa décision n° 93 du 29 mai 2019, le CRD statue sur le fondement d'un DAO corrigé ou complété, dans lequel l'autorité contractante a défini les critères du

caractère substantiel de la non-conformité. Il applique alors ce critère au classement par la SDE de la télé-relève en bien de reprise et constate qu'au regard du DAO corrigé, un tel classement constitue une non-conformité substantielle. La motivation du CRD est la suivante :

Qu'en ce qui concerne le classement de biens de retour en biens de reprise, le caractère substantiel de la non-conformité, déjà relevée par le CRD, est lié au fait qu'elle limite d'une manière non conforme au Dossier d'Appel d'Offres, les droits de l'Autorité contractante, même avec l'option d'achat sur les équipements de télé-relève ; le manque de clarté du DAO, allégué par le requérant, ne peut justifier sa décision de classer ce bien en bien de reprise alors que les candidats avaient toute la latitude d'adresser des demandes de précisions ;

Le dispositif de la décision confirme cette motivation en ses termes

12) Dit que la Commission des marchés du Ministère de l'Eau et de l'Assainissement (MEA) est fondée à conclure que l'offre de la SDE à la deuxième étape n'est pas conforme, de manière substantielle, sur le reclassement de biens de retour en biens de reprise et la projection du nombre de branchements sociaux ;

13) Dit que le rejet de l'offre de la SDE, à l'étape d'analyse des offres techniques corrigées et offres financières de la deuxième étape, est justifié ;

Les décisions n° 27 du 13 février 2019 et n° 93 du 29 mai 2019 font jurisprudence quant à la définition du bien de retour de délégation de service public. Elles vont contribuer à la réforme de la réglementation de la commande publique sur cette question.

7. Dans sa décision n° 27 du 13 février 2019, 1^{er} espèce ci-dessus, le CRD fait référence à l'arrêt d'Assemblée du Conseil d'État français du 21 décembre 2012 dans l'affaire **Commune de Douai**.

7.1. Cette référence est particulièrement productive et opportune. En effet, le droit français de délégation de service public est en passe d'être généralisé au niveau de l'Union Européenne. La réglementation sénégalaise en matière de commande publique devrait s'inscrire dans la même logique.

À cela s'ajoute que l'apport de la jurisprudence est inestimable pour le progrès de la réglementation. C'est par des décisions d'organes juridictionnels ou quasi juridictionnels que sont établis des repères à partir desquels se développe la réglementation.

Sous ce rapport, l'arrêt du Conseil d'État **Commune de Douai** constitue un repère dans l'évolution du régime juridique des biens en matière de délégation de service public.

Une littérature juridique abondante a été publiée sur cet arrêt. Seules quelques questions à approfondir seront relevées.

La jurisprudence **Commune de Douai** porte sur la **concession** du service public; toutefois, elle peut s'adapter aux autres conventions de délégation de service public, notamment à l'**affermage**.

7.2. Le régime des biens de retour a été amélioré. Sa conception est plus large.

- a) Les biens de retour sont des biens nécessaires au service public ; mais c'est aussi l'ensemble des biens nécessaires au fonctionnement du service. Cette conception large issue de l'**avis** du Conseil d'État français du 19 août 2005 n'est pas remise en cause par la jurisprudence commune de Douai. Le caractère de bien de retour peut s'appliquer à la totalité des biens mis à la disposition du cocontractant, ou à certains de ces biens. Il appartient au juge d'apprécier.
- b) Les biens de retour sont propriété de l'État **ab initio**, dès leur réalisation, peu importe qu'ils soient ou non achevés.
- c) Les biens de retour font retour à la collectivité publique en fin de contrat, **gratuitement**, sous réserve de l'indemnisation du concessionnaire pour les biens non totalement amortis en fin de contrat.
- d) Les conventions entre parties ne peuvent pas déroger au caractère de bien de retour.
- e) Les implantations sur le domaine public sont des biens de retour
- f) Les implantations sur les propriétés privées sont des biens de retour si elles sont grevées de servitudes, comme en matière de tourisme.
- g) Le droit de retour peut aussi porter sur les installations nécessaires à l'exploitation de la concession.
- h) Les droits réels auxquels les concessionnaires peuvent prétendre sur ces biens sont déterminés selon le Code de la propriété.

7.3. Les biens de reprise appartiennent au délégataire. Les conventions de DSP déterminent les conditions de leur reprise par l'autorité délégante.

7.4. Pour les biens non totalement amortis en fin de contrat, l'indemnité à laquelle peut prétendre le concessionnaire ne peut excéder un montant correspondant à leur **valeur nette comptable**.

9

Délégation de service public (DSP) Référé administratif de suspension

*Cour suprême du Sénégal
Ordonnance n° 05 du 10 octobre 2019
Affaire SDE c/ ARMP et État du Sénégal*

Vu la requête reçue le 22 juillet 2019 au greffe central de la Cour suprême par laquelle la Société sénégalaise des Eaux dite SDE, représentée par son directeur général, élisant domicile aux études de Maîtres Coumba Séye Ndiaye, Alioune Cissé et la SCP Wane et Fall, avocats à la Cour, sollicite la suspension de l'exécution des actes ci-après cités et de leurs effets :

- la décision n° 093/19/ARMP/CRD/DEF rendue le 29 mai 2019 par le Comité de Règlement des Différends (CRD) de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) dans l'affaire relative à la procédure d'Appel d'Offres lancé par le ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement pour la sélection d'un opérateur chargé de la gestion du service public de production et de distribution d'eau potable en zone urbaine et péri-urbaine ;

-la décision d'attribution du contrat d'affermage à SUEZ GROUPE, notifiée par la correspondance n° 00519/MEA/DAGE/CM du 17 juin 2019 ;

Vu la requête en date du 5 juillet 2019, enregistrée au greffe central sous le n° 278, par laquelle la SDE sollicite l'annulation des décisions susvisées ;

.....
Par ces motifs •

En la forme

*Rejette les exceptions soulevées ;
Déclare la SDE déchue de son recours contre la décision d'attribudon provisoire du contrat d'affermage ;*

Au fond

Dit n'y avoir lieu d'ordonner la suspension de la décision n°093/19/AR1v1P/CRD/DEF rendue le 29 mai 2019 par le Comité de Règlement des Difnr;nds (CRD) de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) dans l'affaire relative à la procédure d'Appel d'Offres lancé par le Ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement pour la sélection d'un opérateur chargé de la gestion du service public de production et de distribution d'eau potable en zone urbaine et péri-urbaine.

Commentaires

I. Les faits et la procédure

La Cour suprême du Sénégal, statuant comme juge de référé administratif aux fins de suspension a, par une Ordonnance du 10 octobre 2019, rejeté la demande de suspension introduite par la Sénégalaise des Eaux (SDE), dans l'affaire qui l'oppose à SUEZ GROUPE. Le contexte de cette affaire est le suivant.

1. Au courant de l'année 2017, le Ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement, devenu Ministère de l'Eau et de l'Assainissement, avait engagé une procédure d'appel d'offres international avec pré-qualification et en deux étapes, pour la sélection d'un opérateur chargé de la gestion du service public de production et de distribution d'eau potable en zone urbaine et péri urbaine. Trois sociétés avaient déposé un pli à la date limite de réception des dossiers : la Sénégalaise des Eaux (SDE), Suez Groupe et Veolia Eau-compagnie des Eaux.

2. Au terme du processus de passation, le Ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement avait poursuivi la procédure comme suit :

- a) Par décision du 23 octobre 2018, le ministre procède à **l'attribution provisoire** à SUEZ GROUPE de la délégation de service public.
- b) Par décision n° 27 du 13 février 2019, le CRD annule cette attribution provisoire et ordonne la reprise de l'évaluation.
- c) A l'issue de la reprise de l'évaluation, l'offre de la SDE est rejetée. Le 30 avril 2019, suite à l'échec de son recours gracieux, la SDE attaque cette décision du Ministre devant le Comité de Règlement des Différends (CRD) de l'ARMP.
- d) Le CRD rejette le recours de la SDE, par décision n° 93 du 29 mai 2019,
- e) Par décision n° 519 du 17 juin 2019, le Ministre de l'Eau et de l'Assainissement procède à **l'attribution définitive** du contrat d'affermage à SUEZ GROUPE.
- f) Le 5 juillet 2019, la SDE introduit deux recours en annulation devant la Cour suprême
 - Un recours en annulation contre la décision n° 93 ARMP/CRD du 29 mai 2019 (ci-dessus visée). Dans cette instance, la SDE s'oppose à l'ARMP, représenté par son Directeur général.
 - Un recours en annulation contre la décision du Ministre n° 519 MEA/DAGE du 17 juin 2019. Dans cette instance, elle s'oppose à l'Etat, représenté par l'Agent judiciaire de l'Etat.

3. En attendant les suites de ses recours en annulation, la SDE engage la procédure de référé administratif aux fins de suspension. À cet effet, elle introduit le 22 juillet 2019, à la Cour suprême, une requête par laquelle elle sollicite la suspension de l'exécution des deux décisions ci-dessus dont elle a demandé l'annulation, à savoir, la décision n° 93/ARMP/CRD du 9 mai 2019 ; et la décision n°519 du Ministre de l'Eau et de l'Assainissement en date du 17 juin 2019. La Cour suprême, dans son ordonnance de référé, **en la forme**, déclare la SDE déchue de son recours contre la décision **d'attribution provisoire** du contrat d'affermage. **Au fond** dit n'y avoir lieu d'ordonner la suspension de la décision n° 093/19/ARMP/CRD/DEF rendue le 29 mai 2019 par le Comité de Règlement des Différends (CRD) de l'ARMP.

Les commentaires de cette ordonnance portent sur

- les visas et le dispositif,
- la motivation,
- et le recours principal devant la Cour suprême.

II. Observations sur les visas et le dispositif de l'ordonnance de référé n° 05 du 10 octobre 2019

5. Le dispositif de l'ordonnance de référé n° 05 du 10 octobre 2019 est ainsi conçu.

Par ces motifs

En la forme

Rejette les exceptions soulevées ;

Déclare la SDE déchue de son recours contre la décision d'attribution provisoire du contrat d'affermage ;

Au fond

Dit n'y avoir lieu d'ordonner la suspension de la décision n° 093/19/ARMP/CRD/DEF rendue le 29 mai 2019 par le Comité de Règlement des Différends (CRD) de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) dans l'affaire relative à la procédure d'Appel d'Offres lancé par le Ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement pour la sélection d'un opérateur chargé de la gestion du service public de production et de distribution d'eau potable en zone urbaine et péri urbaine.

Les observations sont relatives aux conséquences ainsi qu'aux suites de l'ordonnance.

A. Conséquences du rejet de la demande de suspension

6. Le rejet par la Cour suprême de la demande de suspension des deux actes concernés a pour conséquences que ces actes continuent de produire leurs pleins effets.

a) A titre préliminaire, il y a lieu de constater que Il y a lieu d'observer ce qui suit, s'agissant de la décision du Ministre n° 519 du 17 juin 2019. Dans ses visas, l'ordonnance de la Cour suprême se réfère à cette décision ainsi qu'il suit ; « *la décision d'attribution du contrat d'affermage à SUEZ GROUPE , notifiée par correspondance n° 0519/MEA/SAGE/CM du 17 juin 2019* ». Dans son dispositif, l'ordonnance « *déclare la SDE déchue de son recours contre l'attribution provisoire du contrat d'affermage* ». Le qualificatif de provisoire n'est utilisé que dans le dispositif de l'ordonnance. En tenant compte de l'historique de l'affaire, la décision du Ministre n° 519 du 17 juin 2019 ne peut pas être une décision **d'attribution provisoire** du marché. En effet, le 23 octobre 2018, le Ministre avait pris une décision d'attribution provisoire du marché à SUEZ. Le CRD avait annulé cette attribution par sa décision n° 27 du 13 février 2019 et ordonné la reprise de l'évaluation des offres. A l'issue de cette reprise, l'offre de la SDE avait été rejetée. La SDE avait contesté ce rejet devant le CRD qui l'avait débouté de son recours par décision n° 93 du 29 mai 2019. Dans ce contexte, la décision du Ministre n° 519 du 17 juin 2019, ne peut être qu'une **décision d'attribution définitive du contrat d'affermage**. Cette décision est susceptible de recours devant la Cour suprême. C'est un

tel recours que la SDE a intenté. Le recours contre cette décision ne suspend pas son exécution, sauf s'il en est décidé autrement par le juge des référés. Justement, ce juge a rejeté la demande de SUEZ de suspension de l'exécution de cette décision.

b) En ce qui concerne la décision n°93 du CRD du 29 mai 2019, le CRD avait décidé que c'est à bon droit que le Ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement avait procédé à l'attribution provisoire de la délégation de service public à SUEZ GROUPE. La SDE soutenait le contraire. Elle contestait la légalité de cette décision du Ministre. Elle fondait sa contestation sur une série de griefs que le CRD avait examinés et rejetés dans ladite décision n° 93 du 29 mai 2019. N'étant pas satisfaite de la décision du CRD, la SDE l'avait attaquée, le 5 juillet 2019, en annulation devant la Cour suprême. Pour préserver ses droits, la SDE avait saisi la Cour suprême en formation de référé administratif, le 22 juillet 2019, pour solliciter la suspension de son exécution.

L'ordonnance de référé du 10 octobre 2019 qui rejette cette demande de suspension, signifie que la décision n° 93 du 29 mai 2019 du CRD est toujours présumée légale ; en d'autres termes, c'est à bon droit que le Ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement a procédé à l'attribution provisoire de la délégation de service public à SUEZ GROUPE.

c) En ce qui concerne la décision n°519 du Ministre de l'Eau et de l'Assainissement, on rappelle et observe ce qui suit

Cette décision procède à l'attribution définitive de la délégation de service public à SUEZ GROUPE. Elle date du 17 juin 2019, ce qui veut dire qu'elle est prise après la décision n°93 du CRD du 29 mai 2019. Le CRD ayant décidé le 29 mai 2019 que l'attribution provisoire de la délégation de service public à SUEZ GROUPE était légale, le ministre a pu, sans difficulté, transformer cet acte en décision d'attribution définitive.

La SDE avait attaqué cette décision en annulation devant la Cour suprême le 5 juillet 2019. À cette occasion, la SDE avait soutenu les mêmes griefs que ceux qu'elle avait développés, sans succès, devant le CRD.

La Cour suprême a décidé dans l'ordonnance n° 05 du 10 octobre 2019 que la SDE est déchue de son pourvoi, au motif qu'elle n'a pas signifié sa requête à l'Agent Judiciaire de l'État qui représentait l'État dans cette instance. Ce dispositif de l'ordonnance de référé signifie que la décision attaquée du Ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement reste en vigueur ; en conséquence, SUEZ GROUPE bénéficie toujours de l'attribution définitive de la délégation du service concernée.

7. Finalement, au regard de ses conséquences, le dispositif de l'ordonnance de référé n°5 du 10 octobre 2019 de la Cour suprême peut être ainsi reformulé ;

a) La décision du 23 octobre 2018 du Ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, procédant à l'attribution du contrat d'affermage de la production et de la gestion de l'eau à SUEZ GROUPE reste exécutoire et présumée légale.

b) La décision n° 519 du 17 juin 2019 du Ministre de l'Eau et de l'Assainissement, procédant à l'attribution définitive du contrat d'affermage de la production et de la gestion de l'eau à SUEZ ,... GROUPE reste exécutoire et présumée légale.

B. Suites de l'ordonnance de référé n° 5 du 10 octobre 2019

8. Lorsque le juge des référés rejette la demande, dont il est saisi, de suspension de l'exécution des décisions administratives, celles-ci ne bénéficient que **d'une présomption de légalité** : la raison en est que l'ordonnance de référé présente un caractère provisoire ; le juge de référé n'est pas saisi du recours principal.

La loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017, ci-après LOCS 2017, dispose, à cet effet, dans son article 83, al. 1 et 2.

*Art. 83 — Il est institué un juge des référés en matière administrative.
Il statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. (LOCS 2017)*

La présomption de légalité signifie que ces décisions sont présumées légales, sous réserve des suites qui seront données au recours principal. La procédure de référé ne se substitue donc pas au recours principal ; elle le précède.

En droit positif sénégalais actuel, la seule suite à l'ordonnance de référé, c'est l'intervention ultérieure de la décision judiciaire sur le principal. En l'occurrence, la suite de l'ordonnance de référé du 10 octobre 2019, c'est l'arrêt que la chambre administrative de la Cour suprême rendra suite au recours en annulation de la SDE du 5 juillet 2019 contre d'une part, la décision n° 93 du 29 mai 2019 de l'ARMP/CRD, et d'autre part la décision du Ministre de l'Eau et de l'Assainissement du 17 juin 2019 portant attribution définitive du contrat d'affermage à SUEZ GROUPE.

Au regard du droit sénégalais, après l'ordonnance de référé du 10 octobre 2019, la seule chose que la SDE peut faire, c'est d'attendre la décision de la Cour suprême sur le principal, suite aux recours en annulation du 5 juillet 2019.

9. Deux suites seront alors possibles

Théoriquement, l'arrêt de la chambre administrative sur le principal pourrait contredire l'ordonnance de référé

En effet, la procédure de la demande en annulation et celle de référé de la demande de suspension d'exécution se succèdent ; elles ne se superposent pas. Le juge de l'excès de pouvoir n'est pas tenu de suivre le juge des référés. Par exemple, le juge de l'excès de pouvoir pourrait décider que les moyens soulevés par la SDE au soutien de

sa requête sont fondés, ce qui justifierait l'annulation du contrat d'affermage attaqué. Cette issue rappelle le contentieux de l'ancienne procédure de sursis à exécution.

Dans ce contentieux du sursis à exécution, le juge ne pouvait suspendre l'action administrative que lorsque l'annulation de l'acte attaqué lui paraissait très probable, voire certaine, bien qu'il n'était pas vérifié que toutes les fois que le sursis avait été accordé, l'acte attaqué avait été certainement annulé.

En fait cependant dans la présente espèce, au regard de la motivation du juge des référés, il est probable que la chambre administrative de la Cour suprême, juge de l'excès de pouvoir, suivra le juge des référés et rejettera le recours de la SDE.

III. Observations sur la motivation du juge des

référé A. Motifs de procédure

a. Reprise, dans l'ordonnance de référé, du dispositif de la décision n° 093/ARMP/CRD du 29 mai 2019

10. L'ordonnance reproduit dans son intégralité le dispositif de la décision n° 093/ARMP/CRD du 29 mai 2019, attaquée par SDE. Cette reproduction ne se situe pas dans la zone des visas. Elle n'est pas précédée de l'expression «Vu» qui annonce un libellé de visa. Au fait d'ailleurs, cette décision est déjà visée en 2^e position dans l'ordonnance, de manière particulièrement détaillée; de même, est visée la décision d'attribution attaquée du contrat d'affermage.

Le dispositif reproduit est précédé du terme «considérant» qui annonce la formulation d'une motivation du juge. Il se trouve donc dans la zone des motifs de l'ordonnance. On pourrait donc penser que le juge l'a reproduit pour le rejeter comme il a énoncé les exceptions de l'ARMP pour les rejeter, ce qui n'est pas le cas. On pourrait aussi penser qu'il a repris ce dispositif en rapport avec les conditions de recevabilité de la demande de référé suspension, par exemple parce qu'il justifie l'existence ou non de l'urgence, ou l'existence ou non d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées, ce qui n'est pas le cas

b. Exceptions soulevées par l'ARMP

11. Les exceptions visent à rendre le recours en annulation irrecevable. Si elles sont accueillies et fondées, le recours en annulation intenté par SDE sera irrecevable ; dans ce cas, le juge de référé ne pourra pas accueillir sa demande de suspension. L'ARMP soulevait deux exceptions.

En premier lieu l'ARMP soutenait que la requête de la SDE était irrecevable en ce qu'elle ne comprend ni l'adresse, ni le nom de l'Autorité de Régulation des marchés publics dont la décision est attaquée, en violation des prescriptions de l'article 33 de la loi organique sur la Cour suprême. La Cour rejette cette exception, considérant que l'ARMP a reçu signification de la requête principale et a fait valoir ses moyens de défense dans les délais prévus par la loi ; qu'elle «ne justifie d'aucun préjudice découlant du défaut d'indication des mentions prévues par l'article 33 de la loi organique». La Cour ajoute :

Qu'il ressort, d'ailleurs, de l'examen de la procédure que la SDE a indiqué les noms et adresses de toutes les parties à la page 38 de la requête aux fins d'annulation déposés au greffe central de la Cour suprême ;

En second lieu, l'ARMP soutenait que la requête de la SDE est irrecevable parce qu'elle ne respecte pas l'ordre des moyens prescrit par l'article 34 de la loi organique sur la Cour suprême. La Cour rejette cette exception considérant que l'ordre de présentation des moyens prescrits par l'article 34 de l'ordonnance sur la Cour suprême concerne le recours en cassation ; que s'agissant du recours pour excès de pouvoir, c'est l'article 74 de la loi organique qui s'applique.

c. Déchéance et mise hors de cause de l'État

12. En matière de recours pour excès de pouvoir, l'article 37 de la loi organique sur la Cour suprême dispose que la requête doit être signifiée à la partie adverse, c'est-à-dire **notifiée par exploit d'huissier**. En cas de non respect, le requérant est déchu de son pourvoi. Dans la présente affaire, la SDE attaque la décision du ministre de l'eau et de l'Assainissement portant attribution provisoire du contrat d'affermage à SUEZ groupe. Elle devait signifier cette requête à l'Agent judiciaire de l'État, représentant de l'Etat. Pour ne l'avoir pas fait, **elle est déchue de son pourvoi contre l'État ; l'État est mis hors de cause**.

13. La conséquence de la déchéance du pourvoi de la SDE contre l'État, c'est que l'attribution définitive du contrat d'affermage à SUEZ groupe ne peut plus faire l'objet d'un recours direct en annulation.

14. Le procès se poursuit pour le second recours en annulation de la décision n° 93 du 29 mai 2019 de l'ARMP introduite par la SDE. Cette décision dispose que l'attribution provisoire du contrat d'affermage à SUEZ Groupe était légale. En se prévalant de cette décision, le Ministre a procédé à l'attribution définitive du contrat qui ne peut plus faire l'objet d'un recours direct en annulation par SDE. Toutefois, en cas d'annulation de cette décision du CRD, SDE aurait pu demander l'annulation par voie de conséquence, si ce moyen avait été soulevé dès l'introduction de son recours.

d. La recevabilité du mémoire en défense

15. La SDE a conclu à l'irrecevabilité du mémoire en défense de l'ARMP au motif, **d'une part**, qu'il a été adressé au Président de la chambre administrative de la Cour suprême, alors qu'il aurait dû être adressé au Premier Président, et d'autre part, qu'il mentionne en intitulé : "requête aux fins du sursis à exécution de la décision", procédure supprimée qui n'existe plus dans la loi organique sur la Cour suprême.

Cette exception a été rejetée au motif que la transmission du mémoire en défense de l'ARMP est conforme **aux règles formelles** prescrites par l'article 41 de la loi organique sur la Cour suprême.

B. Motifs de fond

16. L'article 84 de la loi organique relative à la Cour suprême énonce deux conditions cumulatives pour ordonner la suspension d'une décision administrative : il faut que l'urgence le justifie ; il faut en outre que le moyen soulevé soit propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. S'agissant de la condition de l'urgence, le juge motive :

Considérant cependant ; que la SDE, candidate malheureuse à un marché dont l'attribution provisoire a été effectuée du fait de sa situation et des intérêts qu'elle entend défendre, a un intérêt certain et direct à la suspension de l'exécution jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond ; Que, dès lors, l'urgence dont elle se prévaut est établie ;

La première condition relative à l'existence de l'urgence est donc établie. S'agissant de la condition liée au moyen invoqué, le juge passe en revue tous les griefs soulevés par la SDE contre l'attribution provisoire du marché et, pour chacun d'eux, confirme les décisions de rejet prises par le CRD dans sa décision n° 93 du 29 mai 2019. Le juge ajoute :

Qu'au demeurant, il n'est ni argué ni établi que lors de cette opération, la Commission a accompli des actes décisifs d'analyse ou de comparaison susceptibles d'entamer la régularité de la procédure par la rupture de l'égalité de traitement des candidats de nature à mettre en cause l'objectivité de l'évaluation subséquente des offres ;

Le juge conclut qu'en l'état de l'instruction **"l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision n'est pas établie"**.

La deuxième condition n'étant pas réunie, le juge rejette la demande de suspension présentée par la SDE.

IV Le recours principal devant la Cour suprême

17. Suite à l'ordonnance du 10 octobre 2019, la Cour suprême a statué au principal dans cette affaire, par **l'arrêt n°01 du 23 janvier 2020, SDE contre ARMP.**

La Cour a confirmé sur tous les points le dispositif de décision n° 93 du 29 mai 2019 de l'ARMP, et rejeté les recours de la SDE.

Sanctions. Discipline

Sanctions des fautes commises par les candidats ou titulaires de marchés publics

CMP14 art. 140 à 143

1^{er} Espèce

Ramadane SECK

DÉCISION N° 049/18/ARMP/CRD DU 11 AVRIL 2018

PAR CES MOTIFS :

- 1) Reçoit le Président du CRD en sa saisine;
- 2) Constate que dans l'offre du cabinet GIC, Monsieur Ramadane SECK est proposé au poste de technicien supérieur topographe avec un Diplôme universitaire de Technologie, option génie civil de 1993, dont la délivrance est prétendument attribuée à l'École supérieure polytechnique (ESP) ;
- 3) Constate que l'ESP, saisie par AGEROUTE pour authentifier le diplôme, a déclaré que Monsieur SECK est inconnu du répertoire des diplômés de l'École et qu'il s'agit manifestement d'un cas de fraude sur diplôme;
- 4) Constate que Monsieur SECK n'a pas répondu à la convocation de la Cellule d'Enquêtes de l'ARMP pour s'en expliquer et, malgré plusieurs relances;
- 5) Dit que l'intention délibérée du cabinet GIC d'utiliser le diplôme frauduleux n'est pas établie;
- 6) Prononce, en application de l'article 23 du décret portant organisation et fonctionnement de l'ARMP et de l'article 148 du Code des Marchés publics, l'exclusion de Monsieur Ramadane SECK des marchés publics et délégations de service public pour une durée de dix (10) ans;
- 7) Dit que la présente décision prend effet à compter de sa notification à Monsieur Ramadane SECK, ou à défaut, à compter de la date de sa publication sur le site officiel des marchés publics;

2^e Espèce

Université Virtuelle du Sénégal (UVS)

c/Société B2COM

DECISION N° 111/19/ARMP/CRD/DEF DU 17 JUILLET 2019

PAR CES MOTIFS :

- 1) *Déclare la saisine de l'Université virtuelle du Sénégal recevable ;*
- 2) *Constate que dans le cadre de la passation du marché de la DMTA ayant pour objet l'« acquisition de trois (03) lots de banderoles et drapeaux », la société B2COM a produit une fausse attestation de service fait ;*

3) *Dit qu'ainsi, B2COM a violé le Code des Marchés publics en son article 148.d) ;*

4) *Prononce, en application de l'article 149.b) du Code des Marchés publics, l'exclusion de la société B2COM des marchés publics pour une durée de trois (03) mois assortie du sursis ;*

5) *Dit que la présente décision prend effet à compter de sa notification à la société B2COM ;*

6) *Dit que le Directeur général de l'ARMP est chargé de notifier à la société B2COM, à l'Université virtuelle du Sénégal, à la Direction du Matériel et du Transit administratif ainsi qu'à la Direction centrale des Marchés publics, la présente décision qui sera publiée sur le site officiel des marchés publics.*

Commentaires

1. Les deux décisions ci-dessus ont donné l'occasion au CRD d'exercer sa compétence disciplinaire.

Dans la 1^{ère} espèce, Monsieur Ramadan SECK a fait l'objet d'une sanction d'exclusion des marchés publics et délégations de service public pour une durée de dix (10) ans. Dans la 2^{ème} espèce, la société B2COM, dénoncée par l'Université Virtuelle du Sénégal (UVS), a été sanctionnée par une peine d'exclusion des marchés publics pour une durée de trois (03) mois assortis du sursis.

Pour statuer comme il l'a fait, le CRD s'est fondé sur les textes qui organisent les sanctions et la procédure disciplinaire dans le cadre des marchés publics.

I. Sanctions et procédure disciplinaire dans le cadre des marchés publics

2. Les fondements et les incriminations sont posés par les textes ci-après.

- a) **L'article 148 CMP14** prescrit qu'en cas de violation des règles de passation de marchés, des sanctions peuvent être prononcées contre les auteurs de ces violations par le CRD, siégeant en formation disciplinaire. Le même article énumère les actes et faits incriminés et les regroupe en sept catégories, de a) à g).
- b) **L'article 149 CMP14** détermine les sanctions applicables selon les principes suivants

Article 149 :

1. Sans préjudice de poursuites pénales et d'actions en réparation du préjudice subi par l'Autorité contractante, les sanctions suivantes peuvent être prononcées et, selon le cas, de façon cumulative :

- a) confiscation des garanties constituées par le contrevenant dans le cadre des procédures de passation de marchés auxquelles il a participé ;*

b) exclusion du droit à concourir pour l'obtention de marchés publics et délégations de service public pour une durée déterminée en fonction de la gravité de la faute commise.

2. Ces sanctions peuvent être étendues à toute entreprise qui possède la majorité du capital de l'entreprise contrevenante, ou dont l'entreprise contrevenante possède la majorité du capital, en cas de collusion établie par le Comité de Règlement des Différends.

3. Lorsque les violations commises sont établies après l'attribution d'un marché ou d'une délégation de service public, la sanction prononcée peut être assortie de la résiliation du contrat en cours ou de la substitution d'une autre entreprise, aux risques et périls du contrevenant sanctionné.

4. Le contrevenant dispose d'un recours devant les tribunaux à compétence administrative à l'encontre des décisions du Comité de Règlement des Différends. Ce recours n'est pas suspensif.

3. La procédure disciplinaire est organisée par les articles 20 et 23 du décret n° 2007/546 du 25 avril 2007, portant organisation et fonctionnement de l'ARMP

a) **Article 20** : Le Président du CRD est saisi d'une dénonciation des irrégularités en matière de marché public

Si les faits concernent la violation de la réglementation en matière de **passation de marché public ou de délégation de service public**, il saisit soit le comité siégeant en formation disciplinaire

Si les faits concernent la violation de la réglementation en matière **d'exécution des marchés publics**, il saisit le Comité en formation disciplinaire

S'ils constituent une infraction pénale, il saisit les juridictions compétentes

b) **Article 23** : La procédure se déroule comme suit

Le CRD en formation disciplinaire, prononce les sanctions sous la forme d'exclusions temporaires et de pénalités pécuniaires à l'encontre des contrevenants

Les sanctions peuvent également être prononcées par le CRD statuant en commission litiges

La pénalité financière est fonction de la gravité des irrégularités et violations de la réglementation constatées, sans excéder 5% du chiffre d'affaires annuel réalisé par l'auteur de la violation constatée.

Le dernier alinéa de l'article 23 est ainsi conçu : «Le Comité de Règlement des Différends informe les autorités de tutelle compétentes ainsi que les autorités judiciaires des fautes commises par les agents de l'État à l'occasion de la passation ou de l'exécution des marchés publics et délégations de service public».

II. Mise en œuvre de la procédure disciplinaire par le CRD

Le régime des sanctions et la procédure disciplinaire en matière de marchés publics présentent des insuffisances que le CRD s'efforce de

comblent. Les deux espèces reproduites plus haut illustrent l'habileté du CRD dans ce domaine.

4. En matière de procédure disciplinaire, le dernier stade de la réglementation concerne la saisine du CRD par son Président. Les textes sont muets quant à la suite de la procédure. Or cette suite est importante parce que la procédure disciplinaire diffère de la procédure de la commission litiges sur des points importants. Ainsi

a) La composition de la commission de discipline doit garantir les droits du prévenu.

b) Le prévenu doit être entendu, assisté par son défenseur

c) L'établissement **du rapport d'enquête**, pièce maîtresse de cette procédure est entourée de garanties de transparence pour sauvegarder les droits du prévenu.

Les textes de l'ARMP sont lacunaires sur ces questions

Dans l'affaire Ramadan Seck, 1^{er} espèce ci-dessus, cet Expert avait soumis un faux diplôme à l'appui de son offre. Le CRD n'a même pas eu l'occasion de combler les insuffisances des textes, puisque l'auteur des faits incriminés avait refusé de déférer aux convocations qui lui avaient été adressées.

5. En matière de sanction, les textes sont rigides. Il n'existe que deux catégories de sanctions : la confiscation des garanties et les exclusions temporaires. S'agissant des exclusions, les textes prescrivent qu'elles peuvent être modulées en fonction de la gravité des faits ; toutefois, aucun critère de gravité n'est fourni ; dans la pratique, on ne peut donc pas exclure des dérives portant atteinte à l'égalité de traitement des candidats.

Dans les deux affaires reproduites en exergue, l'écart des sanctions s'explique par le comportement des mis en cause. En effet, Monsieur Ramadan Seck a refusé de déférer aux convocations ; il n'a donc pas pu exposer ses moyens de défense. Cette attitude peut expliquer qu'il soit sanctionné par 10 ans d'exclusion. En revanche, dans l'affaire du Cabinet B2COM, le responsable a coopéré avec le CRD pour la manifestation de la vérité, ce qui explique la peine légère de trois (03) mois assortie de sursis qui lui a été infligée.

III. Portée et effets de la jurisprudence du CRD en matière de discipline

Le CRD a rendu des décisions en matière disciplinaire dont les critères de sévérité ne sont pas aisés à déterminer. Ainsi :

1. L'expert n'a ni fourni les livrables à l'autorité contractante, ni donné de justificatifs. Il est condamné à cinq (05) ans d'exclusion (*ARMP/CRD 139 du 04 Septembre 2019 Observatoire National de la Parité (ONP)*).
2. Par négligence managériale, le responsable d'un Cabinet a laissé les CV des Experts dans les procédures, alors que le contrat avec les Experts est expiré. Le Cabinet est sanctionné de huit (08) mois d'exclusion (*ARMP/CRD 105 du 01 Août 2018 Entreprise Diama Technologie (Discipline)*).

3. Une entreprise a introduit de fausses attestations de service fait dans les offres. Elle est condamnée à six (06) mois d'exclusion. Le CRD décide en outre qu' **«Une note d'information sera transmise au Procureur de la République pour**

toute suite à donner à cette infraction pénale» (ARMP/CRD 117 du 24 Juillet 2019 Université Virtuelle du Sénégal (UVS) Discipline).

Les décisions du CRD en matière disciplinaire ont leur plein effet dans la procédure de passation de marché. Ainsi un candidat qui a fait l'objet d'une exclusion de participation à la commande publique n'a pas qualité pour exercer un recours contre l'attribution provisoire du marché. Le CRD décide :

PAR CES MOTIFS :

- 1) *Constate que Diama Technology fait l'objet d'exclusion de participation à la commande publique par décision du CRD n°105/18 du 01 août 2018 pour une durée de huit (8) mois ;*
- 2) *Constate que le CRD, par un avis donné le 01 février 2012, a précisé qu'une sanction d'exclusion, notifiée dans la phase d'attribution provisoire du marché, fait obstacle à l'attribution définitive du marché concerné ;*
- 3) **Constate que Diama Technology était déchue de son droit de participer à une procédure de passation de marché, au moment de l'introduction du recours gracieux auprès de l'autorité contractante, le 08 novembre 2018 ;**
- 4) **Constate que Diama Technology n'a pas qualité à agir pour obtenir l'annulation de la décision d'attribution provisoire ;**
- 5) **Déclare que ce défaut de qualité à agir constitue une fin de non-recevoir justifiant le rejet de son recours ; (ARMP/CRD 004 du 09 Janvier 2019 Société Diama Technologie).**

Le cadre normatif de la compétence disciplinaire de l'ARMP mérite d'être rationalisé. En attendant, une Résolution du Conseil de Régulation de l'ARMP pourrait en fixer les grandes lignes.
